



République du Sénégal
Primature
AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS



BULLETIN DES DÉCISIONS ET AVIS RENDUS PAR LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PERIODE DE 2014 A 2015



Mars 2017

Préface

L'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est une autorité administrative indépendante dotée d'une autonomie financière et de gestion.

Elle a pour mission d'émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des politiques et de l'assistance à l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de délégations de service public, de contribuer à l'information, à la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public, d'exécuter des enquêtes, de mettre en œuvre des procédures d'audits indépendants, de sanctionner les irrégularités constatées, de procéder au règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation des marchés publics et des délégations de service public, ou de rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de leur exécution.

L'ARMP est composée de trois organes : le Conseil de Régulation, le Comité de Règlement des Différends et la Direction générale. Le Comité de Règlement des Différends (CRD) est l'organe qui est chargé de connaître les recours et les demandes d'avis introduites devant l'ARMP ; il siège, en fonction des faits dont il est saisi, soit en Commissions des Litiges, soit en Formation disciplinaire.

C'est ainsi que le CRD rend des décisions qui ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée de la réglementation ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. Il peut rendre aussi des avis sur la réglementation des marchés publics.

Le contexte et la justification de cette étude commandent la compréhension que nous devons avoir de la mission du Régulateur dans le traitement du contentieux de la régulation des marchés publics et des délégations de service public. Cette régulation découle d'une approche nouvelle qui, au début, a dû dérouter certains acteurs de la Justice : ils voyaient en cela une forme de « dépossession » d'une partie de leurs attributions au profit d'une autorité administrative autonome. Il n'en est rien.

En effet, l'ARMP exerce dans le champ du contrôle a posteriori, le règlement non-juridictionnel des litiges et les sanctions prévues. Ce contrôle ne se traduit pas par une « dépossession » dans le contentieux de la régulation : le juge d'appel reste la Cour Suprême. La mission de régulation du système de passation des marchés publics est à mesurer à l'aune des rapports féconds que peuvent entretenir « Juge » et « Régulateur ». Cette complémentarité permet de garantir à la commande publique l'efficacité et surtout la célérité qui sont nécessaires à la réalisation satisfaisante de l'objectif de rationalisation de la dépense publique.

Outre ces passerelles salutaires, la mise en place d'un Droit public communautaire des marchés publics qui se nourrit d'un système de recours non-juridictionnel, mais aussi de son contrôle par le juge administratif. Gage d'une jurisprudence conforme à la réglementation communautaire sur les marchés publics.

Le présent Bulletin regroupe l'essentiel des décisions et avis rendus par le CRD entre 2014 et 2016. Il est un document à destination des acteurs du système de passation des marchés notamment les autorités contractantes, les opérateurs économiques, les bailleurs de fonds, la famille judiciaire, le monde universitaire. Les décisions et avis du CRD sont commentés par le magistrat Adiouma SEYE.

S'inscrivant dans une logique d'amélioration continue, l'ARMP compte sur les acteurs pour toutes observations tendant à conforter la pratique du CRD.



SOMMAIRE

SOMMAIRE	3
INTRODUCTION	7
THEMES	
I. INCOMPETENCE DU CRD A L'EGARD DES ASSOCIATIONS DE DROIT PRIVE ET A L'EGARD DES SOCIETES DE DROIT PRIVE DANS LESQUELLES LA PARTICIPATION PUBLIQUE N'EST PAS MAJORITAIRE (articles 11 et 12 de la directive n°5/2005/CM/UEMOA-article 31 nouveau du Code des Obligations de l'Administration- aticle 2 du Code des Marchés publics- articles 20 à 24 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP)	9
II. IRRECEVABILTE DES RECOURS ADRESSES AU CRD	16
2.1 Irrecevabilité pour forclusion : irrecevabilité des recours adressés au CRD au-delà-du délai de trois(3) jours ouvrables fixé par le Code des Marchés Publics (articles 88 et 89 du Code des Marchés publics de 2011-articles 89 et 90 du Code des Marchés publics de 2014)	17
2.2 Irrecevabilité pour défaut de recours gracieux préalable adressé à l'autorité contractante (article 89 du Code des Marchés publics de 2014)	20
2.3 Irrecevabilité pour inobservation du délai d'attente du recours gracieux(articles 88 et 89 du Code des Marchés publics de 2011-articles 89 et 90 du Code des Marchés publics de 2014)	23
2.4 Irrecevabilité pour cause de deux recours gracieux	26
2.5 Irrecevabilité pour saisine du CRD avant la publication de l'avis d'attribution provisoire (articles 88 et 89 du Code des Marchés publics de 2011-articles 89 et 90 du Code des Marchés publics de 2014)	30
2.6 Irrecevabilité pour défaut de qualité à agir (article 89 du Code des Marchés publics de 2014)	33
2.7 Irrecevabilité pour absence de preuve de l'allégation	36
2.8 Irrecevabilité pour absence de grief (articles 89 et 90 du Code des Marchés publics de 2014)	40
2.9 Irrecevabilité pour non-paiement de consignation (article 90 du Code des Marchés publics de 2014)	43
2.10 Irrecevabilité pour irrespect du délai de saisine de l'autorité contractante (article 89 du Code des Marchés publics de 2014)	46
III. AFFIRMATION, NON PROUVEE, DE L'INEXISTENCE D'UNE PIECE AU MOMENT DE L'OUVERTURE DES PLIS ET ABSENCE D'INTERDICTION A DES SOCIETES DIFFERENTES DE SOUMISSIONNER LES MEMES PRODUITS ET A DES PRIX DIFFERENTS (article 44 du Code des Marchés publics de 2014)	50
IV. OBLIGATION POUR LE GROUPEMENT SOUMISSIONNAIRE DE LISTER SUR LA GARANTIE DE SOUMISSION TOUS LES MEMBRES DUDIT GROUPEMENT (articles 114 à 120 du Code des Marchés publics de 2014- dispositions du cahier des charges)	58
V. AFFIRMATION, NON-FONDEE, SELON LAQUELLE L'ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE NE REMPLIT PAS LES CRITERES PREVUS DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (article 44 des codes des marchés publics de 2011 et 2014-clauses du DAO).	73
VI. IMPERTINENCE DE LA CONTESTATION D'UNE CLAUSE DU DOSSIER DE CONSULTATION SOULEVEE APRES L'ATTRIBUTION PROVISOIRE (article 89 du Code des Marchés publics de 2014)	83
VII. OBLIGATION POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE DE RESPECTER LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE(article 67 alinéas 2 et 3 des Codes de Marchés publics de 2011 et 2014- article 24 nouveau du Codes des Obligations de l'Adminstration)	89
VIII. OBLIGATION POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE DE RESPECTER LES PRINCIPES D'EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS ET DE LIBRE ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE (article 67 des Codes de Marchés publics de 2011 et 2014- article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration –article 2 de la directive n°04/2005/CM/UEMOA	95

IX.	LA DETERMINATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONTENUES DANS LE DAO PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE EST SOUMISE AU CONTROLE DE L'ARMP ET DE LA COUR SUPREME (article 7 des Codes de Marchés publics de 2011 et 2014- article 2 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP)	101
X.	OBLIGATION POUR LA COMMISSION DES MARCHES DE MOTIVER LE REJET DE L'OFFRE JUGEE ANORMALEMENT BASSE (article 59-4 des Codes de Marchés publics de 2011 et 2014)	107
XI.	L'APPEL D'OFFRES OUVERT EST LE PRINCIPE ET L'ENTENTE DIRECTE OBEIT A DES CONDITIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR LA LOI (article 26 nouveau du Code des Obligations de l'Administration - article 38 de la directive n°4/2005/CM/UEMOA-article 76 des Codes de Marchés publics de 2011 et 2014)	114
XII.	POURSUITE DE LA CONCLUSION DU MARCHÉ PAR ENTENTE DIRECTE SUR CERTIFICATION DU PREMIER MINISTRE(article 76, dernier alinéa des Codes des Marchés publics de 2011 et 2014)	120
XIII.	OBLIGATION POUR L'AUTORITE CONTRACTANTE DE PUBLIER SUR UN SUPPORT INTERNATIONAL L'AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL (article 56-3 du Code des Marchés publics de 2014-article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration)	126
XIV.	OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ CONTRACTANTE D'AVOIR UN MINIMUM DE TROIS SOUMISSIONNAIRES (articles 67.5 et 74 du Code des Marchés publics de 2014)	139
XV.	DENONCIATION D'IRREGULARITES: EXCLUSION DU FAUSSAIRE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (article 20 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fontionnement de l'ARMP-articles 148 et 149 du Code des Marchés publics de 2014)	145
XVI.	LES MEMBRES DE LA COMMISSION DES MARCHES DOIVENT ETRE DISTINCTS DE CEUX DE LA CELLULE DE PASSATION ET SON PRESIDENT DOIT ETRE UN FONCTIONNAIRE DE LA HIERARCHIE B OU UN CADRE OU ASSIMILE (article 35 du Code des Marchés publics de 2014-arrêté n°0864 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan) ..	151
XVII.	L'AUGMENTATION DES FOURNITURES RESULTANT D'UN AVENANT NE PEUT DEPASSER 30% DU MONTANT INITIAL (article 24 du Code des Marchés publics de 2014)	157
XVIII.	AUTORISATION D'OUVRIR A L'INTERNATIONAL UN APPEL D'OFFRES (articles 47 et 52 du Code des Marchés publics de 2011)	162
XIX.	INTERDICTION A L'AUTORITE CONTRACTANTE DE PROCEDER A UN CLASSEMENT SANS SUITE ABUSIF (articles 64 et 65 du Code des Marchés publics de 2011)	168
XX.	L'AVIS DU CRD NE PEUT FAIRE GRIEF AU REQUERANT (article 2.5 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP)	176
XXI.	REVERSEMENT DE LA CONSIGNATION AU REQUERANT DONT LE RECOURS EST FONDE (article 90 alinéas 2 et 3 du Code des Marchés publics de 2014)	182

INTRODUCTION

A l'issue de l'exploitation et de l'analyse des décisions et avis rendus par le CRD pendant la période de 2008 à 2013, un bulletin desdits avis et décisions avait été élaboré et publié par l'ARMP; il s'agissait du premier bulletin, en la matière, regroupant vingt-six (26) thèmes.

Ce deuxième bulletin, réalisé à partir de l'exploitation et de l'analyse des décisions et avis rendus de 2014 à 2015, compte vingt-un (21) thèmes et dix (10) sous-thèmes.

Il existe une complémentarité entre ces deux bulletins ; en effet, même si quelques thèmes du premier bulletin son repris dans le présent bulletin (obligation de respecter les principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats- incompétence du CRD à l'égard de certains marchés- participation des entreprises étrangères...), on note dans ce bulletin numéro deux (2) plusieurs nouveaux thèmes et sous-thèmes.

Il en est ainsi, par exemple, de sept (7) sous-thèmes relatifs à l'irrecevabilité (pour défaut de recours gracieux préalable - pour inobservation du délai d'attente du recours gracieux – pour absence de grief...) ; il en est de même des thèmes nouveaux relatifs :

- à l'obligation du groupement de soumissionnaires de lister sur sa garantie de soumission tous les membres du groupement ;
- au contrôle du CRD et de la Cour Suprême sur la détermination des spécifications techniques contenues dans le DAO ;
- à l'obligation de la commission des marchés de motiver le rejet de l'offre anormalement basse, même si elle a un pouvoir souverain d'appréciation de ladite offre ;
- au principe de l'appel d'offres ouvert et aux conditions de l'entente directe ;
- à l'interdiction faite à l'autorité contractante de procéder à un classement sans suite abusif

Ces deux bulletins, comme les différents guides élaborés par l'ARMP (Guide du soumissionnaire destiné aux PME, Check-list pour le contrôle des procédures ..., constituent des instruments, pratiques et utiles ; ils permettent aux acteurs de la commande publique d'éviter des erreurs au niveau de toutes les étapes du processus des marchés publics, de l'identification à la liquidation, en passant par la préparation, l'attribution, l'exécution et la réception ; et de minimiser les risques de rejet de leur dossier et de leur recours au niveau de différents organes d'attribution, de contrôle et de régulation.



**INCOMPETENCE DU CRD A L'EGARD
DES ASSOCIATIONS DE DROIT PRIVE ET
A L'EGARD DES SOCIETES DE DROIT PRIVE
DANS LESQUELLES LA PARTICIPATION
PUBLIQUE N'EST PAS MAJORITAIRE**

Pour apprécier les domaines de compétence du CRD, il faut se référer aux textes et articles suivants :

- Articles 11 et 12 de la directive n° 05/2005/CM/UEMOA ;
- Article 31 nouveau du Code des Obligations de l'Administration ;
- Article 2 du code des marchés publics ;
- Articles 20 à 24 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP).

En application de ces dispositions, le CRD s'est déclaré incompétent chaque fois qu'il a été saisi d'une affaire n'entrant pas dans le champ de sa compétence.

C'est ainsi que de 2008 à 2015 le CRD a rendu trente décisions d'incompétence ne représentant que 2,42% du total du nombre de recours tranchés. En 2014 et 2015, il a rendu sept (7) décisions d'incompétence.

Nous donnerons à titre d'exemple deux affaires dans lesquelles le CRD s'est déclaré incompétent en 2014. La première affaire est relative à la « Fédération des producteurs maraichers de la zone des Niayes » qui est une association de droit privé (décision n°33 du 5 février 2014). La seconde affaire est relative à la SODIFITEX, qui est une société de droit privé dans laquelle la participation publique n'est pas majoritaire (décision n°103 du 16 avril 2014).

**DECISION N° 033/14/ARMP/CRD DU 05 FEVRIER 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LA FEDERATION DES
PRODUCTEURS MARAICHERS DE LA ZONE DES NIAYES DE PASSER PAR ENTENTE DI-
RECTE, LE MARCHE D'ACQUISITION DE SEMENCES DE POMME DE TERRE, SUITE AU
REFUS DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS.**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes en date du 24 janvier 2014, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 20/14 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Poulméry BA NIANG, Directrice de la Formation et des Appuis techniques assurant l'intérim du Directeur général de l'ARMP absent, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'enquête sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et délégations de service public et contrats de partenariat ; Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d'enquêtes à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Khadijetou LY, chargée d'enquêtes à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 24 janvier 2014, la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes (FPMN) a saisi le CRD d'une demande d'autorisation de passer en urgence par entente directe, le marché d'acquisition de semences de pomme de terre, suite à l'avis défavorable de la DCMP.

SUR LA COMPETENCE

Considérant que selon les dispositions de l'article 141.3 du Code des marchés publics, si l'autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou relative à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends (CRD) auprès de l'organe chargé de la régulation des marchés publics ;

Considérant que la saisine du CRD fait suite au refus de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) d'autoriser une entente directe entre la société COGEPAL et la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes (FPMN) pour l'acquisition de semences de pomme de terre ;

Considérant que ce refus est doublement motivé par le défaut de qualité d'autorité contractante de la FPMN ainsi que la déclaration d'incompétence du Ministère chargé de l'agriculture et du PADEN pour porter la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du Code des Marchés publics, les dispositions du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 s'appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :

- a) l'Etat, y compris ses services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité;
- b) les collectivités locales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale, placés sous leur autorité, ainsi que les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 74 et 327 du Code des collectivités locales;
- c) les établissements publics;
- d) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général;
- e) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire;

f) les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) ci-dessus.

Considérant d’une part que, la FPMN est une association de droit privé dont les activités ne rentrent pas dans le champ du Code des Marchés publics et que, d’autre part, les fonds qui vont servir à la réalisation dudit marché vont provenir du seul compte bancaire de la FPMN. ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer l’incompétence du CRD ;

PAR CES MOTIFS:

- 1) Constate que la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes est une association de droit privé qui n’est pas considérée comme une autorité contractante au sens des dispositions de l’article 2 du Code des Marchés publics ;
- 2) Constate que le Code des Marchés publics n’est pas applicable pour le marché envisagé ;
- 3) Se déclare incompétent ;
- 4) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Fédération des Producteurs Maraîchers de la Zone des Niayes et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP	Les membres du CRD Cheikhou Issa SYLLA	Boubacar MAR
	Pour le Directeur Général Rapporteur Poulméry BA NIANG	

**DECISION N° 103/14/ARMP/CRD DU 16 AVRIL 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE EMG UNIVERSAL AUTO
CONTESTANT LES CRITERES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES PORTANT SUR LA
FOURNITURE DE CAMIONS CHASSIS CABINES PORTEURS, BRAS HYDRAULIQUES DE
CHARGEMENT/DECHARGEMENT DES CONTENEURS, REMORQUES, LANCE PAR LA
SODEFITEX**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l'entreprise EMG Universal Auto du 08 avril 2014, enregistré le 10 avril 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 104/14 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ousseynou CISSE, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Boubacar MAR et Samba DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Salimata SALL DEMBELE, assurant l'intérim du Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, coordonnateur de la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation ; Cheikh Saad Bou SAMB, Conseiller technique ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, Baye Samba DIOP, juriste, chargé de la Régulation et Madame Khadi djetou DIA LY, chargée d'enquêtes à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 08 avril 2014, enregistré le 10 avril 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 104/14, l'entreprise EMG Universal Auto a saisi le CRD pour contester le contenu du dossier d'appel d'offres relatif à la fourniture en cinq lots de camions châssis cabines porteurs, bras hydrauliques de chargement/déchargement des conteneurs, remorques porte conteneurs, automoteurs pour manutention des conteneurs, 40 conteneurs coton graine trapézoïdiques type CMT 75/40, lancé par la Société de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX).

SUR LA COMPETENCE DU CRD

Considérant que l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration (COA) précise que les principes fondamentaux qui régissent les marchés publics s'appliquent aux achats effectués par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, par les personnes qui agissent au nom et pour le compte des acheteurs publics et par les organismes dont l'activité est financée

majoritairement par des fonds publics, déterminés conformément aux dispositions du Code des Marchés publics ;

Qu'en application des dispositions ci-dessus, l'article 2 du Code des Marchés publics fixe le champ d'application dudit Code par énumération exhaustive des personnes morales auxquelles il s'applique ;

Considérant que le recours de l'entreprise EMG Universal Auto vise un marché passé par la SODEFITEX qui est une société privée dans laquelle la participation publique n'est pas majoritaire dans le capital ;

Qu'il en résulte que la SODEFITEX n'est pas autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics et, en conséquence, n'est pas soumise audit Code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21, alinéa 2 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), le Comité de Règlement des Différends (CRD) est compétent pour recevoir et enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu'à leur objet ;

Que la SODEFITEX, n'étant pas concernée par les dispositions de l'article 2 du Code des Marchés publics qui énumère la liste des autorités contractantes relevant du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011, le CRD doit se déclarer incompétent ;

PAR CES MOTIFS:

- 1) Constate que le recours de EMG Universal Auto concerne un marché lancé par la SODEFITEX qui est société de droit privée et n'est pas une autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics ;
- 2) Se déclare incompétent pour statuer sur le recours ;
- 3) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'entreprise EMG Universal Auto, à la SODEFITEX ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Les membres du CRD
Samba DIOP et Boubacar MAR**

**Pour le Directeur général
Rapporteur
Salimata SALL DEMBE**

2

IRRECEVABILITE DES RECOURS ADRESSES AU CRD

De 2008 à 2015, le CRD a déclaré irrecevables 295 recours initiés devant lui, soient 23,71% du total des recours tranchés (1244 recours), donc presque le quart.

En 2014 et 2015 le nombre de recours irrecevables est respectivement de 49 (20,94%) et 39 (15,98%).

Aucune de ces décisions n’a été déférée devant la Cour Suprême, contrairement à la période 2008 à 2013.

Et pendant ces deux années 2014 et 2015, les dix causes d’irrecevabilité sont les suivantes :

N° d’ordre	Causes d’irrecevabilité	Année 2014	Année 2015	total
1	Irrecevabilité pour forclusion (saisine hors-délai)	25	25	50
2	Irrecevabilité pour défaut de recours gracieux préalable	3	5	8
3	Irrecevabilité pour inobservation du délai d’attente du recours gracieux	16	5	21
4	Irrecevabilité pour avoir effectué deux recours gracieux	-	1	1
5	Irrecevabilité pour saisine avant publication avis d’attribution	-	-	2
6	Irrecevabilité pour défaut de qualité à agir	2	-	1
7	Irrecevabilité pour non production de document prouvant l’allégation	1	-	1
8	Irrecevabilité pour absence de grief	1	-	1
9	Irrecevabilité pour non-paiement de consignation	1	2	2
10	Irrecevabilité pour irrespect du délai de saisine de l’autorité contractante	-	1	1
Totaux		49	39	88

2.1 Irrecevabilité pour forclusion (irrecevabilité des recours adressés au CRD au-delà-du délai de trois (3) jours ouvrables fixé par le Code des Marchés publics)

Il résulte des articles 88 et 89 du code de 2011 (89 et 90 du code de 2014) que tout candidat à une procédure d’attribution d’un marché peut, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux, auquel celle-ci est tenue de répondre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables (code 2011) et 3 jours ouvrables(code 2014); qu’en l’absence d’une suite favorable à son recours, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai, susvisé imparti à ladite autorité, pour présenter un recours au CRD.

S’appuyant sur ces dispositions, le CRD pendant les années 2014 et 2015 a rendu 88 décisions d’irrecevabilité, dont les 50 (soient 56,82%) ont pour cause la forclusion du requérant, c’est-à-dire que celui-ci a attendu l’expiration du délai de trois jours qui lui est réservé pour saisir tardivement le CRD. L’importance relative de cette cause d’irrecevabilité montre que la computation des délais n’est pas encore maîtrisée par certains soumissionnaires, d’où la nécessité d’une action de formation.

**DECISION N° 047/14/ARMP/CRD DU 19 FEVRIER 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE TRANSAFRICAINE DE TRAVAUX ET SERVICES RELATIF A L'APPEL D'OFFRES DE LA SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL (SONES) AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX D'EXTENSION DE L'USINE DE TRAITEMENT DE KHOR DE SAINT- LOUIS, DE LA PRISE D'EAU DE BANGO ET LA CONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Transafricaine de Travaux et Services (TTS) en date du 11 février 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 037/14 ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

Vu la consignation faite par TTS ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique, Ely Manel FALL, Chef de la Division de la réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes, Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijatou LY DIA, chargée d'enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 11 février 2014, TTS a saisi le CRD d'un recours contentieux pour contester l'éviction de son offre concernant le lot 2 de l'appel d'offres de la SONES, ayant pour objet les travaux d'extension de l'usine de traitement de Khor de Saint-Louis, de la prise d'eau de Bango et la construction de la station de pompage.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l'autorité contractante ou l'expiration du délai de cinq (5) jours qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, par lettre du 28 janvier 2014, avant publication de l'attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 31 janvier 2014, la SONES a informé TTS du rejet de son offre concernant le lot 2 de l'appel d'offres précité ;

Que, par courrier daté du 30 janvier 2014, le requérant a saisi la SONES d'un recours gracieux auquel l'autorité contractante a répondu par correspondance du 04 février 2014, reçue le même jour par TTS ;

Qu'au vu de la réponse défavorable de la SONES, le 11 février 2014, TTS a saisi le CRD d'un recours contentieux ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, le requérant devait saisir le CRD au plus tard le 07 février 2014 ;

Qu'en conséquence, TTS ayant saisi le CRD après l'expiration du délai de saisine, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS:

- 1) Constate que TTS a saisi le CRD après expiration du délai qui lui était imparti ;
- 2) Déclare, en conséquence, son recours irrecevable ;
- 3) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 4) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à Transafricaine de Travaux et Services, à la SONES, ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP **Les membres du CRD**
Boubacar MAR **Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

2.2 Irrecevabilité pour défaut de recours gracieux préalable adressé à l'autorité contractante

L'article 88 du code de 2011 stipule que : « *Tout candidat à une procédure d'attribution d'un marché est habilité à saisir la personne responsable du marché d'un recours gracieux* ».

Par contre l'article 89 du code de 2014 est ainsi libellé : « *Tout candidat à une procédure d'un marché doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la personne responsable du marché d'un recours gracieux* ».

Ainsi, alors que le recours gracieux auprès de l'autorité contractante n'était qu'une simple faculté donnée au candidat à la commande publique sous l'empire du code de 2011, comme du code de 2007, par contre il est devenu maintenant une obligation avec le code de 2014.

Donc actuellement tout soumissionnaire qui a des contestations à faire à l'égard d'un marché, doit, avant de saisir le CRD, adresser un recours gracieux à la personne responsable du marché, sinon le CRD déclare son action irrecevable.

**DECISION N° 069/15/ARMP/CRD DU 23 MARS 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE DE COMMERCE ET DE
SERVICES SUARL (ENCOSER) CONSTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISoire DU LOT N°7
(EPT THIES) DU MARCHE LANCE PAR LE CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE
DAKAR POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU RESTAURANT DE L'EPT**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l'Entreprise de Commerce et de Service (EN.CO.SER) du 12 mars 2015, reçu à l'ARMP le même jour ;

Vu la consignation faite par l'Entreprise de Commerce et de Service (EN.CO.SER) le 13 mars 2015 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision.

Par courrier du 12 mars 2015, reçu le même jour et enregistré le 16 mars 2015 au secrétariat du CRD sous le n°064/CRD, l'Entreprise de Commerce et de Services SUARL (EN.CO.SER) a introduit un recours pour contester l'attribution provisoire du lot n°7 (restaurant de l'EPT) du marché relatif à la gestion et l'exploitation des restaurants universitaires.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public doit préalablement à tout recours contentieux, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction qu'après la publication dans le journal « le soleil » du 11 mars 2015 de l'attribution provisoire des sept (07) lots du marché relatif à la gestion et l'exploitation des restaurants universitaires « Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, Bloc ISFAR-CMRT-UFR Santé, Hôtel du Rail, EPT, Ziguinchor », l'entreprise ENCOSER a saisi le CRD le lendemain 12 mars 2015, pour contester l'attribution du lot n°7 à l'entreprise IGB ;

Qu'ainsi, le recours contentieux devant le CRD a été introduit sans recours gracieux préalable;

Qu'en conséquence, il y a lieu de le déclarer irrecevable et d'ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que ENCOSER a saisi directement le CRD au lendemain de la publication de l'avis d'attribution provisoire ;
- 2) Constate que le recours n'a pas été précédé d'un recours gracieux préalable ;
- 3) En conséquence, le déclare irrecevable ;
- 4) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 5) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à ENCOSER, au COUD ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président
Mademba GUEYE

Samba DIOP **Les membres du CRD**
Boubacar MAR **Cheikhou Issa SYLLA**

Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG

Cette innovation du code est venue à l'heure parce que si le contentieux peut être réglé au niveau de l'autorité contractante, il vaut mieux s'en arrêter là ; mais il est exceptionnel de voir une autorité contractante donner une suite favorable à un recours gracieux.

Cependant le nombre total de décisions d'irrecevabilité enregistrées pour défaut de recours gracieux préalable étant faible (8 soit 9% du total des décisions d'irrecevabilité) on peut penser que cette nouveauté du code est maîtrisée par les acteurs de la commande publique.

2.3 Irrecevabilité pour inobservation du délai d'attente du recours gracieux

Il résulte des articles 88 et 89 du code de 2011 et 89 et 90 du code de 2014 que si le candidat à une procédure d'attribution d'un marché saisit la personne responsable du marché d'un recours gracieux, celle-ci a un délai (de cinq jours ouvrables selon le code de 2011 et de trois jours ouvrables selon le code de 2014) pour y répondre et qu'au-delà de ce délai le défaut de réponse sera constitutif d'un rejet implicite dudit recours ; qu'en l'absence de suite favorable à son recours gracieux le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables, à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai imparti à cette dernière pour répondre, pour saisir le CRD.

Donc le candidat ne peut ni saisir l'autorité contractante et le CRD en même temps, ni saisir le CRD sans avoir reçu la réponse défavorable de l'autorité contractante ou avant l'expiration du délai imparti à cette dernière pour répondre.

**DECISION N° 007/14/ARMP/CRD DU 08 JANVIER 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GIE MAFATIOUL BISRI PORTANT SUR
LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 16 ECOLES COMPLETES
COMPOSEES CHACUNE DE 3 SALLES DE CLASSE, 1 BLOC ADMINISTRATIF, 1 POINT
D'EAU, 1 BLOC D'HYGIENE ET 1 MUR DE CLOTURE DANS LA REGION DE KOLDA, LANCE
PAR L'INSPECTION D'ACADEMIE DE KOLDA.**

19

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du GIE MAFATIOUL BISRI ;

Vu la quittance de consignation du 13 décembre 2013 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de M. Samba DIOP, M. Boubacar MAR et M. Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; M. Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d'enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre du 12 décembre 2013, enregistrée le 13 décembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 564/13, le GIE MAFATIOUL BISRI a introduit un recours pour contester l'attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction de 16 écoles complètes composées chacune de 3 salles de classe, un bloc administratif, un point d'eau, un bloc d'hygiène et un mur de clôture dans la région de Kolda pour le compte de l'entreprise Bolé Yakar (EBY) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics que tout candidat à un marché public peut saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication du dossier d'appel d'offres puis le CRD dans les trois jours suivant l'expiration du délai de cinq jours imparti à l'autorité contractante pour répondre ; Considérant qu'il résulte des faits invoqués, que suite à la publication de l'avis d'attribution provisoire dans le quotidien « le soleil » du 07 décembre 2013, le GIE MAFATIOUL BISRI est informé du rejet de son offre ;

Que le requérant a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux par courrier daté du 10 décembre 2013, pour contester l'attribution provisoire du marché à l'entreprise Bolé Yakar (EBY) ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux ne peut adresser de recours au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l'expiration du délai de cinq jours constitutive d'un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Que le GIE MAFATIOUL BISRI en décidant de porter sa contestation devant le CRD le 13 décembre 2013, enregistrée le même jour au service du courrier à la suite de son recours gracieux du 10 décembre 2013 auprès de l'autorité contractante, n'a pas observé le délai d'attente légal imposé par la réglementation en vigueur en l'absence de réponse de cette dernière ;

Qu'ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Que sa demande n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation ;

DECIDE:

- 1) Constate que le GIE MAFATIOUL BISRI a saisi le CRD à la suite de son recours gracieux sans avoir observé le délai d'attente légal imposé par la réglementation en vigueur en l'absence de réponse de cette dernière ; en conséquence,
- 2) Déclare irrecevable ledit recours ;
- 3) Ordonne la confiscation de la consignation ;

4) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au GIE MAFATIOUL BISRI, à l'Inspection d'Académie de Kolda ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP **Les membres du CRD
Cheikhou Issa SYLLA** **Boubacar MAR**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

Si le nombre de décisions d'irrecevabilité pour cause de défaut de recours gracieux est relativement faible, par contre le nombre de décisions d'irrecevabilité pour cause d'inobservation du délai d'attente du recours gracieux est relativement élevé en 2014 et 2015 (21 représentant 23,86% du total des causes d'irrecevabilité, soit près du quart).

2.4 Irrecevabilité pour cause de deux recours gracieux

La société Générale de Travaux et de Services (GTS) était candidate à un appel d'offres lancé par le Projet d'Appui à la Promotion de l'Emploi des jeunes et des Femmes (PAPEJF) du Ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne. Après réception de la lettre de notification de l'attribution provisoire le 18 mai 2015, l'entreprise GTS a saisi l'autorité contractante par courrier du 19 mai 2015 pour contester ladite attribution. N'étant pas satisfaite de la réponse fournie par l'autorité contractante, par correspondance reçue le 20 mai 2015, GTS réintroduit un autre recours gracieux par correspondance reçue le lendemain par l'autorité contractante.

Finalement elle saisit le CRD d'un recours contentieux reçu le 27 mai 2015. Le CRD par décision n° 137 du 3 juin 2015 déclara irrecevable le recours, non seulement parce qu'il a été introduit tardivement, mais également parce que les dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics de 2014 ne prévoient pas, pour un candidat qui envisage un recours auprès du CRD, la possibilité de saisir l'autorité contractante une deuxième fois après une réponse défavorable à un premier recours gracieux.

DECISION N° 137/15/ARMP/CRD DU 03 JUIN 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE GENERALE DE TRAVAUX ET DE SERVICES
CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISoire DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET
POSE DE CLOTURE GRILLAGEE ET CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE TOILETTES,
LANCE PAR LE PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES
FEMMES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Générale de Travaux et de Services (GTS) du 26 mai 2015 ;

Vu la consignation faite le 26 mai 2015 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou DIA LY, Chargée d'enquêtes et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ;

Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 26 mai 2015, reçu le lendemain au secrétariat du CRD sous le n°124/CRD, l'entreprise GTS a introduit un recours contentieux pour contester l'attribution provisoire du marché relatif à la fourniture et à la pose de clôture grillagée et construction de bâtiments et toilettes à deux boxes dans les fermes des régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor lancé par le Projet d'Appui a la Promotion de l'Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) du Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 91 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public doit préalablement à tout recours contentieux, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction qu'après la réception de la lettre de notification de l'attribution provisoire le 18 mai 2015, l'entreprise GTS a saisi l'autorité contractante par courrier du 19 mai 2015 pour contester l'attribution provisoire du lot n°4 du marché ;

Que n'ayant pas été satisfait de la réponse fournie par l'autorité contractante par correspondance reçue le 20 mai 2015, le requérant a réintroduit un autre recours par correspondance du 21 mai 2015 reçue le lendemain par l'autorité contractante ;

Que sans attendre de recevoir une réponse à sa deuxième saisine, l'entreprise GTS a saisi le CRD d'un recours contentieux par lettre du 26 mai 2015, reçue le 27 mai 2015.

Qu'au regard de la réglementation, lorsque la réponse de l'autorité contractante au recours gracieux est parvenue au requérant le 20 mai 2015, ce dernier aurait dû saisir le CRD dans les trois (3) jours à compter de la réception de la réponse, soit au plus tard le 22 mai 2015 ;

Que dès lors, étant donné que le recours contentieux est parvenu au CRD le 27 mai 2015, il doit être déclaré irrecevable pour tardiveté ;

Qu'au surplus, les articles 89 et 90 du Code des Marchés publics ne prévoient pas, pour un candidat aux marchés publics qui envisage de soumettre un recours au CRD, la possibilité de saisir l'autorité contractante une deuxième fois après une réponse défavorable à un premier recours gracieux ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 6) Constate que le requérant a saisi l'autorité contractante une deuxième fois après une réponse défavorable à son recours gracieux ;
- 7) Constate que le recours contentieux est parvenu au CRD au-delà des délais prescrits par la réglementation ;
- 8) Déclare, en conséquence, ledit recours irrecevable ;
- 9) Ordonne la confiscation de la consignation ;

- 10) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société Générale de Travaux et de Services (GTS), au Projet d'Appui à la Promotion de l'Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

**Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

Heureusement que cette cause d'irrecevabilité est marginale, car elle n'a concerné qu'une seule affaire pendant les années 2014 et 2015.

2.5 Irrecevabilité pour saisine du CRD avant la publication de l'avis d'attribution provisoire

Il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du code de 2011(89 et 90 du code de 2014) que les contestations relatives à l'évaluation des candidats et au rejet des offres doivent être faites après la publication de l'avis d'attribution provisoire ou de la notification de la décision d'attribution.

Se fondant sur lesdites dispositions le CRD déclare irrecevables tous les recours faits avant la publication de l'avis d'attribution provisoire et relatifs auxdites contestations.

DECISION N° 095/14/ARMP/CRD DU 09 AVRIL 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE KEUR SERIGNE TOUBA PORTANT LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE LANCE PAR LA COMMUNE DE LOUGA

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l'entreprise KEUR SERIGNE TOUBA en date du 19 mars 2014, reçu le 21 mars 2014 ;

Vu la consignation faite par l'entreprise KEUR SERIGNE TOUBA, le 19 mars 2014 ;
Madame Khadijetou Dia LY, chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Ely Manel FALL, Chef de la division Réglementation ; Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes à la Cellule d'enquête et d'Inspection ; Moussa Diagne, chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, juriste spécialiste de la régulation, observateurs ;

Par lettre du 19 mars 2014 reçue et enregistrée le 21 mars 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 088/14, l'entreprise KEUR SERIGNE TOUBA a introduit un recours pour dénoncer le comportement de la commission des marchés de la municipalité de Louga lors de la séance d'ouverture des plis relative au marché portant sur les travaux d'extension du réseau d'eau potable de la commune de Louga.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l'autorité contractante ou l'expiration du délai de cinq jours imparti à l'autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de la demande de propositions ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la Commune de Louga a procédé à la publication de l'avis d'appel d'offres relatif aux travaux d'extension du réseau d'eau potable de la commune de Louga dans le journal « Le Soleil » du 06 février 2014 en fixant la date d'ouverture des plis au 10 mars 2014 ;

Considérant que le requérant a saisi le CRD par lettre du 19 mars 2014 pour dénoncer « le comportement de la commission des marchés » de la Commune de Louga qui aurait rejeté son offre au motif qu'une copie de la page de garde de son offre a été retrouvée dans celle d'une entreprise concurrente ;

Considérant que la saisine du CRD est intervenue sans que le requérant ne puisse justifier que l'avis d'attribution provisoire du marché est publié ;

Qu'au surplus, les investigations menées ont permis de confirmer que l'évaluation des offres est encore en cours ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 88 du Code des Marchés publics que le fait déclencheur du recours doit, en l'espèce, résulter de la publication de l'avis d'attribution provisoire ou de la notification de la décision d'attribution ;

Qu'ainsi, le recours n'ayant pas respecté les règles de forme prévues par les articles 89 et 90 susvisées, il doit être déclaré irrecevable ;

Que dès lors le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que l'entreprise KEUR SERIGNE TOUBA a introduit un recours pour dénoncer le comportement de la commission des marchés qui aurait rejeté son offre lors de la séance d'ouverture des plis du 10 mars 2014 ;
- 2) Dit que le requérant n'a pas prouvé que l'avis d'attribution du marché a été publié ;
- 3) Dit qu'il ressort des informations sur la procédure que l'évaluation du marché en objet est toujours en cours ;
- 4) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable au regard des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics et ordonne la confiscation de la consignation ;
- 5) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'entreprise KEUR SERIGNE TOUBA, à la commune de Louga ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Les membres du CRD
Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

2.6 – irrecevabilité pour défaut de qualité à agir

A la suite de la publication dans le journal « Le Soleil » du 15 octobre 2014 de l'avis d'attribution provisoire du marché lancé par le PALAM, la société EQUIP PLUS, qui n'était pas soumissionnaire, a saisi l'autorité contractante pour lui demander si ladite attribution se rapporte à l'avis de lancement publié dans le journal « Le Soleil » du 14 mai 2014.

N'ayant pas reçu de réponse, la société EQUIP PLUS a saisi le CRD d'un recours au motif que l'avis de lancement de l'appel d'offres n'est pas conforme et que les prix obtenus dans ces conditions sont trop élevés par rapport à ceux pratiqués dans le marché.

Le CRD, par décision n°307 du 5 novembre 2014, déclara le recours irrecevable en faisant valoir que la société EQUIP PLUS, qui n'était pas soumissionnaire, n'avait pas qualité à agir, mais également que sa contestation intervient après la publication de l'attribution provisoire du marché et vise la publication de l'avis d'appel d'offres.

Cette position du CRD s'appuie sur les dispositions de l'article 89 du code des marchés publics de 2014, en vertu desquelles d'une part le recours à une procédure d'attribution d'un marché n'est ouvert qu'au candidat à la commande publique et que d'autre part les contestations relatives à l'avis d'appel d'offres doivent être soulevées avant la publication de l'attribution provisoire.

**DECISION N° 307/14/ARMP/CRD DU 05 NOVEMBRE 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE EQUIP PLUS CONTESTANT
LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE
DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES, LANCE PAR LE PROGRAMME
D'ALPHABETISATION ET D'APPRENTISSAGE DE METIERS POUR LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE (PALAM)**

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l'entreprise EQUIP PLUS par courrier du 27 octobre 2014 ;

Vu la consignation faite par EQUIP PLUS le 27 octobre 2014 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Khadijetou DIA LY, Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Mame Aïssatou DIENG TRAORE, chef de la Division Appuis Techniques ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par courrier du 27 octobre 2014, la société EQUIP PLUS a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester la procédure de passation du marché relatif à la fourniture de matériels et outillages techniques (Equipements d'allègement et facilités pour la composante 3) pour le PALAM.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public doit préalablement à tout recours contentieux, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu'à la suite de la publication dans le journal « Le Soleil » du 15 octobre 2014 de l'avis d'attribution provisoire du marché relatif à l'acquisition de matériels et outillages techniques, la société EQUIP PLUS a saisi l'autorité contractante pour lui demander de répondre à la question de savoir si ladite attribution se rapporte à l'avis de lancement publié dans le journal « Le Soleil » du 14 mai 2014 ;

Que n'ayant pas reçu de réponse, la société EQUIP PLUS a saisi le Comité de Règlement des Différends en faisant observer que l'avis de lancement de l'appel d'offres n'est pas conforme et que les prix obtenus dans ces conditions sont trop élevés par rapport à ceux pratiqués dans le marché ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'entreprise EQUIP PLUS n'a pas acquis le dossier d'appel d'offres et n'a pas déposé d'offres ;

Qu'à cet égard, le requérant n'a pas qualité à agir par l'introduction d'un recours pour contester une procédure à laquelle il n'a pas participé.

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable et d'ordonner la confiscation de la consignation.

PAR CES MOTIFS:

- 1) Constate que la contestation d'EQUIP PLUS intervient après la publication de l'attribution provisoire du marché et vise la publication de l'avis d'appel d'offres, jugé non conforme;
- 2) Constate qu'Equip Plus n'a ni acquis le dossier d'appel d'offres, ni soumis une offre ;
- 3) Dit que le requérant n'a pas qualité à agir dans le cadre de la procédure ;
- 4) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable ;
- 5) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 6) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à l'entreprise EQUIP PLUS, au Programme d'Alphabétisation et d'Apprentissage de Métiers pour la Lutte contre la Pauvreté (PALAM) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP **Les membres du CRD**
Boubacar MAR **Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

2.7 – irrecevabilité pour non production de document prouvant l'allégation

Par courrier enregistré le 24 avril 2014 au CRD, le cabinet d'avocats « François Sarr et Associés », agissant pour le compte de la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT), a allégué que la société nationale du Port Autonome de Dakar (PAD) a concédé à la société NECOTRANS un périmètre de son domaine portuaire au môle 8 et qu'une telle décision risque de porter préjudice à sa cliente.

Le cabinet d'avocats a joint à sa requête l'autorisation n°0009/PAD/DG/REP du 6 mars 2007 autorisant la SSPT à occuper le domaine portuaire en zone nord sous douane, mais n'a joint ni un document du PAD relatif à la révocation de ladite autorisation, ni un document prouvant qu'un périmètre de son domaine portuaire a été concédé à NECOTRANS.

Par décision n°122 du 7 mai 2014, le CRD déclara son recours irrecevable parce qu'il n'a produit aucun acte portant révocation de son titre d'occupation, de nature à permettre au CRD de statuer sur le mérite de sa requête, en vertu des articles 20 et 21 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

**DECISION N° 122/14/ARMP/CRD DU 07 MAI 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE SENEGALAISE DES
PHOSPHATE DE THIES CONTESTANT L'ATTRIBUTION PAR LE PORT AUTONOME
DE DAKAR DE LA CONCESSION DU TERMINAL VRAQUIER DU MOLE 8 AU GROUPE
NECOTRANS**

29

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du cabinet d'avocats « FRANCOIS SARR & Associés » du 22 avril 2014, enregistré 24 avril 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 114/14, agissant pour le compte de la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) ;

Vu la consignation faite par le cabinet d'avocats en date du 24 avril 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Khadijetou Dia LY, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes ; Moussa DIAGNE, Chef de

la Division Formation, Baye Samba DIOP, Chef de la Division Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination, observateurs ;

Par courrier du 22 avril 2014, enregistré le 24 avril 2014 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 114/14, le cabinet d'avocats « François SARR & Associés », agissant pour le compte de la Société sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) a saisi le CRD pour contester l'attribution de la concession du terminal vraquier du môle 8 au groupe NECOTRANS par le Port autonome de Dakar(PAD).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'au sens de l'article 20 et 21 du décret portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, le CRD peut être saisi de toutes dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toutes autres personnes avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics ou délégations de services publics, de même que toutes contestations ayant pour objet :

- les décisions d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation ;
- les conditions de publication des avis ;
- les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ;
- la conformité des documents d'appels d'offres à la réglementation ;
- les spécifications techniques retenues ;
- les critères d'évaluation.

Considérant que le cabinet d'avocats dans sa requête allègue « qu'il est revenu à la SSPT » que la société nationale du Port Autonome de Dakar a concédé à la société NECOTRANS un périmètre de son domaine portuaire au môle 8, alors que sa cliente est titulaire depuis mars 2007 d'une autorisation d'occupation domaniale d'une partie du même domaine aujourd'hui concédée à NECOTRANS ;

Que le requérant estime que la mise en œuvre d'une telle décision risque de porter un préjudice à sa cliente au regard du montant important des investissements consentis par cette dernière durant les cinq dernières années, d'autant plus que la procédure d'attribution de la concession à NECOTRANS paraît irrégulière ;

Considérant toutefois, qu'à l'appui de sa requête, le cabinet d'avocats a joint l'autorisation N° 0009/ PAD/DG/REP du 06 mars 2007, assortie du cahier des charges portant autorisation accordée à la SSPT pour l'occupation du domaine portuaire en zone nord sous douane, sans pour autant joindre un document émanant du PAD lui notifiant la révocation de ladite autorisation ;

Considérant qu'il est de principe qu'un requérant ne peut saisir le CRD que d'un acte qui lui fait grief ;

Que, parmi les pièces produites, le requérant titulaire d'une autorisation d'occupation n'a produit aucun acte portant révocation de son titre d'occupation de nature à permettre au CRD de statuer sur le mérite de sa saisine ;

Qu'ainsi, le requérant n'ayant pas respecté les règles de formes imposées par la réglementation, il y a lieu de déclarer la saisine irrecevable ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 6) Constate que le cabinet d'avocats « François SARR & Associés » allègue que le domaine portuaire en zone nord sous douane qui lui était attribué depuis mars 2007 fait partie du domaine portuaire concédé au groupe NECOTRANS ;
- 7) Dit que le requérant n'a pas joint dans sa requête un document prouvant ses allégations ;
- 8) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable et ordonne la confiscation de la consignation ;
- 9) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au cabinet d'avocats « François SARR & Associés », au Port Autonome de Dakar ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

2.8 - irrecevabilité pour absence de grief

Suite au marché lancé par la direction de la cinématographie, la société TAF PRODUCTION AFRIQUE, après avoir attendu quinze jours, à partir de la séance d'ouverture des plis sans aucune information sur l'attribution provisoire, a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux auquel cette dernière n'a donné aucune réponse. La société saisit alors le CRD pour contester l'évaluation technique et la non publication de l'attribution provisoire du marché.

Par décision n°297 du 29 octobre 2014, le CRD déclara le recours irrecevable au motif qu'il a été initié par la requérante en dehors de tout acte lui faisant grief, parce que la preuve de l'attribution provisoire du marché n'a pas été rapportée.

Cette décision du CRD se fonde sur les dispositions des articles 89 et 90 du code de 2014 en vertu desquelles le recours n'est recevable que si, entre autres, le candidat invoque une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics.

**DECISION N° 297/14/ARMP/CRD DU 29 OCTOBRE 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES PORTANT SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TAF PRODUCTION
AFRIQUE RELATIF A L'ATTRIBUTION DU MARCHE « ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SECTEUR
DU CINEMA SENEGALAIS ET L'ELABORATION D'UN PLAN STRATEGIQUE QUINQUENNAL
DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL (2016-2020) (PAICA) »,
LANCE PAR LA DIRECTION DE LA CINEMATOGRAPHIE.**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société TAF PRODUCTION AFRIQUE ;

Vu la quittance de consignation 22 octobre 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Ndèye Siga FAYE GUEYE, Directeur des Services administratif et financier, assurant l'intérim du Directeur général de l'ARMP absent, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Mame Aïssatou DIENG TRAORE, chef de la Division des Appuis techniques, Khadijetou DIA LY, Chargée d'Enquêtes et Takia Nafissatou Carvalho FALL, Conseillère chargée du de la Coordination et du Suivi ;

Messieurs Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation et Ousseynou CISSE, Chargé des enquêtes au niveau de la Cellule Enquête et Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 22 octobre 2014, enregistrée le même jour au bureau du courrier puis le 23 octobre au Secrétariat du CRD sous le numéro 295/14, la société TAF PRODUCTION AFRIQUE a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l'évaluation technique et la non publication de l'attribution provisoire du marché susvisé.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public peut saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel d'offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant la réponse de l'autorité contractante ou l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables qui lui est imparti pour répondre ;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction que, après avoir attendu quinze (15) jours à partir de la séance d'ouverture des plis sans aucune information sur l'attribution ou la non attribution du marché, le requérant, par lettre du 13 octobre 2014, a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux auquel cette dernière n'a donné aucune réponse ;

Que, le requérant, par correspondance du 22 octobre 2014 susvisée, a introduit auprès du CRD une requête pour arbitrage ;

Considérant qu'en l'espèce, les deux recours ont été exercés sans qu'il soit fait la preuve d'une décision d'attribution provisoire du marché par l'autorité contractante ;

Qu'ainsi, le requérant a fait usage de son droit de recours en dehors de tout acte lui faisant grief ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la recours irrecevable ;

Qu'en outre, le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS:

- 1) Constate que le recours de la société TAF PRODUCTION AFRIQUE est introduit à l'absence d'un acte lui faisant grief ;
- 2) Déclare, en conséquent, le recours irrecevable ;
- 3) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 4) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la société TAF PRODUCTION AFRIQUE, à la Direction de la Cinématographie du Ministère de la Culture et de la Communication ainsi qu'à la Direction Centrale des Marchés Publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA**

**Pour Le Directeur Général, par intérim
Rapporteur
Le Directeur des Services administratif et financier**

2.9 – irrecevabilité pour non-paiement de consignation

En vertu de l'article 90, deuxième alinéa, « le recours du candidat à une procédure d'attribution n'est recevable que s'il invoque une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagné de la pièce attestant du paiement d'une consignation dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances. »

Le non-paiement d'une consignation entraîne donc l'irrecevabilité du recours.

**DECISION N° 010/15/ARMP/CRD DU 14 JANVIER 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA 7 VISION CONTESTANT LA
PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE LANCE PAR LA SN HLM POUR LES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE 3 400 VILLAS A DIAMNIADIO**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société 7 VISION par courrier du 24 décembre 2015 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par courrier du 24 décembre 2014, la société 7 VISION a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester la procédure de passation du marché relatif aux travaux d'aménagement et de construction de 3 400 villas à Diamniadio, lancé par la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l'affirmative, ordonne à l'autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, que tout candidat à un marché public doit préalablement à tout recours contentieux, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu'il apparaît de l'instruction qu'après la publication dans le journal « Le Soleil » du 06 novembre 2015 de l'avis d'appel d'offres lancé par la SN HLM pour les travaux d'aménagement et de construction de 3400 villas à Diamniadio, la société 7 VISION, ayant reçu le dossier d'appel d'offres le 10 décembre 2014, a saisi l'autorité contractante d'une lettre datée du 19 décembre 2014 ayant pour objet la demande de report de la date d'ouverture des plis, puis, le CRD d'un « recours » introduit par correspondance du 24 décembre 2014 ;

Qu'ainsi, la saisine du CRD ne répond pas aux prescriptions du Code des Marchés publics puisque le requérant devrait préalablement saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux exercé au plus tard le 18 décembre 2014 en lieu et place d'une lettre du 19 décembre 2014 ayant pour objet la demande de report de la date d'ouverture des plis;

Qu'en outre, la saisine du CRD n'a pas été accompagnée de la pièce attestant du paiement d'une consignation ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.

35

PAR CES MOTIFS:

- 1) Constate que la saisine de 7 VISION survient après une lettre du 19 décembre 2014 adressée à la SN HLM ayant pour objet la demande de report de la date d'ouverture des plis ;
- 2) Constate que 7 VISION n'a pas accompagné sa saisine de la pièce attestant du paiement d'une consignation ;
- 3) Dit que 7VISION devrait saisir, au préalable, l'autorité contractante d'un recours gracieux au plus tard le 18 décembre 2014 avant de porter sa contestation au CRD dans le délai réglementaire ;
- 4) Déclare, en conséquence, le recours irrecevable ;
- 5) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à l'entreprise 7 VISION, à la Direction générale de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

Le paiement d'une consignation est une nouveauté du code de 2014, permettant, entre autres, de décourager les recours fantaisistes.

2.10 – irrecevabilité pour irrespect du délai de saisine de l'autorité contractante

En vertu de l'article 89 du code des marchés publics de 2014, le retour gracieux auprès de l'autorité contractante doit intervenir dans un délai de cinq jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence.

Donc est irrecevable le recours exercé après l'expiration dudit délai.

DECISION N° 348/15/ARMP/CRD DU 02 DECEMBRE 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD) STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DISMAT CONTESTANT LE REJET DE SON OFFRE, DANS LE CADRE DU MARCHE NUMERO F_DG_003 RELATIF AUX FOURNITURES DE BUREAU, LANCE PAR LE PORT AUTONOME DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours contentieux de la société DISMAT, par lettre datée du 18 novembre 2015, reçu le 19 à l'ARMP, et enregistrée au secrétariat du CRD sous le numéro 324 ;

Vu la quittance de consignation numéro 100012015002306 du 19 novembre 2015 ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Catherine Aïssata BA, Commissaire à la Cellule d'instruction des Recours, présentant les moyens et demandes des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Khadijatou Dia LY assurant l'intérim du Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assistée par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la Régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par courrier daté du 18 novembre 2015, reçu le lendemain à l'ARMP et enregistré au secrétariat du CRD sous le numéro 324/CRD, la société DISMAT a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester le rejet de son offre dans le cadre du marché numéro F_DG_003 relatif aux fournitures de bureau, lancé par le Port Autonome de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, tout candidat à un marché public doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir l'autorité contractante d'un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, et le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la réponse de l'autorité contractante ou de l'expiration du délai de trois (3) jours ouvrables imparti à l'autorité contractante pour répondre ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que l'avis d'attribution provisoire a été publié dans le quotidien « Le Soleil » du 29 octobre 2015 ;

Considérant que la société DISMAT a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux par lettre datée du 13 novembre 2015 reçue le même jour, puis le CRD d'un recours contentieux, par lettre datée du 18 novembre 2015, reçue le lendemain ;

Considérant que par correspondance datée du 16 novembre 2015, adressée au requérant, le Port Autonome de Dakar, autorité contractante, a soulevé le caractère irrecevable du recours gracieux, pour tardiveté ;

Considérant qu'au regard des dispositions de l'article 89 du Code des Marchés publics, le recours gracieux auprès de l'autorité contractante doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire ;

Considérant, dès lors, que la date de publication de l'avis d'attribution provisoire est la référence pour computer les délais de saisine de l'autorité contractante ;

Considérant, dès lors, qu'en l'espèce, le recours gracieux auprès de l'autorité contractante devait intervenir dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché effectuée le 29 octobre 2015, soit au plus tard le 06 novembre 2015 ;

Considérant, toutefois, que le recours gracieux a été soumis à l'autorité contractante le 13 novembre 2015, soit après le délai prescrit par l'article 89, et qu'il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;

Considérant que le recours contentieux introduit devant le CRD le 19 novembre 2015 est, en conséquence, irrecevable ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que l'avis d'attribution provisoire du marché a été publié dans le quotidien « Le Soleil » du 29 octobre 2015 ;
- 2) Constate que la société DISMAT a saisi, le Port Autonome de Dakar d'un recours gracieux, par lettre datée du 13 novembre 2015 ;

- 3) Constate que, par lettre datée du 16 novembre 2015, l'autorité contractante, se fondant sur les dispositions de l'article 89 du Code des Marchés publics, a soulevé le caractère irrecevable du recours gracieux pour tardiveté ;
- 4) Dit qu'au regard des dispositions de l'article 89 du Code des Marchés publics, le recours gracieux doit être exercé dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire ;
- 5) Dit que la date de publication de l'avis d'attribution provisoire est la référence pour computer les délais de saisine de l'autorité contractante ;
- 6) Dit que le recours gracieux, introduit le 13 novembre 2015, doit être déclaré irrecevable, pour violation des dispositions de l'article 89 du Code des Marchés publics ;
- 7) Dit que le recours n'a pas respecté les conditions fixées par l'article 90 du Code des Marchés publics ;
- 8) Dit, en conséquence, que le recours contentieux est irrecevable ;
- 9) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 10) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société DISMAT, au Port Autonome de Dakar (PAD) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

**Pour le Directeur général, par intérim,
Rapporteur
Khadijetou Dia LY**

3

**AFFIRMATION, NON PROUVEE, DE
L'INEXISTENCE D'UNE PIECE AU MOMENT
DE L'OUVERTURE DES PLIS ET ABSENCE
D'INTERDICTION A DES SOCIETES
DIFFERENTES DE SOUMISSIONNER LES
MEMES PRODUITS A DES PRIX DIFFERENTS**

En vertu de l'article 44 du Code des Marchés publics de 2014, les documents administratifs et ceux liés à la qualification non fournis ou incomplets sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire.

Donc, n'est pas fondé l'argument du candidat selon lequel l'attributaire provisoire n'avait pas fourni l'autorisation du fabricant à l'ouverture des plis, d'autant plus que le procès-verbal d'ouverture des plis ne mentionne pas cette inexistence.

Suite à l'appel d'offres international lancé par la Pharmacie nationale d'Approvisionnement (PNA) le 6 janvier 2014, les séances d'ouverture des plis ont eu lieu du 08 au 16 avril 2014 et les articles 415, 416 et 417 ont été attribués provisoirement au candidat CARREFOUR MEDICAL, suite à l'évaluation des offres.

Le cabinet d'avocats « Mame Adama Gueye et Associés » agissant pour l'Entreprise Sénégalaise de Représentation (ESR), saisit alors l'autorité contractante pour contester le rejet de l'offre de son client. Insatisfait de la réponse de ladite autorité, le cabinet introduit un recours auprès du CRD aux motifs que d'une part l'attributaire provisoire a présenté l'autorisation du fabricant postérieurement à l'ouverture des plis et que d'autre part CARREFOUR MEDICAL a proposé les mêmes produits que le candidat AFRIMED mais à des prix différents, violant ainsi, selon lui, les principes d'égalité de traitement des candidats et d'équité.

Après avoir ordonné la suspension provisoire de la procédure de passation par décision n°351 du 24 décembre 2014 et réclamé les documents nécessaires à l'instruction, par décision n°16 du 21 janvier 2015, le CRD déclara la décision de la commission des marchés justifiée et le recours d'ESR non fondé aux motifs que :

- 1) Le grief, selon lequel l'autorisation du fabricant FUJIFILM n'était ni dans l'offre d'AFRIMED ni dans celle de CARREFOUR MEDICAL, n'est pas fondé, parce que non seulement le procès-verbal d'ouverture des plis n'a pas mentionné cela, alors que l'examen de l'offre de ces deux soumissionnaires fait ressortir, contrairement aux affirmations des requérants, l'existence d'une autorisation du fabricant FUJIFILM Belgique signée le 21 février 2014 pour AFRIMED et celle du fabricant FUJIFILM Maroc délivrée le 12 février 2014 pour CARREFOUR MEDICAL, mais également ces deux autorisations sont confirmées par une autre du 17 juillet 2014 envoyée par la maison mère du fabricant basée au Japon ; que l'article 44 du code des marchés publics de 2014 dispose que les documents administratifs et ceux liés à la qualification non fournis ou incomplets sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire ;
- 2) L'argument, selon lequel les soumissionnaires AFRIMED et CARREFOUR MEDICAL ont proposé pour les articles 415, 416 et 417 les mêmes produits de marque FUJIFILM mais à des prix différents, n'est pas pertinent, parce que d'une part, non seulement un même fabricant peut délivrer à plusieurs fournisseurs des autorisations de fabricant pour assurer la commercialisation de ses produits, mais également aucun texte réglementaire n'interdit à des sociétés différentes de soumissionner en proposant des produits d'une même marque tout en présentant individuellement l'autorisation du fabricant ; que d'autre part, les prix, constituant un élément de concurrence, sont librement fixés par les candidats.

**DECISION N° 016/15/ARMP/CRD DU 21 JANVIER 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ENTREPRISE SENEGALAISE
DE REPRESENTATION CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISoire DES ARTICLES 415,
416 ET 417 DANS LE CADRE DU MARCHE LANCE PAR LA PHARMACIE NATIONALE
D'APPROVISIONNEMENT (PNA) POUR LA FOURNITURE DE MEDICAMENTS ESSENTIELS,
MATERIELS ET CONSOMMABLES MEDICO-PHARMACEUTIQUES, DES FILMS
NUMERIQUES, DES KITS DE DIALYSE, DE CATARACTE, D'ACCOUCHEMENT ET DE
CESARIENNE, DES REACTIFS DE LABORATOIRES, VACCINS, PRODUITS DENTAIREs**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours, en date du 15 décembre 2014 de l'Entreprise Sénégalaise de Représentation (E.S.R.) par le biais de la société civile professionnelle d'avocats Mame Adama Guèye & Associés ;

Vu la consignation faite par ladite société civile professionnelle d'avocats ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;
Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ;
Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 15 décembre 2014, reçue le lendemain, l'Entreprise Sénégalaise de Représentation (ESR), par le biais de la société civile professionnelle d'avocats « Mame Adama Guèye & Associés » a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester l'attribution provisoire des articles 415, 416 et 417 portant sur des films radios et des films numériques dans le cadre de l'appel d'offres international lancé par la Pharmacie nationale d'Approvisionnement (PNA).

LES FAITS

Dans le cadre de son budget de fonctionnement, la PNA a lancé un appel d'offres international pour l'acquisition de médicaments, matériels et consommables médico-pharmaceutiques. A ce titre, elle a fait publier l'avis d'appel d'offres dans le journal « Le Soleil » du 06 janvier 2014 et dans l'hebdomadaire « Jeune Afrique » du 5 au 11 janvier 2014 pour sélectionner les fournisseurs.

A l'ouverture des plis, 147 offres ont été reçues.

Au terme de l'évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d'attribuer les articles 415, 416 et 417, correspondant respectivement aux films radio 20x40+intercalaire, aux films numériques 8x10, 10x12, 11x14, 14x14, 14x17 et aux films numériques 8x10 mammographie, au candidat CARREFOUR MEDICAL dont les offres ont été jugées conformes, évaluées moins-disantes et remplissant les critères de qualification requis.

Dès qu'il a pris connaissance des résultats de l'attribution provisoire, le cabinet d'avocats Mame Adama Guèye & Associés, conseil de l'Entreprise Sénégalaise de représentation, a saisi l'autorité contractante pour contester le rejet de l'offre de son client pour les articles 415, 416 et 417 par lettre du 08 décembre 2014.

Non satisfaite de la réponse reçue de l'autorité contractante, le 12 décembre 2014, le requérant a porté sa réclamation devant le CRD par courrier du 15 décembre 2014.

Par décision n° 351/14 du 24 décembre 2014, le CRD a jugé le recours de l'E.S.R. recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation et saisi l'autorité contractante pour disposer des documents nécessaires à l'instruction.

Suivant courrier du 31 décembre 2014, reçu le 05 janvier 2015, puis complété par des éléments reçus le 16 janvier 2015, la PNA a transmis à l'ARMP les pièces demandées.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS.

A l'appui de son recours, le requérant déclare qu'à l'ouverture des plis, deux soumissionnaires, en l'occurrence AFRIMED et CARREFOUR MEDICAL, avaient proposé les mêmes produits provenant du fabricant FUJIFILM, en ce qui concerne les articles 415, 416 et 417. Il informe que ces produits de même marque, bien qu'identiques, avaient été proposés avec des prix différents. Sur ce point, il affirme que contrairement à la réponse donnée par la PNA, aucune disposition du Code des Marchés publics ne permet à un fabricant d'être représenté par deux candidats. De son point de vue, une telle situation constitue une entorse aux principes de concurrence, d'égalité de traitement des candidats, et d'équité.

Il affirme, en outre, qu'au moment de l'ouverture des plis, aucune de ces deux structures n'avait produit l'autorisation du fabricant comme requis dans le dossier d'appel à la concurrence. Il déclare, à ce sujet, que l'attributaire provisoire du marché, CARREFOUR MEDICAL, n'a fourni ledit document qu'un mois après, en violation manifeste du délai prévu en la matière, dénotant une démarche frauduleuse. Il explique, en effet, que le fabricant FUJIFILM s'était gardé, au départ, de fournir aux sociétés qui proposaient sa marque une autorisation, pour attendre l'ouverture des plis et identifier celle qui était la mieux placée pour être attributaire provisoire. C'est pourquoi, expose le requérant, le fabricant, poursuivant sa logique, a finalement délivré à CARREFOUR MEDICAL ledit document.

Le requérant soutient que cette manœuvre frauduleuse fausse les principes d'égalité et de libre concurrence et ne résulte pas de l'article 70 du Code des Marchés publics qui dispose que les pièces administratives et autres justificatifs de qualification d'un candidat peuvent être complétés jusqu'à l'attribution provisoire.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs soulevés par le requérant, la PNA soutient qu'à sa connaissance, aucune disposition du Code des Marchés publics n'interdit à différentes sociétés, de droits sénégalais ou étranger, ayant des personnalités juridiques distinctes et ne faisant pas partie d'un même groupement d'entreprises, de soumissionner à un appel d'offres avec les produits d'un même fabricant. Elle ajoute que chaque fabricant est libre de délivrer des autorisations à plusieurs représentants.

A ce propos, l'autorité contractante rappelle que, lors des séances d'ouvertures des plis qui se sont tenues du 08 au 16 avril 2014, la commission des marchés a procédé à une lecture à haute et intelligible voix, de la liste des pièces administratives fournies par les soumissionnaires et d'autres documents notamment la garantie de soumission. Elle affirme, toutefois, que la présence ou non des autorisations des fabricants dans les offres des soumissionnaires n'a pas fait l'objet de vérification à ce stade de la procédure, contrairement aux affirmations du requérant.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien fondé de l'attribution provisoire des articles 415, 416 et 417 à CARREFOUR MEDICAL qui aurait d'une part, présenté l'autorisation du fabricant postérieurement à l'ouverture des plis, et, d'autre part proposé les mêmes produits qu'un autre soumissionnaire mais à des prix différents.

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l'article 44 du Code des Marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Qu'en application de l'article susmentionné, l'autorité contractante a exigé des soumissionnaires, au niveau de la clause IC 18.1a des Données particulières de l'appel d'offres (DPAO) qu'ils présentent l'autorisation du fabricant conformément au modèle joint au Dossier d'appel d'offres ;

Considérant que le requérant reproche à l'autorité contractante d'avoir attribué les articles 415, 416 et 417 à CARREFOUR MEDICAL qui a proposé pour les articles précités, les mêmes produits de marque FUJIFILM que le soumissionnaire AFRIMED, mais à des prix différents, violant ainsi, de l'avis du requérant, les principes d'égalité de traitement des candidats et d'équité;

Considérant que l'exigence de l'autorisation du fabricant, requis au niveau des critères de qualification du DAO en objet, vise à prémunir l'autorité contractante contre les risques de malfaçon et permet d'obtenir l'assurance que les articles proposés ont la qualité requise et sont des produits d'origine ;

Que pour assurer la commercialisation de ses produits, un même fabricant peut délivrer à plusieurs fournisseurs des autorisations de fabricant ;

Qu'au demeurant, aucun texte réglementaire n'interdit à des sociétés avec des formes juridiques distinctes de soumissionner en proposant les produits d'une même marque tout en présentant individuellement l'autorisation du fabricant délivrée par qui de droit ;

Considérant par ailleurs, que le requérant fait observer, qu'à l'ouverture des plis l'autorisation du fabricant FUJIFILM, n'était ni incluse dans l'offre du soumissionnaire AFRIMED, encore moins dans celle de CARREFOUR MEDICAL et n'a été produite par le dernier nommé qu'un mois après la date d'ouverture des plis , en violation manifeste du délai prévu en la matière ;

Considérant que l'examen du procès-verbal d'ouverture des plis n'a pas permis de corroborer cette affirmation, puisqu'aucune mention relative à la présence ou à l'absence de ce document n'y figure ;

Qu'en outre, l'examen de l'offre de AFRIMED fait ressortir, contrairement aux affirmations du requérant, l'existence d'une autorisation du fabricant FUJIFILM Belgique signée le 21 février 2014, tandis que celle de CARREFOUR MEDICAL révèle la présence de l'autorisation du fabricant FUJIFILM, délivrée le 12 février 2014 et signée par le Directeur général du bureau de la représentation du Maroc ;

Considérant par ailleurs, que le dossier transmis par la PNA, révèle la présence d'une attestation datée du 17 juillet 2014 et envoyée par la maison mère du fabricant FUJIFILM, basée au Japon et confirmant l'autorisation du fabricant délivrée par le bureau de représentation du Maroc ;

Qu'en tout état de cause, l'article 44 du Code des Marchés publics dispose que les documents administratifs et ceux liés à la qualification non fournis ou incomplets sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire ;

Qu'à cet égard, la décision de la commission des marchés est justifiée ;

Que s'agissant de la différence de prix constatée sur les produits proposés, il est de principe que lesdits prix constituent un élément de concurrence et sont librement fixés par les candidats en prenant en compte plusieurs paramètres notamment les charges, et la marge bénéficiaire de leurs entreprises, qui ne sont pas identiques d'une entité à une autre ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les griefs du requérant ne sont pas fondés ;

Qu'en conséquence la décision de la commission des marchés de la PNA d'attribuer les articles 415,416 et 417 à la société CARREFOUR MEDICAL qui est le candidat ayant soumis l'offre conforme évaluée la moins-disante et remplissant les critères de qualification requis, est justifiée ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de poursuivre la procédure pour les articles précités ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il convient de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que le requérant reproche à l'autorité contractante d'avoir attribué les articles 415, 416 et 417 à Carrefour Médical qui a proposé les mêmes produits de la marque FUJIFILM que le candidat AFRIMED mais à des prix différents ;
- 2) Constate que le requérant dénonce également la production tardive de l'autorisation du fabricant par CARREFOUR MEDICAL ;
- 3) Dit qu'aucun texte réglementaire n'interdit à deux soumissionnaires distincts de proposer les produits d'une même marque ;
- 4) Dit que le prix est un élément de concurrence et est, à ce titre, librement fixé par les candidats ;
- 5) Constate que les autorisations du fabricant FUJI FILM respectivement délivrées par les bureaux du Maroc et de la Belgique figurent dans les différentes offres de CARREFOUR MEDICAL et AFRIMED, contrairement aux allégations du requérant ;

- 6) Dit que la maison-mère FUJIFILM basée au Japon a confirmé l'autorisation du fabricant délivrée à CARREFOUR MEDICAL ;
- 7) Constate que l'autorisation du fabricant fait parti des documents devant attester de la qualification des candidats dans le cadre de cet appel d'offres ;
- 8) Dit que les documents liés à la qualification sont exigibles dans un délai égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire du marché, au regard de l'article 44 du Code des Marchés publics ;
- 9) Dit, en conséquence, que la décision de la commission des marchés d'attribuer les articles 415, 416 et 417 à CARREFOUR MEDICAL est justifiée ;
- 10) Ordonne, en conséquence la confiscation de la consignation et la poursuite de la procédure ;
- 11) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'Entreprise Sénégalaise de Représentation par le biais du cabinet d'avocats Mame Adama Guèye, à la Pharmacie nationale d'Approvisionnement ainsi qu'à la Direction centrale des marchés publics la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP **Les membres du CRD**
Boubacar MAR **Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

4

**OBLIGATION POUR LE GROUPEMENT
SOUSSIONNAIRE DE LISTER SUR LA
GARANTIE DE SOUMISSION TOUS LES
MEMBRES DUDIT GROUPEMENT**

Suite à l'appel d'offres international lancé par le Projet de coordination des Réformes Budgétaires et Financières (PCRBF) pour l'acquisition et la mise en œuvre d'un Système électronique intégré de Gestion de l'Information financière (SIGIF), le marché a été attribué provisoirement au groupe ATOS INTEGRATION-BEARING-POINT-ADETEF-GSIE.

Le recours gracieux initié par les groupements CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU-KPGM Sénégal, NOVABASE-SIL et la société IB MAROC-COM ayant été rejeté par l'autorité contractante le 08 septembre 2015, ces trois soumissionnaires saisissent le CRD par lettres reçues les 9 et 10 septembre 2015 pour contester l'attribution provisoire.

Par décision n°298 du 14 octobre 2015, le CRD rejette les recours en faisant valoir, entre autres, que le rejet des offres de CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU-KPGM et NOVABASE-SIL est fondé parce que leurs garanties financières ne sont pas conformes aux spécifications de la clause 29.3 des IS, dans la mesure où d'une part, CATALYST a utilisé les références d'INFOYS LIMITED en tant que membre du groupement pour être qualifié alors que la garantie de soumission produite par ECOBANK et l'attestation de main levée de la garantie ne visent pas INFOYS LIMITED présenté comme membre du groupement dans l'offre technique, mais également, même si la garantie de soumission était conforme, la combinaison des notes techniques et financières de CATALYST ne le classerait pas moins-disant ; que d'autre part NOVABASE a produit une garantie de soumission de la SGBS ne visant pas SIL en tant que membre du groupement.

**DECISION N° 298/15/ARMP/CRD DU 14 OCTOBRE 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LES RECOURS DE CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU/
KPGM, NOVA BASE ET IB MAROC.COM RELATIF A L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
NO : F_PCRBF_PARFP_SIGIF_582PORTANT SUR L'ACQUISITION ET LA MISE EN ŒUVRE
D'UN SYSTEME ELECTRONIQUE DE GESTION DE L'INFORMATIQUE FINANCIERE,
IMPLEMENTATION CLE EN MAIN DES MODULES DE LA SOLUTION SIGIF, LANCE PAR LE
PROJET DE COORDINATION DES REFORMES BUDGETAIRES ET FINANCIERES (PCRBF)**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu la loi no 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu les recours de CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU/KPGM, de NOVABASE et d'IB MAROC.COM datés respectivement du 10 et 11 septembre 2015 et enregistrés au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous les numéros 159/15, 161/15 et 162/15 ;

Vu les consignations faites par CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU/KPGM, de NOVABASE et d'IB MAROC.COM des 9 et 10 septembre 2015 ;

Monsieur Moustapha NGAIDO, Commissaire à la Cellule d'Instruction des Recours, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar

MAR et Cheikhou Issa SYLLA ; membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Par lettres reçues les 9 et 10 septembre 2015, les Groupements CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM Sénégal, NOVABASE/SIL et la Société IB MAROC.COM ont saisi le CRD en contestation de l'attribution provisoire du marché relatif à l'appel d'offres international n° : F_PCRBF_PARFP_SIGIF_582 portant sur l'acquisition et la mise en œuvre d'un Système électronique intégré de Gestion de l'Information financière, Implémentation clé en main des modules de la solution SIGIF, lancé par le Projet de Coordination des Réformes budgétaires et financières (PCRBF).

SUR LA JONCTION DES REQUETES

Considérant que les trois requêtes relatives à l'attribution provisoire du marché susvisé portent sur des faits similaires et soulèvent différents points de droit identiques ;
Qu'ainsi, il y a lieu, pour une bonne administration de ces procédures, d'ordonner la jonction desdits recours pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision.

LES FAITS

Suite à l'Avis général de passation de marché paru dans Développement Business, noWB4007-07/14 du 31 juillet 2014, le PCRBF a fait publier, un avis d'appel d'offres international en deux étapes pour un marché clé en main relatif à l'acquisition et à la mise en œuvre d'un Système électronique intégré de Gestion de l'Information financière, Implémentation clé en main des modules de la solution SIGIF dans les journaux suivants :

- « Le Quotidien », « Le Soleil » du 1er octobre 2014 ;
- l'Hebdomadaire Jeune Afrique no 2804 du 5 au 11 octobre 2014 ;
- CIO MAG n° 033, octobre et novembre 2014.

Une réunion de clarification sur certains aspects du dossier d'appel d'offres a été organisée avec les soumissionnaires intéressés le 30 octobre 2014.

La séance d'ouverture publique des plis et de lecture des pièces administratives de la première étape a eu lieu le 1er décembre 2014, sous la supervision de la Commission des Marchés du Ministère de l'Economie des Finances et du Plan (MEFP) et sept (7) offres ont été reçues :

1. Groupement ATOS INTEGRATION-BEARING POINT-ADETEF-GSIE (France) ;
2. Groupement SNDI-SOCITECH-E-SUD (Côte d'Ivoire) ;
3. Groupement CATALYST-KPGM-INFOSYS (Sénégal) ;
4. Groupement NOVABASE-SIL (Portugal) ;
5. Groupement CFAO-CACIOPEE (Sénégal) ;
6. Groupement IB MAROC-INTRASOFT-BUSINESS APPLICATIONS (Maroc) ;
7. Groupement SIMAC-PLATEFORME TECHNOLOGIES (Tunisie).

Après l'évaluation des offres soumises à la première étape, le comité technique d'évaluation a disqualifié les groupements CFAO-CACIOPE et SIMAC-PLATEFORME TECHNOLOGIES pour absence de références dans le domaine de la mission.

En outre, l'offre du groupement SNDI-SOCITECH, au regard de divergences majeures notées dans la méthodologie, a aussi été écartée.

Ainsi, quatre groupements ont été présélectionnés :

- 1. Groupement ATOS INTEGRATION-BEARING POINT-ADETEF-GSIE ;
- 2. Groupement CATALYST-KPGM-INFOSYS ;
- 3. Groupement NOVABASE-SIL ;
- 4. Groupement IB MAROC-INTRASOFT-BUSINESS APPLICATIONS ;

Par lettre du 8 avril 2015, les quatre groupements ont été invités à soumissionner pour la deuxième étape.

A l'ouverture des plis, le 21 mai 2015, à 10 h45 mn, il a été constaté que les offres suivantes, ont été libellées partiellement en F CFA, en EURO et en dollars américains :

NOM DES GROUPEMENTS	PAYS D'ORIGINE	MONTANTS	OBSERVATIONS
ATOS INTEGRATION/ BERING POINT ADETEF/GSIE TECHNOLOGIE	France	423 874 807 CFA 11 195 907 EUROS	Pas de précisions pour les taxes
CATALYST/KPGM/ INFOSYS LIMITED	Sénégal	8 413 540 567 FCFA HTVA 3 043 991 462 F CFA HTVA	-
IB MAROC.COM S.A/INFRASOFT INTERNATIONAL/ BUSINESS APPLICATION	Maroc	17 846 282,91 DOLLARS US	Pas de précision pour les taxes
NOVA BASE/SIL	Portugal	1 160 475 987,83 FCFA 7 817 150,73 DOLLARS US 4 648 140,48 EUROS Soit un montant total de FCFA TTC de 13 592 603 126,02	-

Des demandes d'éclaircissements ont été envoyées par ATOS, CATALYST et IB. Maroc.com le 8 juin 2015 et des réponses y ont été apportées le 10 juin 2015.

Sur la base du rapport d'évaluation, établi le 11 juin 2015, le classement suivant est effectué :

SOUSSIONNAIRES	NOTE OFFRE TECHNIQUE	OFFRE FINANCIÈRE (FCFA/HTVA)	NOTE GLOBALE	CLASSEMENT
Groupe ATOS/ BEARING POINT/GSIE TECHNOLOGY/EXPERTISE	75,68 %	7 767 508 565	98,37	1 ^{er}
Groupe CATALYST BUSINESS SOLUTION/ KPGM	77,79%	11 477 820 538	87,07	2 ^{ème}
Groupe IB MAROC/INTRASOFT INTERNATIONAL/ BUSINESS	73,70 %	10 424 192 457	86,65	3 ^{ème}
Groupe NOVA BASE/ SIL	71,39 %	10 306 694 366	85,21	4 ^{ème}

Ces différentes offres financières ont fait l'objet d'une conversion en F CFA conformément au taux de la BCEAO.

Les documents administratifs ont fait l'objet d'un examen le 19 juin 2015 et la Commission des Marchés a rejeté les offres de CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU/KPGM et NOVA BASE pour non-conformité des garanties bancaires.

Un nouveau rapport d'évaluation a été produit le 24 juin 2015 avec le classement définitif suivant :

- 1^{er} ATOS/100 ;
- 2^{ème} IB-MAROC/88,24.

L'avis d'attribution provisoire a fait l'objet d'une publication dans le journal, « Le Soleil » du 4 septembre 2015. Le même jour, le PCRBF a informé CATALYST, NOVABASE et IB MAROC.COM du rejet de leurs offres et de l'attribution provisoire du marché précité au groupe ATOS INTEGRATION/BEARING POINT/EXPERTISE France ex ADETEF/GSIE TECHNOLOGIE (France) pour le montant de 7 767 508 565 F CFA HTVA soit 9 165 660 107 F CFA TTC.

Au vu de cette information, NOVABASE, IBA MAROC et CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM Sénégal, par correspondances datées respectivement des 4,5 et 7 septembre 2015, ont adressé un recours gracieux à l'autorité contractante pour contester le rejet de leur offre et l'attribution provisoire du marché au groupe ATOS INTEGRATION/BEARING POINT/EXPERTISE France ex ADETEF/GSIE TECHNOLOGIE.

Le PCRBF a répondu défavorablement auxdits recours, suivant correspondance reçue par courrier électronique, le 9 septembre 2015, par les trois candidats.

Au regard des réponses de l'autorité contractante contenue dans les courriers électroniques, les soumissionnaires évincés ont introduit auprès du CRD une requête pour dénoncer l'attribution provisoire.

CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM a saisi le CRD, le 9 septembre 2015 par courrier reçu le même jour. NOVA BASE et IB MAROC.COM ont saisi le CRD, le 10 septembre 2015, pour demander, à leur tour, l'annulation de l'attribution provisoire.

Ayant jugé les trois recours recevables, par décision n° 265 du 15 septembre 2015, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité, de l'autorité contractante, la transmission des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.

Par ailleurs, les avis de non-objection ont été obtenus, le 27 août 2015 de la Banque Mondiale et, le 1er septembre 2015, de la DCMP.

Par correspondance du 7 octobre 2015 reçue le même jour à l'ARMP, lesdites pièces ont été communiquées.

LES MOYENS A L'APPUI DES RECOURS

1. GROUPEMENT CATALYST/KPGM Senegal

Au soutien de son recours, le groupement soulève plusieurs points :

- l'autorité contractante reproche au groupement de n'avoir pas listé le partenaire « INFOYS LIMITED » conformément à la Clause 29.3 des Instructions aux Soumissionnaires(IS), alors que l'accord de groupement soumis lors de la première étape de l'appel d'offres spécifie que le groupement engage solidairement CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM Sénégal envers le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan. Mais, pour le soumissionnaire, la société de droit indien « INFOSYS LIMITED » est considérée comme sous-traitant dans l'offre. Ce qui est admis par les Données particulières de l'appel d'offres (DPAO) et le sous-traitant a fourni les mêmes pièces administratives que les membres du groupement conformément aux DPAO ;
- la liste des modifications requises n'ayant pas été produite lors de la seconde étape, CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM estime que le mémorandum approuvé lors de la première étape n'a fait l'objet d'aucune modification ;
- conformément à l'article 25.3 des IS du DAO, l'offre de la première étape sur laquelle repose l'offre de la deuxième étape continue de faire implicitement partie intégrante de l'offre de la deuxième étape ;
- la garantie de soumission qui a été produite concerne uniquement le groupement CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM Sénégal, conformément à l'accord de groupement et l'attestation de main levée a bien précisé que la garantie est au profit du groupement CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU/KPGM Sénégal et ne concerne pas le sous-traitant INFOSYS ;
- les éclaircissements demandés, par l'Autorité Contractante, dans le cadre des travaux d'évaluation de l'offre financière de CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM Sénégal et auxquelles, le groupement a répondu le 8 juin 2015, ne concernent que les offres conformes, pour l'essentiel, et admises pour examen détaillé aux termes de l'article 38.4 des IS du DAO. Par conséquent, CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM Sénégal a estimé que son offre était conforme ;
- enfin pour le requérant, il ne semble pas que les offres du groupement attributaire ont répondu aux exigences du DAO au regard des informations parvenues au groupement CATALYST. Plusieurs manquements substantiels auraient été notés et porteraient notamment sur : les qualifications du personnel clé, la certification de la solution, le site de secours, le transfert de compétences, les métriques et la durée de validité des licences. Ainsi, l'importance de ces manquements fait qu'il ne peut y avoir d'ouverture à négociation avec l'attributaire provisoire.

2. GROUPEMENT NOVABASE/SIL

Ce groupement soutient, au moyen de sa requête, que :

- Il est reproché à son offre d'être non conforme, alors que les autres concurrents n'ont pas respecté les termes du DAO, notamment pour n'avoir pas présenté les offres en HT et TTC, comme l'atteste le Procès-verbal d'ouverture des plis et, le réajustement opéré sur le prix du groupement retenu, constitue un élément de doute sur le vrai prix et ne permet pas de respecter l'équité entre les soumissionnaires et c'est ce qui justifie une revue détaillée des offres financières ;
- Par ailleurs, il est demandé à l'ARMP de vérifier si les soumissionnaires ont respecté les termes du DAO, par rapport notamment aux licences utilisateurs simultanés de SIGIF qui doivent être • Le requérant déclare que si le rejet de leur offre est lié au fait que tous les membres du groupement ne figurent pas dans la lettre de garantie, il a été précisé que NOVA BASE en tant que chef de file prend en charge la garantie bancaire et que son dossier administratif a bien été accepté par le PCRBF ;
- Enfin, le requérant allègue que le souci d'équité aurait exigé que la notification des demandes d'éclaircissement soit aussi transmise à son groupement.

3. IB MAROC.COM

L'entreprise, quant à elle, souhaite obtenir la note attribuée à chaque critère et sous-critère, conformément à l'annexe 5,6 et 7 de l'additif au DAO et le réexamen de toutes les offres.

Au regard de ces éléments, les trois soumissionnaires demandent au CRD de reconsidérer la décision d'attribution provisoire du marché objet du recours.

53

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le PCRBF, sur les griefs du Groupement CATALYST/KPGM, précise que l'offre du groupement n'a pas été retenue, au motif que la garantie déposée ne liste pas le partenaire « INFOYS LIMITED » conformément à la clause 29.3 des IS, Ainsi, cette offre non accompagnée d'une garantie d'offre acceptable, pour l'essentiel, a été écartée comme étant non conforme.

L'autorité contractante ajoute que pour qu'un groupement puisse se qualifier, aussi bien le chef de file que les membres du groupement doivent satisfaire aux critères de qualification minimale relativement aux références fournies, aux pièces justificatives, à l'offre technique, à la garantie de l'offre ou garantie de soumission.

Sur le recours de NOVA BASE, l'AC précise, à nouveau, que d'une part, la garantie de l'offre d'un groupement d'entreprises doit être émise au nom du groupement présentant l'offre en dressant la liste de tous les partenaires du groupement et que d'autre part, l'évaluation des prix a été faite sur la base des montants HTVA conformément à la clause 27.5 des IS du DAO.

S'agissant du recours d'IB Maroc, l'AC relève que les notes ont été attribuées par 4 jurys indépendants selon : la capacité à mener le projet, les exigences fonctionnelles et les exigences techniques. Sur cette base, la note de 88,24/100 a été attribuée à IB MAROC. Par ailleurs, les notes attribuées aux autres candidats ne peuvent être transmises aux concurrents.

En définitive, l'autorité contractante soutient que l'offre de l'attributaire provisoire a été évaluée cumulativement suivant les spécifications techniques, les critères de qualification définis dans le dossier d'appel d'offres et les garanties requises.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur :

1. la conformité des garanties de soumission des groupements CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU/KPGM et de NOVA BASE ;
2. la conformité des prix par rapport au DAO ;
3. les conditions d'évaluation des offres des candidats.

EXAMEN DU LITIGE

1. Sur la conformité des garanties de soumission

Considérant, qu'aux termes de l'article 72.3 du Code des Marchés publics, dans l'appel d'offres en deux étapes, les candidats sont invités à présenter des propositions techniques définitives assorties de prix lors de la deuxième étape, sur la base du dossier d'appel d'offres établi ou révisé par la personne publique en fonction des informations recueillies lors de la première étape de présélection ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 47.1 du Code des Marchés publics, les candidats aux marchés publics peuvent se grouper pour concourir à l'obtention des marchés publics ;

Considérant que la composition du groupement ne peut être modifiée entre la remise des candidatures et la conclusion du marché ;

Considérant que selon la clause 3 de l'IS du DAO, pour qu'un groupement puisse se qualifier, le chef de file et tous les membres du groupement doivent satisfaire aux critères de qualification minimale ; Considérant que le DAO exige du soumissionnaire l'exécution avec succès au cours des dernières dix (10) années au moins deux contrats d'intégration de systèmes dans le cadre de la mise en œuvre d'un Système d'Information de Gestion financière (SIGIF) dans le secteur public en tant que chef de file ou membre d'un groupement pour des montants supérieurs à 5 millions de dollars américains, soit la contre-valeur de 2,5 milliards F CFA ;

Considérant, toutefois, que le groupement CATALYST BUSINESS SOLUTION SAU/KPGM a inclus dans son offre les références de la Société INFOYS LIMITED qui n'est pas membre du groupement, comme l'atteste le courrier du représentant d'INFOYS LIMITED en date du 26 novembre 2014 agissant en qualité de sous-traitant ;

Considérant par ailleurs, que la garantie de soumission n° 155/2015 du 12 mai 2015 produite par ECOBANK et l'attestation de main levée de la garantie ne visent pas INFOYS LIMITED, alors qu'il a été présenté explicitement comme membre du groupement dans l'offre technique ; Considérant que le groupement, dont le chef de file est CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM, a utilisé les références d'INFOYS LIMITED en tant que membre du groupement pour être qualifié ;

Considérant que, dans ces conditions et conformément à la Clause 29.3 des IS, la garantie d'offre du groupement d'entreprises qui correspond à la garantie de soumission aurait dû être émise au nom du groupement présentant l'offre sans omettre de dresser la liste de tous les membres dudit groupement d'entreprises ;

Qu'ainsi, la décision d'écarter le groupement CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM Sénégal, qui n'a pas listé INFOYS LIMITED en tant que membre du groupement dans la garantie de soumission, est fondée ;

Considérant, au surplus, que l'offre de CATALYST BUSINESS SOLUTIONS n'est par ailleurs, pas la plus avantageuse au plan économique et même qu'en supposant que sa garantie de soumission soit conforme, la combinaison des notes techniques et financières ne classerait pas ce groupement moins-disant, donc en définitive, le rejet de ladite offre est largement justifié ;

Considérant, par ailleurs, que NOVA BASE BUSINESS SOLUTIONS a produit une garantie de soumission no 080.275 de la Société générale de Banques au Sénégal (SGBS), en date du 21 mai 2015 et que ledit document ne vise pas SIL en tant que membre du groupement ;

En conséquence, la garantie de soumission de NOVA BASE BUSINESS SOLUTIONS n'est pas conforme aux spécifications de la clause 29.3 des IS précitée ;

2. Sur la conformité des prix par rapport au DAO

Considérant qu'à l'ouverture des plis, en présence des chefs de file des groupements, il a été lu publiquement et à haute voix, le montant de 423 874 804 FCFA et 11 195 907 euros et comme observations, «pas de précision pour les taxes » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du Code des Marchés publics, les prix des marchés sont réputés couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, de la fourniture ou du service, y compris tous droits, impôts et taxes applicables, sauf lorsqu'ils sont expressément exclus du prix du marché ou font l'objet d'une exonération ;

Considérant que la clause 27.5 des IS précise que les prix des composantes Services seront indiqués sous la forme d'un chiffre total pour chaque service avec décomposition desdits prix entre les éléments en devises et les éléments en monnaie nationale et que ces prix doivent englober tous les droits, taxes, impôts et charges, à l'exclusion de la TVA et des autres impôts indirects ou droits de timbre qui peuvent être établis ou s'appliquer dans le pays de l'Acheteur sur le prix des Services lors de la facturation à l'Acheteur si le marché est attribué ;

Considérant que sur cette base, la Commission des Marchés a appliqué à toutes les offres des prix HTVA et qu'elle a procédé à une conversion en XOF, conformément au taux de la BCEAO à la date du 7 mai 2015 ;

Considérant qu'aucun réajustement des prix des candidats n'a été opéré, après la lecture publique des offres ;

Que dès lors, le recours de NOVA BASE sur une telle éventualité n'est pas fondé ;

3. Sur les conditions d'évaluation des offres

Considérant que l'évaluation a porté sur les aspects techniques et financiers des offres des soumissionnaires ;

Considérant qu'au plan technique, les quatre (4) jurys composés de 14 membres ont pris en compte : les capacités à mener le projet, les exigences fonctionnelles et les exigences techniques conformément aux annexes 5,6 et 7 de l'additif au DAO ;

Considérant que le jury a divisé ces aspects en critères qui à leur tour ont été subdivisés en sous-critères et que les membres du jury ont noté individuellement chaque offre en suivant les grilles de notation correspondant à chaque niveau ;

Considérant qu'à l'issue de l'évaluation technique et financière, un score global combinant la qualité et le prix a été calculé pour chaque offre, par application de la formule définie dans le DAO, tenant compte des coefficients de pondération, et qui est la suivante :

d'où :

$$B = \frac{C_{min}}{C} X + \frac{T}{T_{max}} (1-X)$$

C = le Prix évalué de l'offre

Cmin = le plus faible des prix évalués pour l'ensemble des offres conformes

T = le nombre total de points techniques attribué à l'offre

Tmax = le nombre de points techniques attribué à l'offre conforme ayant obtenu le score technique le plus élevé

X = la pondération de prix, telle que spécifiée dans les DPAO.

Considérant que sur cette base, le nombre total de points techniques attribués à l'offre (T) d'IB MAROC est de 73,70, obtenu à partir de la moyenne des quatre (4) jurys, que le score global est de 88,24/100 et par conséquent, l'entreprise a été classée deuxième derrière le groupement ATOS lors de la seconde évaluation ;

Considérant que s'il appartient à l'AC de transmettre au soumissionnaire les critères de notation et la note nominative qui lui a été attribuée, conformément l'article 88.3 du Code des Marchés publics, elle ne peut remettre des informations concernant les autres concurrents si leur divulgation est contraire à la loi ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'autres candidats en révélant des informations publiques sur leur situation financière ou juridique ou sur leur méthode de fabrication et de gestion ;

Considérant que le candidat a, sur sa demande, obtenu de l'autorité contractante, le 8 septembre 2015, les éléments relatifs à l'évaluation de son offre technique et financière, il n'appartient pas à l'Autorité contractante de transmettre les détails de l'évaluation des autres candidats ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commission d'évaluation des offres est fondée à rejeter les candidatures de CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM, NOVA BASE et IB MAROC ;
Qu'il y a lieu d'autoriser la continuation de la procédure de passation du marché ;

Que les recours n'ayant pas prospéré, il y'a lieu d'ordonner la continuation de la procédure et la confiscation des consignations ;

PAR CES MOTIFS:

- 1) Constate que les recours de CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM, NOVA BASE et IB MAROC.COM portent sur la même procédure de passation de marché ;
- 2) Ordonne la jonction des recours ;

- 3) Constate que les garanties de soumission de CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM et de NOVA BASE ne sont pas conformes ;
- 4) Dit que l'admission de la conformité de la garantie de soumission de CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU/KPGM n'aurait aucune incidence sur l'attribution du marché au regard de son classement ;
- 5) Dit que les prix lus publiquement sont HTVA conformément aux exigences du DAO ;
- 6) Dit que l'évaluation des candidatures a été effectuée conformément au DAO ;
- 7) Déclare, en conséquence, que les recours des requérants ne sont pas fondés ;
- 8) Ordonne la continuation de la passation des marchés et la confiscation des consignations ;
- 9) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à CATALYST BUSINESS SOLUTIONS SAU / KPGM, NOVABASE et IB MAROC, ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

57

Suite à cette décision du CRD, seul le groupement CATALYST a saisi la Cour Suprême d'une requête pour solliciter le sursis à l'exécution de la décision du CRD n°298 du 14 octobre 2015.

Mais par arrêt n°03 du 14 janvier 2016, la haute juridiction, s'appuyant sur les dispositions de l'article 73.2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour Suprême, rejeta la demande de sursis, en faisant valoir qu'en l'état de l'instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas sérieux et le préjudice encouru par le requérant n'est pas irréparable.

Les garanties que les candidats et titulaires des marchés publics doivent fournir sont prévues aux articles 114 à 120 du code de 2014. Il s'agit d'une part de la garantie de soumission et de la garantie de bonne exécution et d'autre part des autres garanties éventuellement fixées par le cahier des charges pour l'exécution d'un engagement particulier.

Le montant de la garantie de soumission est fixé dans le dossier d'appel d'offres et doit être compris entre 1% et 3% de la valeur estimée du marché, exception faite des marchés de prestations intellectuelles ; pour permettre à certaines entreprises particulières de participer au jeu de la concurrence, elles sont dispensées de fournir la garantie de soumission lorsque la valeur du marché ne dépasse pas 50 millions CFA.

L'article 114 du code qui prévoit la garantie de soumission en fait une condition d'admission aux appels d'offres, mais ne précise pas son objet ; le Conseil de Régulation de l'ARMP a adopté, par sa résolution n°03 du 9 avril 2013, un dossier-type incluant des modèles de garanties de soumission. Néanmoins on peut dire que la garantie de soumission est destinée à protéger l'autorité contractante contre le soumissionnaire en cas de manquement aux obligations de ce dernier.

Et à ce titre tous les membres d'un groupement de soumissionnaires, qui sont solidaires entre eux dans le cadre du marché, doivent être visés par la garantie de soumission pour que l'objectif, qui est la couverture de l'autorité contractante en cas de préjudice du fait du soumissionnaire, soit atteint, d'autant plus que l'engagement de la banque doit être de payer et sans réserve et d'une manière irrévocable à la première demande de l'autorité contractante.

Relativement à la garantie de bonne exécution (article 115 du code), son objet est bien précisé par le code qui dispose que : « tout titulaire d'un marché d'un montant supérieur ou égal aux seuils fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances doit fournir une garantie de la bonne exécution de celui-ci, destinée à couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie, éventuellement prévu.. »

Et son montant est constitué en totalité lors de la signature du marché sans pouvoir dépasser 5% du marché (article 116).

Ainsi défini, la « garantie de bonne exécution » prévu par l'article 115 du code sénégalais s'apparente à la « garantie à première demande » prévue par le code français des marchés publics en ses articles 101 et 102 en vertu desquels, « le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fraction sur chacun des versements autres qu'une avance... et son montant ne peut être supérieur à 5% du montant du marché...

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.

Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102...

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. »

La notion de « garantie de soumission » n'est pas prévue par le code français.

Pour la doctrine et la jurisprudence française, « la garantie à première demande » est une obligation autonome du contrat principal, c'est-à-dire qu'elle est indépendante des relations contractuelles existant entre le pouvoir adjudicateur (l'autorité contractante) et le titulaire du marché. Cela a pour conséquence principale que la garantie à première demande a la nature d'un contrat de droit privé, dont le contentieux incombe au juge judiciaire, y compris lorsque le marché a pour objet la réalisation de travaux (CE, ord, 3 novembre 2001, Ste Technibat Aluminium Service).

C.A.A Paris, 6 février 2007, Assistance Publique Hôpitaux de Paris.

5

**AFFIRMATION, NON-FONDEE, SELON
LAQUELLE L'ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE NE
REMPLE PAS LES CRITERES PREVUS DANS
LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES.**

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Acte III de la Décentralisation, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, actuellement dénommé Ministère de la gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, a lancé un appel d'offres pour l'acquisition de 615 véhicules en deux lots.

Suite à l'évaluation des offres, l'attribution provisoire des deux lots du marché a été faite au profit de l'entreprise Tracto Service Equipement (TSE).

Après avoir saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux qui se révéla infructueux, CCBM Industries introduit alors un recours contentieux auprès du CRD, lequel, après avoir prononcé la suspension de la procédure par décision n° 178 du 10 juillet 2014, ordonna ensuite la reprise de l'évaluation du lot n°2 du marché, par décision n° 192 du 23 juillet 2014.

A l'issue de la réévaluation effectuée en application de cette décision du CRD, TSE fut déclarée attributaire provisoire du lot 2 du marché.

Contestant de nouveau l'attribution provisoire du lot 2, CCBM saisit encore le CRD d'un recours contentieux, lequel, après avoir ordonné une deuxième fois la suspension de la procédure et reçu les pièces y afférentes, ordonna, par décision n°245 du 10 septembre 2014, la poursuite de la procédure après avoir rejeté le recours de CCBM.

Le CRD a fait valoir qu'en application de sa décision n°192 du 23 juillet 2014, l'autorité contractante a repris l'évaluation des offres du lot n°2 et il en est résulté que l'affirmation de CCBM selon laquelle TSE ne remplit pas les exigences de qualification relatives au service après-vente et au magasin de pièces de rechange n'est pas fondée, parce que d'abord, pour prouver sa qualification, l'entreprise TSE a présenté ses ressources matérielles et humaines dans la même forme que les autres soumissionnaires, conformément à l'article 44 du code des marchés publics, en décrivant d'une façon détaillée les deux ateliers de réparation dont elle se prévaut, avec des photos à l'appui ; qu'ensuite l'autorité contractante a déterminé la qualification de TSE en procédant à la vérification de la qualification des candidats conformément aux modalités et procédures fixées par la DAO, notamment les clauses 28 et 36 des « Instructions aux Candidats (IC) » ; que finalement, en plus TSE et CCBM ont tous les deux produit un constat d'huissier, TSE, pour étayer la matérialité des équipements dont il se prévaut et CCBM pour infirmer leur existence ; que non seulement ledit constat, même s'il peut constituer un moyen de preuve supplémentaire, n'est pas exigé par le DAO, mais également il résulte des mentions du constat d'huissier produit par CCBM que celui qui a fait le constat n'as pas accédé aux installations et que les pièces de rechange dont on cherche à prouver l'inexistence n'ont rien à voir avec le marché litigieux.

**DECISION N° 245/14/ARMP/CRD DU 10 SEPTEMBRE 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE CCBM INDUSTRIES –
ESPACE AUTO CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISoire LOT 2 DU MARCHE RELATIF
A L'ACQUISITION DE SIX CENT QUINZE (615) VEHICULES, LANCE PAR LE MINISTERE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO en date du 27 août 2014 ;

Vu la consignation faite par CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO, le 19 août 2014 ;

Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Madame Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par courrier du 27 août 2014, enregistré le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 242/14, la société CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO a saisi le CRD pour contester l'attribution provisoire du lot 2 du marché relatif à l'acquisition de 615 véhicules, lancé par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales (MATCL).

LES FAITS

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Acte III de la Décentralisation, le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales (MATCL), actuellement dénommé Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MGLDAT) a publié un avis d'appel d'offres dans le journal « Le Soleil » du 05 mai 2014, pour l'acquisition de six cent quinze (615) véhicules en deux lots, ainsi répartis :

- lot 1 : 50 véhicules (minimum) à 215 véhicules (maximum) 4X4 STATION WAGON,
- lot 2 : 50 véhicules (minimum) à 400 véhicules (maximum) 4X4 PICK UP.

A l'ouverture des plis, sept (07) offres ont été reçues et les montants ci-après ont été lus au lot 2 :

N° PLI	FOURNISSEURS	MONTANT en FCA TTC (pour le minimum de 50 véhicules)	MONTANT en FCA TTC (pour le maximum de 400 véhicules)
1	MATFORCE	585 000 000	
2	CCBM AUTOMOBILES		7 080 000 000
3	CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO	495 000 000	3 960 000 000
4	TATA AFRICA SENEGAL	624 500 000	4 996 000 000
5	LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE	729 750 000	5 560 000 000
6	CFAO MOTORS SENEGAL		7 792 000 000
7	TSE		3 800 000 000

Après l'évaluation des offres, l'autorité contractante a fait publier, dans les journaux « Le Soleil » et « Le Quotidien » du 02 juillet 2014, l'avis d'attribution provisoire des deux (2) lots du marché au profit de l'entreprise Tracto Service Equipement (TSE).

Au vu dudit avis, le soumissionnaire CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux par lettre du 02 juillet 2014.

Non satisfaite de la réponse reçue le 04 juillet 2014 de l'autorité contractante, le requérant a introduit un recours contentieux auprès du CRD par courrier du 07 juillet 2014, reçu et enregistré le même jour sous le numéro 196/14.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure par décision n° 0178/14 du 10 juillet 2014, puis, après instruction du dossier transmis par l'autorité contractante, ordonné la reprise de l'évaluation des deux lots du marché, par décision n° 192 du 23 Juillet 2014.

Au terme de la réévaluation des offres effectuée en application de la décision du CRD susvisée, l'autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 19 août 2014, l'avis d'attribution provisoire du lot 2 du marché au profit de la société TSE.

La société CCBM INDUSTRIES- ESPACE AUTO, contestant de nouveau l'attribution provisoire du lot 2 au soumissionnaire TSE, a saisi le CRD d'un recours contentieux.

Ayant jugé le recours recevable, le CRD a, une deuxième fois, ordonné la suspension de la procédure et demandé les pièces du dossier qui lui ont été transmises par le Ministère de la Gouvernance locale du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MGLDAT) par correspondance du 03 septembre 2014.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours, CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO rappelle que le CRD avait ordonné la reprise de l'évaluation du lot 2 avec l'existence d'éléments de preuves pertinentes permettant de s'assurer de la qualification de TSE.

A ce propos, il soutient, qu'en matière de contentieux des marchés publics, notamment dans le cas de l'acquisition de véhicules, la preuve la plus tangible est celle apportée par le fournisseur lui-même. Aussi, ne comprend-il pas la démarche adoptée par l'attributaire provisoire du marché, qui consiste à se « réfugier derrière un constat d'huissier » pour apporter les informations complémentaires exigées. Il souligne, par ailleurs, que l'huissier ne fait que constater, ce qui de son point de vue, suscite des interrogations, notamment sur le magasin effectivement constaté, sa date d'acquisition.

Par ailleurs, le requérant informe que le journal « Direct Info » N° 795 du 07 août 2014 a annoncé « l'acquisition d'un nouveau garage ultra moderne » par TSE et que pour vérifier l'information, il s'est attaché les services d'un huissier dont le procès-verbal infirme l'annonce faite.

Dans le même ordre d'idées, le requérant estime que seul le fournisseur a la possibilité d'apporter les preuves sur la base de documents authentifiés et non postérieurs à l'appel d'offres.

Le requérant conclut ainsi que l'offre de TSE doit être écartée car l'attributaire n'a pas rempli les critères prévus dans le DAO.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Par lettre du 03 septembre 2014, le Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, a transmis les éléments demandés aux fins d'instruction, tout en précisant que l'entreprise TSE, qui a proposé l'offre conforme évaluée la moins-disante, a fourni, suite à une demande d'éclaircissements, les preuves complémentaires attestant qu'elle remplit les critères de qualification requises pour exécuter le lot 2 du marché.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de l'attributaire provisoire du lot 2 du marché suite à la réévaluation effectuée par l'autorité contractante.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que dans la décision n°192 du 23 Juillet 2014, le CRD avait estimé que TSE n'avait pas apporté des preuves suffisantes pour justifier sa qualification puisqu'il n'avait fourni qu'un document signé par son Directeur général pour prouver qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires pour exécuter le marché, notamment un service après-vente et un magasin de pièces de rechange ;

Qu'à cet égard, le CRD avait ordonné que l'évaluation des offres du lot 2 soit reprise et que l'autorité contractante demande des informations complémentaires à TSE afin de disposer de preuves pertinentes permettant d'établir la qualification du soumissionnaire susnommé ;

Qu'en application de la décision rendue par le CRD, l'autorité contractante, procédant à la reprise de l'évaluation des offres, a requis et obtenu de TSE, des éclaircissements sur sa qualification, puis, ayant jugé que les preuves fournies permettent d'attester qu'il dispose des capacités techniques requises, l'a désigné, à nouveau, comme attributaire provisoire du lot 2 du marché ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 44 du Code des Marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que pour prouver sa qualification, l'entreprise TSE, a présenté ses ressources matérielles et humaines dans la même forme que les autres soumissionnaires au moyen d'une description détaillée de ses installations, lesquelles sont réparties sur deux sites et constituées ainsi qu'il suit :

- site 1 : un atelier de réparation à Colobane ex-Terrain Foyer en face de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie comprenant : réception, mécanique, électricité, tôlerie, peinture, magasin pièces détachées, un service rapide pour entretien courant, un show room, un service d'assistance jour/nuit.

Le site 1 dispose des équipements suivants : 2 ponts élévateurs, une cabine de peinture avec four de séchage de dernière génération, 2 stations de vidange graissage+quick service, 1 équilibreuse+1 démonte pneus, 1 station train avant ;

- site 2 : un atelier de réparation sis au 15, Routes des Brasseries, comprenant : réception, mécanique, électricité, magasin pièces détachées, show room, un service d'assistance. Le site 2 comprend 3 entrepôts, 2 magasins de pièces détachées, 1 équilibreuse de roue, 2 stations de levage, l'outillage standards mécaniciens, un ensemble d'outils informatiques en liaison avec les constructeurs ;

Qu'en outre, TSE a fourni, en guise de preuve complémentaire, des photos ainsi que le détail de ses moyens humains ;

Considérant que selon la clause 36 de la partie « Instructions aux candidats (IC)» du DAO, la vérification de la qualification des candidats est fondée sur l'examen des pièces soumises par le candidat et attestant ses qualifications ; l'attribution du marché au candidat est subordonnée par l'issue positive de cette vérification ;

Qu'au regard de la clause 28 des IC, pour faciliter la vérification de la qualification des candidats, l'autorité contractante a toute latitude pour demander à un candidat des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements de l'autorité contractante, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit ;

Qu'il résulte des clauses susvisées que l'autorité contractante a fait une application correcte des dispositions du DAO en demandant des éclaircissements par écrit à TSE sur sa qualification ;

Que dans le même ordre d'idées, la détermination de la qualification de TSE sur la base de l'examen des pièces fournies est conforme aux prescriptions du Dossier d'appel d'offres (DAO) ;

Que, par ailleurs, au vu des éléments de preuves produits par TSE, présentés de la même manière que les autres soumissionnaires sous forme de description détaillée des moyens humains et matériels, étayés par des photos, brochures, CV du personnel exigés et en référence à la clause 28.1 des IC qui énonce que les offres doivent être évaluées sur la base de leur seul contenu, la décision de la commission des marchés est justifiée ;

Considérant que CCBM INDUSTRIES – ESPACE AUTO fait grief au concurrent TSE de ne pas remplir les exigences de qualification relatives au service après-vente et au magasin de pièces de rechange ;

Considérant que TSE et CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO ont, tous les deux, produit un procès-verbal de constat d'huissier, le premier pour étayer la matérialité des équipements et installations dont il se prévaut, le deuxième, pour infirmer l'information relative à l'existence d'un service après-vente et d'un magasin de pièces de rechange pour le compte de TSE ;

Que s'il est vrai qu'en l'espèce le constat d'huissier peut constituer un moyen de preuve supplémentaire, il reste entendu que ce procédé n'est pas exigé par le DAO ;

Que s'agissant du constat de l'huissier commis par CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO, le contenu du procès-verbal ne permet pas de conclure que TSE ne dispose pas des capacités techniques requises dans le DAO ;

Qu'en effet, au sujet du service après-vente, ce procès-verbal de constat d'huissier décrit le bâtiment censé abriter les locaux, de l'extérieur et fait cas « d'un regard à travers les interstices de la porte » ce qui laisse apparaître qu'il n'a pas accédé aux installations ;

Qu'en ce qui concerne la disponibilité de pièces de rechange, le procès-verbal a consigné la réponse d'une personne considérée comme un employé de TSE, qui, à la question de l'huissier de savoir si son entreprise dispose de telles pièces pour véhicule FOTON PICK-UP, aurait affirmé ne pas en détenir ;

Qu'à ce sujet, il convient de rappeler que le stock de pièces de rechange requis dans le DAO doit concerner le modèle de véhicule proposé par les soumissionnaires, et qu'en l'espèce, il n'est nulle part mentionné dans l'offre du lot 2 de TSE, un véhicule FOTON PICK-UP, ce dernier ayant proposé un véhicule CHTC T2 LHD Pick-up ;

Que dès lors le requérant n'a pas apporté de preuve attestant que TSE ne remplit pas les exigences du dossier d'appel d'offres en moyens techniques et humains ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le grief relatif à la non qualification de TSE n'est pas fondé ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de poursuivre la procédure ;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que TSE, a produit des documents pour prouver qu'il remplit le critère de qualification relatif aux moyens matériels et humains, présentés dans la même forme que les autres soumissionnaires ;
- 2) Constate, au surplus, que TSE a produit un procès-verbal de constat d'huissier en guise de preuve supplémentaire ;
- 3) Dit que selon les clauses du DAO, l'évaluation des offres doit être effectuée sur la base du contenu de l'offre et de l'examen des pièces produites par les candidats ; le recours à l'huissier ne constitue pas un procédé exigé par le DAO ;
- 4) Dit que durant l'évaluation des offres, la demande d'éclaircissements complémentaires est une pratique conforme à la réglementation ;
- 5) Dit que la commission des marchés est fondée à accepter les preuves fournies par TSE et présentées de la même manière que les autres soumissionnaires ;
- 6) Constate que le requérant CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO a contesté la qualification de TSE avec à l'appui un constat d'huissier ;

- 7) Dit qu'à l'analyse du contenu, le procès-verbal de constat de l'huissier commis par CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO ne permet pas de conclure que TSE ne dispose pas des moyens techniques dont il s'est prévalu pour justifier sa qualification ;
- 8) Dit, en conséquence, que le grief n'est pas fondé ;
- 9) Ordonne la poursuite de la procédure ;
- 10) Ordonne la confiscation de la consignation ;
- 11) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à CCBM INDUSTRIES- ESPACE AUTO, au Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MGLDAT) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Samba DIOP Les membres du CRD
Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

Par requête du 20 octobre 2014 adressée à la Cour Suprême, la société CCBM a sollicité le sursis à l'exécution de cette décision du CRD n°245 du 10 septembre 2014.

Suivant arrêt n°53 du 13 août 2015, la Cour a rejeté la requête en faisant valoir qu'en l'état de l'instruction, les moyens ne paraissent pas sérieux et que la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice irréparable encouru si la décision attaquée est exécutée, faisant ainsi application de l'article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour Suprême.

L'appréciation de la capacité des candidats est une exigence du code aussi bien au Sénégal (article 43, 44 et 68 du code sénégalais) qu'en France (article 45, 46 et 52).

Cette exigence, fixée par les codes, doit être nécessairement mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, de même qu'elle doit être respectée par les candidats.

Les textes sénégalais et français vont dans le même sens, car il s'agit de contrôler si le candidat possède les références en lien avec l'objet du marché et les moyens humains et matériels nécessaires à la bonne exécution du marché.

Pour la doctrine cela participe au respect des principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.

Les jurisprudences, en la matière, vont aussi dans le même sens :

► Conseil d'Etat :

- 24 juin 2011 Ville de Rouen, réq n°347840 (Modalités de sélection des candidatures- Obligation d'apprécier les capacités des candidats au vu des documents exigés par le règlement de consultation.) ;
- 29 avril 2011, Ministre de la justice et des libertés c/IGNA réq n°344617 (Modalités de sélection des candidatures et niveau minimal de garantie professionnelle... Obligation de contrôle des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats au vu des documents ou renseignements demandés au règlement de consultation.

6

**IMPERTINENCE DE LA CONTESTATION
D'UNE CLAUSE DU DOSSIER DE
CONSULTATION SOULEVEE APRES
L'ATTRIBUTION PROVISOIRE**

En vertu de l'article 89 du Code de 2014 les contestations relatives au dossier de consultation et aux critères d'évaluation doivent être faites dans un délai de cinq (5) jours francs et ouvrés, à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel à la concurrence, et non après la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché. Donc est impertinent, l'argument du requérant présenté après la publication de l'attribution provisoire et relatif à la contestation d'un critère d'évaluation qui figurait clairement dans le dossier de consultation.

**DECISION N° 329/14/ARMP/CRD DU 26 NOVEMBRE 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT OMEGA TECHNOLOGIE
DEVELOPPEMENT/GIC CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISoire DU MARCHÉ RELATIF
A LA SELECTION DE CANDIDATS POUR LES ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION, LES
ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES ET L'ELABORATION D'UN DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
POUR LA CONSTRUCTION DES ROUTES LOMPOUL-POTOU-GANDIOL EN 2X1 VOIES
(63km), LOMPOUL/POTOU-GUEOUL (35 km) ET REHABILITATION DE LA ROUTE REVETUE
LOUGA-LEONA-POTOU (38 km)**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC du 29 octobre 2014;

Vu la consignation faite par le groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC le 30 octobre 2014;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes et Mame Aïssatou DIENG TRAORE, chef de la Division des Appuis techniques ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

► Adopte la présente décision :

Par courrier du 30 octobre 2014, reçue le lendemain au service courrier de l'ARMP, le groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester la procédure de sélection de candidats pour les études techniques d'exécution, études socio-économiques et l'élaboration d'un Dossier d'appel d'offres pour la construction des routes Lompoul-Potou-Gandiole en 2x1 voies (63 km), Lompoul/Potou-Guéoul (35 km) et réhabilitation de la route revêtue Louga-Léona-Potou (38 km).

LES FAITS

Sur financement de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), l'AGEROUTE a lancé une consultation restreinte pour sélectionner un cabinet chargé de réaliser les études techniques d'exécution, les études socio-économiques et l'élaboration d'un Dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction des routes Lompoul-Potou-Gandiole en 2x1 voies (63 km), Lompoul/Potou-Guéoul (35 km) et réhabilitation de la route revêtue Louga-Léona-Potou (38 km).

A cet égard, l'AGEROUTE a adressé la demande de propositions à sept (07) cabinets constituant la liste restreinte.

A la date limite de dépôt des propositions, cinq (05) offres ont été reçues. Au terme de l'évaluation des offres techniques et financières, la commission des marchés a proposé d'attribuer provisoirement le marché au groupement DECO/Afrique Consult.

Dès qu'il a été informé de l'issue de la procédure, le groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC a saisi l'AGEROUTE d'un recours gracieux pour contester l'attribution provisoire.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n°309/14 et demandé à l'autorité contractante de transmettre les éléments du dossier.

Par courrier du 18 novembre 2014, l'AGEROUTE a fait parvenir à l'ARMP les documents pour les besoins de l'instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS.

Le groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC considère que lors de l'évaluation des offres, l'AGEROUTE a utilisé un critère qui viole la réglementation des marchés publics pour l'évincer.

Ainsi, après avoir rappelé les stipulations de l'article 7 de la demande de propositions relative au mode de sélection et au déroulement de la procédure d'évaluation en deux étapes, le requérant soutient que le motif de son élimination n'est pas fondé. Pour étayer son argumentaire, le requérant a présenté des tableaux faisant ressortir :

- les notes globales pondérées des candidats à partir de leurs notes techniques et propositions financières ;
- les simulations d'offres financières pour démontrer l'impertinence du critère de rejet ;
- une comparaison des prix pratiqués sur des prestations similaires réalisées dans le passé au profit de la même autorité contractante ;

Ainsi, le requérant fait observer qu'un comportement marginal d'un candidat qui, bien qu'étant techniquement classé dernier, soumettrait une offre financière exagérée, pourrait entraîner l'élimination de tous les quatre autres candidats dont les offres financières seraient inférieures à 80% de la moyenne des offres. Dans la même lancée, le requérant, se référant aux décisions d'attribution antérieures d'AGEROUTE, estime que les coûts varient, pour les projets concernés, entre 854 595 FCFA et 1 794 620 FCFA par kilomètre en moyenne, alors que dans la procédure litigieuse, l'attribution est estimée à 2 856 945 FCFA par kilomètre.

Le groupement requérant en conclut que le critère qui a justifié son élimination, constitue une violation de l'article 24 nouveau du COA dans la mesure où il ne cherche pas à préserver les deniers publics.

Par ailleurs, le requérant, estimant être éliminé pour cause d'offre anormalement basse, remet en cause le bien fondé du grief soulevé par AGEROUTE en invoquant quelques litiges dont l'issue constitue selon lui, une jurisprudence, notamment, des décisions rendues par le CRD et arrêts du Conseil d'Etat français.

Le groupement requérant soutient, en fin de compte, qu'AGEROUTE a introduit une troisième étape dans l'évaluation, à travers une disposition dont elle considère qu'elle est porteuse de risques d'une inflation injustifiée puisqu'elle entraîne systématiquement le rejet de toute offre financière inférieure à 244 028 040 de francs CFA.

C'est pourquoi, il demande l'annulation de l'attribution.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

72

En réponse au recours gracieux, l'AGEROUTE rappelle que la demande de propositions comportait la clause qui prévoit l'élimination de tout candidat dont la proposition financière serait inférieure à 0.8 M, M étant la moyenne arithmétique des propositions financières corrigées et ajustées des soumissionnaires ayant obtenu le score minimal requis.

Selon l'AGEROUTE, la disposition n'a jamais fait l'objet d'observation ou de réclamation par les candidats. En outre, le dossier de consultation a été validé par le bailleur (BOAD) et la DCMP.

L'AGEROUTE en conclut qu'à l'étape de la procédure, toute action visant à revenir sur une clause connue et acceptée au préalable, ne doit prospérer.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité du rejet de l'offre du groupement OMEGA TECHNOLOGIE/GIC suite à l'application de la clause de la demande de propositions relative à l'offre anormalement basse.

AU FOND

Considérant qu'à la clause 7.4 des données particulières de la demande de propositions, il est mentionné qu'« une proposition financière est dite anormalement basse si elle est inférieure à 0,80 M, M étant égal à la moyenne arithmétique des propositions financières corrigées et ajustées des soumissionnaires ayant obtenu le score technique minimal requis de 70 points sur 100. Les propositions financières inférieures à 0.80M seront éliminées » ;

Considérant que le rejet d'une offre jugée anormalement basse vise à prémunir les autorités contractantes contre les risques de défaillance pendant l'exécution des prestations puisque le titulaire ayant soumis une telle offre peut se retrouver dans l'incapacité d'exécuter le marché, ou bien peut tenter d'obtenir postérieurement un relèvement du prix par le biais d'avenants, ou enfin, peut jouer sur la qualité des prestations pour rattraper sa marge bénéficiaire ;

Que pour juger de la réalité économique d'une offre, l'autorité contractante a la possibilité de prévoir une formule mathématique qui doit, cependant, simplement permettre de déterminer un seuil d'anomalie en deçà duquel l'offre peut être suspectée d'être anormalement basse ; le rejet ne peut intervenir que si, le candidat invité à justifier son prix, n'apporte pas une réponse satisfaisante ;

Que contrairement aux principes ci-dessus décrits, la clause 7.4 de la demande de propositions, relative aux offres anormalement basses, a pour effet d'écarter systématiquement toute proposition financière en deçà de 80% de la moyenne des offres ;

Qu'il en résulte que l'éviction de candidats sur la base de la clause susvisée n'est pas conforme aux bonnes pratiques puisque ces derniers n'ont pas la possibilité de présenter des éléments de justification du caractère anormalement bas de leur offre ;

Qu'au surplus, comme l'a si bien relevé le requérant, ladite clause peut induire un renchérissement des coûts dans la mesure où, un prix exagérément élevé pourrait avoir pour effet de relever la moyenne des offres et d'écarter celles qui sont pourtant conformes à la réalité économique ;

Considérant, cependant, qu'il est de principe que les règles préalablement arrêtées dans le dossier d'appel à concurrence doivent être respectées à l'évaluation ;

Que dans le cas de la procédure litigieuse, la clause incriminée figurait, de façon claire, dans le dossier de consultation validé par la BOAD et la DCMP ;

Que dès lors, le requérant aurait dû la contester au moment du lancement de la consultation ;

Qu'ainsi, ayant accepté de participer à la compétition sans soulever de grief, le requérant est mal fondé à contester la clause après l'attribution ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la procédure.

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation de la consignation.

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que l'offre financière du groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC est en deçà de 80% de la moyenne arithmétique des offres ;
- 2) Constate que le rejet de l'offre du groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC découle de l'application de la clause du dossier de consultation relative à l'offre anormalement basse ;
- 3) Dit que le rejet systématique d'une offre sur la base d'une formule n'est pas conforme aux bonnes pratiques puisque le candidat n'a pas l'occasion de justifier ses prix ;
- 4) Constate, toutefois, que la demande de propositions validée par la BOAD et la DCMP comportait la clause relative aux offres anormalement basses ;
- 5) Constate que la clause n'a pas été contestée au lancement de la procédure ;

- 6) Dit qu'en vertu du principe de transparence, les règles préalablement fixées dans le dossier de consultation doivent être respectées à l'évaluation ;
- 7) Dit que le groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC aurait dû contester la clause incriminée au lancement du dossier;
- 8) Dit qu'au stade de la procédure, l'AGEROUTE est fondée à appliquer la clause à l'ensemble des candidats ;
- 9) Dit, en conséquence, que l'élimination du groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC dont la proposition financière est en deçà de 80% de la moyenne arithmétique des offres est fondée ;
- 10) Ordonne la confiscation de la consignation et la poursuite de la procédure ;
- 11) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au groupement OMEGA TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT/GIC, à l'AGEROUTE ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

Le Président
Mademba GUEYE

Samba DIOP	Les membres du CRD	
	Cheikhou Issa SYLLA	Boubacar MAR
	Le Directeur Général	
	Rapporteur	
	Saer NIANG	

7

**OBLIGATION POUR L'AUTORITE
CONTRACTANTE DE RESPECTER LE
PRINCIPE DE TRANSPARENCE**

Dans le journal « Le Soleil » du 10 décembre 2013, l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP) a fait publier une sollicitation à manifestation d'intérêt aux fins de sélectionner des candidats pour les études architecturales et le suivi des travaux de construction de l'Université du Sine Saloum. A la date limite de réception des candidatures, le 16 janvier 2014, dix-sept(17) candidats se sont manifestés, dont le groupement ARCHI CONCEPT INTERNATIONAL/ ARTECH/SOLUTEC/GAUDILLAT.

Après évaluation des candidatures, dans le journal « Le Soleil » du 30 mai 2014, l'ACBEP a fait publier la liste restreinte des cabinets retenus.

Ne figurant pas sur ladite liste, le groupement susvisé a fait un recours gracieux reçu le 2 juin 2014, pour contester son éviction.

L'autorité contractante n'ayant pas répondu audit recours, par lettre du 12 juin 2014 le groupement a saisi le CRD d'un recours contentieux aux motifs qu'il s'étonnait de son éviction de la liste restreinte, en raison des références individuelles des membres du groupement et des rangs des cabinets le composant sur le plan national, régional et international.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD, par décision n°156 du 16 juin 2014, ordonna la suspension provisoire de la procédure et sollicita de l'autorité contractante la transmission des pièces nécessaires à l'instruction.

Suite à la réception desdites pièces, par décision n°180 du 9 juillet 2014, le CRD annula la manifestation d'intérêt et ordonna la reprise de la procédure. A l'appui de sa décision, le CRD a fait valoir qu'il ya eu violation du principe de transparence, dans la mesure où la commission des marchés a déclaré que le groupement requérant a été éliminé parce qu'il n'a pas atteint la note minimale de 80 points, pour n'avoir obtenu que 74 points sur 100, alors qu'il s'est révélé, à l'examen de l'avis à manifestation d'intérêt et des pièces du dossier, que l'autorité contractante n'a précisé nulle part, à l'intention des candidats, la note minimale à atteindre pour être retenu sur la liste restreinte.

**DECISION N° 180/14/ARMP/CRD DU 09 JUILLET 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D'ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL RELATIF A
L'AVIS A MANIFESTATION D'INTERET DE L'AGENCE DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS
ET EDIFICES PUBLICS (ACBEP) AYANT POUR OBJET LA SELECTION DE CANDIDATS
POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET LE SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE L'UNIVERSITE DU SINE SALOUM (CAMPUS DE KAOLACK ET DE KAFFRINE)**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL, pour le compte du groupement Archi-Concept International/ARTECH/Gaudillat/Genesys, en date du 12 juin 2014, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 173/14 ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Mame Aissatou DIENG, chef de la Division Appuis Techniques, Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 12 juin 2014, enregistrée le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 173/14, ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL, pour le compte du groupement précité, a saisi le CRD en contestation de son éviction de la liste restreinte arrêtée par l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), dans le cadre de l'avis à manifestation d'intérêt ayant pour objet la sélection de candidats pour les études architecturales et le suivi des travaux de construction de l'Université du Sine Saloum (campus de Kaolack et de Kaffrine).

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 10 décembre 2013, l'ACBEP a fait publier une sollicitation à manifestation d'intérêt aux fins de sélectionner des candidats pour les études architecturales et le suivi des travaux de construction de l'Université du Sine Saloum.

A la date limite de réception des candidatures, le 16 janvier 2014, dix sept (17) candidats se sont manifestés, dont le groupement ARCHI CONCEPT INTERNATIONAL/ARTECH/SOLUTEC/ GAUDILLAT.

Après évaluation des candidatures, dans le journal « Le Soleil » du 30 mai 2014, l'ACBEP a fait publier la liste restreinte des cabinets retenus.

Ayant pris connaissance de cette publication, par lettre du même jour, le groupement a adressé à l'autorité contractante un recours gracieux, reçu le 02 juin 2014, pour contester son éviction de la liste restreinte.

L'autorité contractante n'ayant pas répondu audit recours, par lettre du 12 juin 2014 enregistrée le même jour au secrétariat du CRD, le groupement a saisi cet organe d'un recours contentieux.

Après avoir déclaré ledit recours recevable, le CRD, par décision n° 156 du 16 juin 2014, a ordonné la suspension de la procédure, et sollicité de l'autorité contractante la transmission des pièces nécessaires à l'instruction.

Par lettre du 07 juillet 2014 reçue le même jour à l'ARMP, l'ACBEP a transmis les documents réclamés.

LES MOYENS A L'APPUI DU RECOURS

Au soutien de sa saisine, le groupement fait observer que son recours gracieux adressé à l'autorité contractante n'a pas reçu de réponse.

Dans ledit recours, il s'étonnait de son éviction de la liste restreinte, en raison des références individuelles des membres du groupement, et des rangs des cabinets le composant sur le plan national, régional et international.

C'est pourquoi, il a saisi le CRD pour arbitrage.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa lettre de transmission des documents, l'ACBEP fait observer que l'évaluation de la candidature du groupement a été faite objectivement par la commission des marchés et que sa note ne lui permettait pas de figurer sur la liste restreinte qu'elle a choisi d'arrêter à cinq (05), alors que la réglementation lui permet d'en retenir trois.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le bien-fondé du rejet de la candidature du groupement requérant.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que dans l'avis à manifestation d'intérêt publié par l'ACBEP, il est mentionné que « les candidats devront fournir la liste des renseignements suivants :

► Expérience générale et spécifique (50 points) :

- expérience générale : 10 points ;
- expérience spécifique études : 20 points (4 points par expérience) ;
- expérience spécifique suivi : 20 points (4 points par expérience) ;

► Personnel : effectif pour réaliser la mission (50 points) :

- architecte : 20 points maximum (2 points/année d'expérience) ;
- ingénieur génie civil : 10 points maximum (1 point/année d'expérience) ;
- ingénieur en électricité : 5 points maximum (1 point/année d'expérience) ;
- ingénieur hydraulique/assainissement : 5 points maximum (1 point/année d'expérience) ;
- spécialiste en téléphonie et internet : 5 points maximum (1 point/année d'expérience) ;
- environnementaliste : 5 points maximum (1 point/année d'expérience) » ;

Considérant que pour évincer le groupement de la liste restreinte, la commission des marchés a argué qu'il n'a pas atteint la note minimale de 80 points, puisqu'il a obtenu la note de 74/100, soit 34/50 au titre de l'expérience et 40/50 pour le personnel ;

Considérant que, toutefois, à l'examen de l'avis à manifestation d'intérêt et des pièces du dossier, l'ACBEP n'a précisé nulle part, à l'intention des candidats, la note minimale à atteindre pour être retenu sur la liste restreinte ;

Qu'il est de principe que l'autorité contractante ne peut faire application, au cours de l'évaluation, d'un critère qui n'a pas été préalablement porté à la connaissance des candidats ;

Qu'en conséquence, en appliquant aux candidats, et notamment au requérant, un critère non annoncé dans le dossier d'appel à candidature, l'ACBEP a violé le principe de transparence exigé dans la passation des marchés publics ;

Qu'il y a lieu d'annuler la manifestation d'intérêt et d'ordonner la reprise de la procédure ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d'ordonner, en outre, la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que la commission des marchés de l'ACBEP a appliqué aux candidats et, notamment, au groupement Archi-Concept International/ARTECH/Gaudillat/Genesys, un critère non contenu dans le dossier d'appel à la concurrence ;
- 2) Dit que l'ACBEP a violé le principe de transparence exigé dans la passation des marchés publics ;
- 3) Ordonne l'annulation de la manifestation d'intérêt et la reprise de la procédure ;
- 4) Ordonne la restitution de la consignation ;
- 5) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL, à l'Agence pour la Construction de Bâtiments de d'Edifices publics, ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée dans le portail officiel des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

La position du CRD, en la matière, est constante, car à chaque fois que le principe de transparence, prévu par l'article 67 alinéas 2 et 3 du code des marchés publics et l'article 24 du COA, a été violé, il a annulé la procédure ; il en a été ainsi par exemple dans ses décisions numéro 11 du 14 janvier 2015 et numéro 73 du 25 mars 2015 ; de même qu'il en a été également ainsi dans sa décision n°3

du 11 janvier 2010 où le Bureau Véritas qui était attributaire provisoire du marché avait introduit , par la suite, devant la Cour Suprême, un recours en annulation de cette décision n°3 du 11 janvier 2010 ; mais la haute Cour le rejeta, adoptant ainsi la même conception que le CRD.

En France et en Europe, les décisions vont dans le même sens.

En effet, selon une jurisprudence constante, il convient de préciser les sous-critères dans le règlement de la consultation, voire selon certaines juridictions, dès l'avis d'appel public à la concurrence : (T.A. Marseille ; ordonnance du 26 juillet 2006, Communauté de communes de Trois Vallées, req. N° 0604605. Irrégularité de l'absence de précisions dans l'avis du critère valeur technique apprécié au regard de la conformité aux normes et de l'organisation de la mise en place des bacs roulants).

- CJCE (Cour de Justice de l'Union Européenne), 18 novembre 2010, Commission Européenne contre Irlande, Aff. C. 226/09 (conditions de mise en œuvre des critères d'attribution. Impossibilité de modifier la pondération des critères d'attribution en cours de procédure) ;
- C.J.C.E., 12 décembre 2002, Universale – Bau AG, Aff. C.470/99, contrats et marchés publics, mars 2003, n° 51, p. 26, note G. Ekert (obligation de mention de la pondération des critères dans les documents de consultation lorsque le pouvoir adjudicataire les a fixés préalablement) ;
- C.E., 14 janvier 1998, Préfet du Val-d'Oise contre Office départemental d'HLM du Val d'Oise, req. N° 165416 (irrégularité d'une précision ou complément d'offres entraînant un ajout à l'offre initiale).

Pour la doctrine française, « la transparence est une obligation quasi générale d'éviter l'opacité des procédures de décision publique, dans le but de permettre la vérification de l'observation d'autres règles, en particulier celle de non-discrimination dans le cadre de la passation des contrats publics, essentiellement au moyen d'une publicité adéquate ou éventuellement une autre forme d'information, par exemple l'accès à certains documents administratifs. La transparence de la passation des contrats publics s'impose en vertu de règles communautaires et constitutionnelles ainsi qu'en application de divers textes, notamment en matière de marché publics. »

8

**OBLIGATION POUR L'AUTORITE
CONTRACTANTE DE RESPECTER LES
PRINCIPES D'EGALITE DE TRAITEMENT
DES CANDIDATS ET DE LIBRE ACCES A LA
COMMANDE PUBLIQUE**

Suite à l'avis à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEPME et ayant pour objet la « recherche de partenaire privé pour la mise en place d'un Cloud Computing pour les PME, Global Sourcing Solutions a transmis son offre qui a été reçue le 28 août 2014 par l'autorité contractante. »

Mais, après l'ouverture des propositions techniques des soumissionnaires, le 29 août 2014, l'ADEPME saisit le requérant d'une lettre datée du 1er septembre 2014, pour l'informer de « l'omission de son offre, par inadvertance, au moment de l'ouverture des plis ».

Informé, ainsi, du rejet implicite de sa proposition, Global Sourcing Solutions (GSS) saisit le CRD par lettre du 2 septembre 2014, pour lui demander de le rétablir dans ses droits afin de lui permettre de soumissionner dans les mêmes conditions que les autres candidats.

Ayant déclaré le recours recevable, par décision n°242 du 10 septembre 2014, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et a sollicité de l'autorité contractante la transmission des pièces du dossier aux fins d'instruction.

Par décision n°260 du 24 septembre 2014, le CRD ordonna l'annulation et la reprise de la procédure de passation du marché aux motifs que la commission des marchés de l'ADEPME a violé les principes d'égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique, car le requérant ayant déposé son offre le 28 août 2014, il appartenait à la commission des marchés, qui a ouvert les plis le lendemain, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ouvrir sa proposition technique en même temps que celle de tous les autres candidats, en application des articles 67 alinéa 1 du code des marchés publics de 2011 et 24 nouveau du COA.

**DECISION N° 260/14/ARMP/CRD DU 24 SEPTEMBRE 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE GLOBAL SOURCING SOLUTIONS EN
CONTESTATION DE LA NON PRISE EN COMPTE DE SON OFFRE PAR LA COMMISSION
DES MARCHES, LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS CONCERNANT LE MARCHE DE
L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET D'ENCADREMENT DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES (ADEPME), AYANT POUR OBJET LA RECHERCHE D'UN PARTENAIRE PRIVE
POUR LA MISE EN PLACE D'UN CLOUD COMPUTING POUR LES PME**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Global Sourcing Solutions en date du 02 septembre 2014, enregistré le même jour au bureau du courrier, sous le numéro 2530 ;

Vu la consignation faite par le requérant ;

Monsieur René Pascal DIOUF, entendu en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Ibrahima GUEYE, Amacodou DIOUF, Abdourahmane NDOYE assurant respectivement l'intérim de Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et de Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division Appuis techniques et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ;

Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, Chef de la Division Formation, observateurs ;

Par lettre en date du 02 septembre 2014, Global Sourcing Solutions a saisi le CRD en contestation de la non prise en compte de sa proposition technique par la commission des marchés de l'ADEPME, lors de l'ouverture des plis en date du 29 août 2014.

LES FAITS

Dans le journal « L'Observateur » du 06 février 2014, l'ADEPME a fait publier un avis à manifestation d'intérêt ayant pour objet la « recherche de partenaire privé pour la mise en place d'un Cloud Computing pour les PME ».

Après sélection des candidats, des demandes de propositions ont été transmises à Global Sourcing Solutions, AXXEND, CATALYST, SIMEX SA/My TIC SARL, Orange Business Solutions et POPAY.

Après ouverture des propositions techniques, le 29 août 2014, l'ADEPME a saisi le requérant d'une lettre, en date du 01er septembre 2014, pour l'informer de « l'omission de son offre par inadvertance au moment de l'ouverture des plis ».

Informé, ainsi, du rejet implicite de sa proposition, Global Sourcing Solutions a saisi le CRD, par lettre du 02 septembre 2014, pour lui demander de le rétablir dans ses droits.

Ayant déclaré le recours recevable, par décision n°242 du 10 septembre 2014, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l'autorité contractante la transmission des pièces nécessaires aux fins d'instruction.

Par lettre du 17 septembre 2014, l'ADEPME a transmis lesdites pièces.

LES MOYENS A L'APPUI DU RECOURS

Après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure, le requérant demande au CRD de le rétablir dans ses droits afin de lui permettre de soumissionner dans les mêmes conditions que les entreprises concurrentes retenues.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Dans sa lettre de transmission des pièces, l'ADEPME reconnaît que l'offre de Global Sourcing Solutions a été bien reçue le 28 août 2014, mais n'a pas été ouverte, par inadvertance, par les membres de la commission des marchés. C'est après l'ouverture des plis que le constat a été fait.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur les conséquences à tirer de la non prise en compte de l'offre de Global Sourcing Solutions lors de l'ouverture des plis.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 67 du Code des Marchés publics dispose que, à l’expiration des date et heure limites de dépôt des offres, la commission des marchés est chargée de procéder à l’ouverture des plis. Seuls peuvent être ouverts les plis reçus au plus tard aux date et heure limites de dépôt des offres ;

Considérant qu’il est constant, comme résultant de l’extrait du registre de dépôt des offres produit par l’ADEPME, que le 28 août 2014, le requérant, contre décharge, a déposé son offre ;

Qu’à l’ouverture des plis du lendemain, la commission des marchés a omis d’ouvrir sa proposition technique, bien que l’enveloppe contenant ses propositions fût de celles qu’elle avait en sa possession ;

Qu’au regard des règles précitées, il incombait à la commission des marchés de prendre toutes les dispositions idoines pour ouvrir tous les plis des candidats ayant régulièrement déposé leurs offres, dans le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique ;

Qu’en conséquence, en n’ouvrant pas l’offre de Global Sourcing Solutions dont le pli a été reçu avant les date et heure limites de dépôt et était, de surcroit, en sa possession lors de l’ouverture des plis, la commission des marchés de l’ADEPME a violé les principes précités ;

Qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la procédure de passation du marché et d’ordonner sa reprise ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu de procéder à la restitution de la somme consignée ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que l’offre de Global Sourcing Solutions a été déposée avant les date et heures limites arrêtées par l’autorité contractante;
- 2) Constate que la commission des marchés n’a pas ouvert le pli du requérant qu’elle avait en sa possession lors de l’ouverture des plis ;
- 3) Dit qu’en procédant ainsi, la commission des marchés a violé les principes d’égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique;
- 4) Ordonne l’annulation et la reprise de la procédure de passation du marché;
- 5) Ordonne, en outre, la restitution de la consignation ;
- 6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Global Sourcing Computing, à l’ADEPME, ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président
Mademba GUEYE

Ibrahima GUEYE Les membres du CRD **Amacodou DIOUF**
Abdourahmane NDOYE

Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG

Le CRD a rendu beaucoup de décisions sur le fondement de l'article 67, siège des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats (numéros 11 du 14 janvier 2015 ; 73 du 25 mars 2015 ; 180 du 9 juillet 2015...) et à chaque fois que les principes en question ont été violés, il a annulé la procédure de passation du marché.

Le principe de transparence des procédures, le principe de l'égalité de traitement des candidats et le principe de liberté d'accès à la commande publique sont les trois principes fondamentaux du droit de la commande publique.

Au Sénégal, ils sont prévus par l'article 2 de la directive n°04/2005/CM/UEMOA et l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration (COA).

En France c'est l'article 1er II du code des marchés publics qui disposent : « *les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code.* »

Les décisions du Comité de Règlement des Différends vont dans le même sens que la doctrine et la jurisprudence françaises. La doctrine considère que le principe d'égalité de traitement des candidats résulte du principe d'égalité, principe général du droit énoncé dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Ainsi, déjà en 1906, le commissaire du gouvernement Romieu écrivait dans ses conclusions : « le soumissionnaire évincé a le droit de demander l'annulation de l'adjudication pour inobservation des règles fondamentales, même si elles sont édictées dans l'intérêt de l'administration, du moment où une inégalité a été créée entre les concurrents (C.E, 30 mars 1906 Ballande, Rec, page 281).

85

En France et en Europe de nombreuses règles ont été élaborées de même que des solutions jurisprudentielles pour faire respecter les principes d'égalité de traitement et de transparence :

- Les marchés et les critères d'attribution sont définis avec précision (CJCE, 14 octobre 2004, Commission c/France) ;
- Les critères utilisés par le pouvoir adjudicateur pour écarter les candidatures doivent être justifiés et adaptés à l'objet du marché et aux conditions de son exécution (CE, 14 janvier 1998, Ste martin-Fourquin, Rec,p.12) ;
- Le pouvoir adjudicateur doit placer les candidats dans la même situation, en leur fournissant, par exemple, les mêmes informations (CE, 13 mars 1998, SA Transport Galière, n°165238).

Pour la même doctrine, le principe de liberté d'accès à la commande publique veut dire que toute personne ne peut se porter candidate à l'attribution d'un marché public si elle remplit les conditions préalablement fixées par l'Administration.

Certes le pouvoir adjudicateur peut restreindre l'accès à la commande publique, mais à condition que cela résulte de l'objet même du marché ou des conditions de son exécution (CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-Minervois, Rec,p.1035 ; CE, 21 février 2000, syndicat Sud Travail). La liberté d'accès à la commande publique s'applique à tous les marchés publics, quel que soit leur montant (CE, avis cont 29 juillet 2002, Ste MAJ Blanchisseries de Pantin, req. n°246921).

9

LA DETERMINATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONTENUES DANS LE DAO PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE EST SOUMISE AU CONTROLE DE L'ARMP ET DE LA COUR SUPREME

Suivant avis des 31 août et 1er septembre 2013, la SENELEC a publié dans le journal « Le Soleil » un appel d'offres en dix lots, en vue de l'acquisition de matériel roulant pour les besoins de son exploitation.

La société CCBM Industries, par lettre du 5 septembre 2013, a introduit auprès de la SENELEC un recours gracieux tendant à la modification des spécifications techniques contenues dans le dossier d'appel offres (DAO).

N'ayant pas reçu de réponse satisfaisante, elle a saisi le 18 septembre 2013, le CRD, qui a d'abord ordonné la suspension provisoire de la procédure avant de rendre la décision n°27 du 29 janvier 2014 ordonnant la modification des spécifications techniques concernées, faisant ainsi droit à la demande de la société CCBM.

Au soutien de sa décision, le CRD a estimé, d'une part que la référence à un « moteur diesel atmosphérique » revêt un caractère discriminatoire et qu'il y a lieu de modifier le DAO sur ce point en mentionnant « moteur diesel » et que d'autre part, même si l'autorité contractante détient la prérogative de fixer les critères en fonction de l'utilisation de la fourniture, il n'en demeure pas moins vrai que les spécifications techniques devant être fixées de manière à ne pas constituer une entrave à l'accès du marché, au principe de liberté d'accès à la commande publique, il faut donc accéder à la requête de CCBM Industries en fixant la garde au sol à 190 mm minimum, en lieu et place de 200 mm, soit une différence d'un (1) cm, car cela ne peut avoir un impact significatif sur la performance du véhicule et ne peut substantiellement limiter l'usage auquel il est destiné.

**DECISION N° 027/14/ARMP/CRD DU 29 JANVIER 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE CCBM INDUSTRIES EN
CONTESTATION DES SPECIFICATIONS DES TECHNIQUES RELATIVES A L'APPEL
D'OFFRES N° 25/2013 DE LA SENELEC AYANT POUR OBJET
L'ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT POUR L'EXPLOITATION**

88

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société CCBM Industries du 18 septembre 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de MM. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, rapporteur du CRD ;

Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection sur les procédures de passation et d'exécution des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat ; Cheikh Saad Bou SAMB ; Ely Manel FALL, chef de la division Réglementation ; Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation ; Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d'enquêtes à la Cellule d'Enquête et d'Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération :

Par lettre du 18 septembre 2013, la société CCBM Industries a introduit un recours pour contester les spécifications techniques prévues dans le dossier d'appel d'offres relatif à l'acquisition de matériel roulant pour l'exploitation, lancé par SENELEC.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 31 août et du 1er septembre 2013, SENELEC a fait publier un avis d'appel d'offres en dix (10) lots pour l'acquisition de matériel roulant pour l'exploitation. Dès qu'elle a acquis le DAO, l'entreprise CCBM Industries a introduit un recours gracieux par lettre du 05 septembre 2013 pour demander la révision des spécifications techniques.

N'ayant pas été satisfaite de la réponse de SENELEC, CCBM Industries a saisi le CRD par lettre enregistrée le 18 septembre 2013.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n° 307/13 du 08 octobre 2013.

Par correspondance du 22 janvier 2014, reçue le 23 janvier 2014 à l'ARMP, SENELEC a transmis les éléments nécessaires à l'instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, la société CCBM Industries estime que les spécifications techniques du DAO relatives à la garde au sol d'un minimum de 200 mm et à l'exigence d'un moteur diesel atmosphérique sont discriminatoires. C'est pourquoi, le requérant demande la révision des critères.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Face aux griefs de CCBM Industries, l'autorité contractante soutient que le DAO a été élaboré en tenant compte des impératifs d'exploitation mais également dans le respect des procédures de passation des marchés. A ce propos, SENELEC fait observer que les spécifications techniques ne sont pas discriminatoires puisque pouvant être satisfaites par au moins trois marques de véhicules commercialisés au Sénégal par des concessionnaires différents et que lesdites spécifications sont conformes aux exigences de la mission de SENELEC.

Par ailleurs, l'Autorité contractante argue que les critères, tels qu'ils sont fixés, obéissent à un souci de préserver les deniers publics, puisqu'ils permettent de se prémunir contre l'achat de matériel inadapté qui occasionnerait des dépenses inutiles ou répétées.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, moyens et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur le caractère restrictif ou non des spécifications techniques, notamment sur l'exigence d'un moteur de type diesel atmosphérique et la garde au sol de 200 mm.

AU FOND

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du Code des Marchés publics, les autorités contractantes qui envisagent de passer un marché de fournitures, doivent déterminer les besoins au moyen de spécifications techniques contenues dans le Dossier d'appel d'offres (DAO), lesquelles définissent les caractéristiques requises en fonction de l'usage auquel les fournitures sont destinées ;

Qu'à cet égard, le dossier d'appel d'offres a indiqué pour chacun des dix (10) lots, les spécifications techniques requises ;

Considérant que les critères contestés, qui sont relatifs au moteur diesel atmosphérique et à la garde au sol de 200 mm concernant de manière précise, le lot n°1 « pick up » ;

Que, s'agissant du moteur diesel atmosphérique, le CRD a déjà rendu la décision n° 311/13/ARMP/CRD du 09 octobre 2013 concernant la même affaire et qu'à ce propos, le CRD a considéré que la référence à un moteur diesel atmosphérique revêt un caractère discriminatoire et qu'il y a lieu de modifier le DAO sur ce point en mentionnant « moteur diesel » ;

Considérant que pour ce qui concerne la garde au sol, l'autorité contractante a justifié l'exigence d'un minimum de 200 mm par le fait que les véhicules sont utilisés sur des terrains d'accès difficile et souvent impraticables avec des chargements lourds ;

Qu'à cet égard, il importe de retenir que certes l'autorité contractante détient la prérogative de fixer les critères en fonction de l'utilisation de la fourniture, cependant les spécifications techniques doivent être fixées de manière à ne pas constituer une entrave à l'accès au marché ;

Qu'en l'espèce, accéder à la requête de CCBM Industries en fixant la garde au sol à 190 mm minimum en lieu et place de 200 mm, soit une différence d'un (1) centimètre, ne peut, objectivement, avoir un impact significatif sur la performance du véhicule et ne peut substantiellement limiter l'usage auquel il est destiné ;

Qu'en outre, la révision de ce critère permet d'élargir la concurrence et de préserver le principe de liberté d'accès à la commande publique ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réviser les spécifications techniques contestées au lot n°1.

PAR CES MOTIFS

1. Constate que les critères contestés portent sur le lot n°1 « véhicules pick up » ;
2. Dit qu'en ce qui concerne la garde au sol, le fait d'accéder favorablement à la demande de CCBM en la fixant à 190 mm minimum en lieu et place de 200 mm n'induit qu'un écart d'un (1) cm sans incidence manifeste sur la performance ;

3. Dit que la révision de l'exigence relative à la garde au sol est susceptible d'élargir l'accès au marché ;
4. Ordonne la modification des critères relatifs à la garde au sol et au moteur diesel atmosphérique ;
5. Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'entreprise CCBM Industries, à SENELEC ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Les membres du CRD
Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA Boubacar MAR

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saer NIANG**

Par requête reçue le 5 mars 2014 à la Cour Suprême, la SENELEC sollicite l'annulation de cette décision du CRD.

Selon arrêt n°25 du 12 mars 2015, la Cour Suprême rejeta le recours aux motifs que d'une part, il résulte de la combinaison des articles 7 du Code des Marchés publics et 2 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, que le pouvoir de l'autorité contractante quant à la détermination des spécifications techniques dans le DAO n'est pas discrétionnaire, mais soumis au contrôle de l'autorité de régulation et de la juridiction compétente ; que d'autre part, relativement à la modification de la garde au sol, le CRD a suffisamment motivé sa décision, contrairement aux affirmations de la SENELEC.

La notion de spécification technique est définie comme étant : « *l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.* »

La position du CRD et de la Cour Suprême, selon laquelle même s'il appartient à l'autorité contractante de définir la nature et le contenu des spécifications techniques, cette prérogative est cependant soumise au contrôle, est conforme à la jurisprudence française et européenne.

Ainsi, pour elles, « les spécifications techniques doivent permettre l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité.

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits (CJCE, 24 janvier 1995, Commission c/Pays-

Bas, aff. n°C-359/93 ; CE, 11 septembre 2006, Commune de Saran, n°257545 ; annulation d'une décision d'attribution d'un marché de fournitures de pavés au motif d'atteinte au principe d'égalité entre les candidats, car les spécifications techniques des pavés à fournir étaient définies dans le CCTP par référence à une marque précise).

Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle, et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ».

10

**OBLIGATION POUR LA COMMISSION DES
MARCHES DE MOTIVER LE REJET DE L'OFFRE
JUGEE ANORMALEMENT BASSE**

Il résulte de l'article 59-4 du code des marchés publics de 2014 qu'il appartient à la commission des marchés de rejeter par décision motivée une offre qu'elle juge anormalement basse et après avoir demandé des informations et explications de nature à permettre de juger du caractère anormalement faible ou élevé de l'offre financière en tenant compte, en particulier, des sous détails des prix, de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés.

Ainsi, même si une offre manifestement basse par rapport aux prix fixés par les autres soumissionnaires pourrait être suspecte, parce que pouvant traduire la volonté d'un candidat de gagner à tout prix le marché, l'autorité contractante, même si elle a un pouvoir d'appréciation, en la matière, le code lui fait obligation, avant de rejeter une offre qu'elle juge anormalement basse, de motiver sa décision.

Faisant application de ce principe, le CRD, par décision n°208 du 22 juillet 2015, a annulé l'attribution provisoire du marché qui était faite au profit de DISMAT (qui avait proposé 43.029.290 frs CFA TTC), suite au recours contentieux initié par M.N.SE (qui avait proposé 18.129.756 frs CFA TTC).

A l'appui de sa décision, le CRD a fait valoir que l'autorité contractante n'a pas demandé à M.N.SE de justifier le prix de son offre et que la commission des marchés a considéré que son offre est anormalement basse sur le simple constat des écarts entre l'offre de DISMAT et celle de MNSE.

**DECISION N° 208/15/ARMP/CRD DU 22 JUILLET 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT
EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE MAGATTE NDOUR SALL ENTREPRISE
(M.N.S.E.) PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DES
SERVICES REGIONAUX LANCE PAR LE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES.**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014 -1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2007 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Magatte Ndour Sall Entreprise (M.N.S.E.) du 29 juin 2015 ;

Vu la quittance de consignation du 30 juin 2015 ;

Après avoir entendu le rapport de Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Boubacar MAR, assurant l'intérim du Président absent ; Messieurs Samba DIOP et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Messieurs Ousseynou CISSE, Coordonnateur de la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques et Baye Samba DIOP, chef de la

Division de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ci-après :

Par courrier du 29 juin 2015, reçu le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 171/15, la société M.N.S.E. a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD), pour contester l'attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réhabilitation des services régionaux (Diourbel, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor) lancé par le Ministère de l'Industrie et des Mines.

LES FAITS

Le Ministère de l'Industrie et des Mines a obtenu de l'Etat du Sénégal des crédits à travers le budget consolidé d'investissement (BCI) et a l'intention d'utiliser une partie de ces crédits pour effectuer des paiements au titre du marché de travaux de réhabilitation des services régionaux (Diourbel, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor). A ce titre, il a publié dans le journal « Le Quotidien » du 04 mai 2015, une Demande de Renseignement et de Prix à Compétition ouverte du marché relatif aux travaux de réhabilitation des services régionaux de Diourbel, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor.

A l'ouverture des plis, du 18 mai 2015, quatre (04) offres ont été reçues. Les montants lus publiquement se présentent ainsi qu'il suit :

M.N.S.E. : 18 129 756 F CFA TTC ;
7 Vision : 26 058 988 F CFA TTC ;
DISMAT : 43 029 290 F CFA TTC ;
EGM : 40 742 568 F CFA TTC.

Après évaluation des offres, l'Autorité contractante a publié dans le journal « Le Quotidien » du 15 juin 2015, l'avis d'attribution provisoire du marché désignant l'entreprise DISMAT qui a présenté, selon elle, l'offre jugée conforme évaluée la moins disante et remplissant les critères de qualification requis.

Par lettre du 22 juin 2015, la société Magatte Ndour Sall Entreprise M.N.S.E. a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux, auquel cette dernière a répondu défavorablement par courrier reçu le 26 juin 2015.

Non satisfaite de la réponse de l'autorité contractante, la société M.N.S.E. a saisi le CRD par lettre du 29 juin 2015 ;

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure par décision n° 184/15/ARMP du 03 juillet 2015 et a demandé à l'autorité contractante la transmission des pièces constitutives du dossier pour instruction.

Par courrier du 08 juillet 2015, le Ministère de l'Industrie et des Mines a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le requérant déclare que ses techniciens ont minutieusement étudié le dossier et ont proposé l'offre technique et financière la meilleure.

LES MOTIFS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l'offre du requérant, l'autorité contractante estime que la société M.N.S.E. n'a pas tenu compte du volume de travail nécessaire, de la distance qui sépare les localités concernées et des prix réels des articles sur le marché.

L'autorité contractante ajoute que le comité technique a jugé que l'offre du candidat M.N.S.E. ne correspond pas à la réalité économique des travaux compte tenu de leur nature et de leur complexité.

Enfin, l'AC estime que pour toutes ces raisons, elle émet des réserves sur la capacité de l'entreprise M.N.S.E. à réaliser le marché avec un montant de 18 129 756 F CFA TTC.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité du rejet de l'offre de la société M.N.S.E. au motif qu'elle est anormalement basse.

AU FOND

Considérant que dans les Données particulières de l'appel d'offres (DPAO) l'autorité contractante a fourni à la section III un bordereau des prix unitaires et des quantités portant sur les travaux de réhabilitation des services régionaux de Diourbel, de Tambacounda, de Kolda et de Ziguinchor ;

Considérant qu'à l'analyse de l'offre du soumissionnaire on constate qu'il a fourni un bordereau des prix et quantités renseigné suivant toutes les rubriques aux travaux de réhabilitation et d'aménagement des services régionaux des mines de Diourbel, de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor ;

Considérant que la commission des marchés après évaluation des offres a considéré que l'offre de M.N.S.E. est anormalement basse;

Considérant que l'article 59 alinéa 4 du Code des Marchés publics prévoit que la commission peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse, si elle détermine que son montant ne correspond pas à une réalité économique par rapport à la prestation offerte, après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant, en particulier, les sous-détails des prix ;

Considérant que le candidat peut justifier son prix du fait :

- de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
- des conditions exceptionnellement favorables dont il dispose pour exécuter les travaux ou fournir les produits ou services ;
- de la possibilité d'utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives ;

Considérant que l'autorité contractante n'a pas demandé au requérant de justifier le prix de son offre ;

Considérant que la commission a considéré que l'offre du requérant est anormalement basse sur le simple constat des écarts entre l'offre de l'attributaire provisoire et celle du requérant ;

Qu'en conséquence, la commission n'est pas fondée à déclarer que l'offre de l'entreprise M.N.S.E. est anormalement basse ;

Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la reprise de l'évaluation et la demande de justification du prix de l'offre par l'autorité contractante ;

Qu'en conséquence le recours ayant prospéré, il y a lieu d'ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que l'autorité contractante a prévu dans le DPAO, un bordereau des prix unitaires et des quantités portant sur les travaux de réhabilitation des services régionaux de Diourbel, de Tambacounda, de Kolda, de Ziguinchor ;
- 2) Constate que le requérant a fourni un bordereau des prix et quantités renseigné suivant toutes les rubriques aux travaux de réhabilitation et d'aménagement des services régionaux des mines de Diourbel, de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor ;
- 3) Constate que la commission des marchés, après évaluation des offres, a considéré que l'offre de M.N.S.E. est anormalement basse ;
- 4) Constate que l'autorité contractante n'a pas demandé au requérant de justifier le prix de son offre ;
- 5) Dit que la décision de l'autorité contractante de rejeter l'offre de l'entreprise M.N.S.E. au motif qu'elle est anormalement basse n'est pas justifiée ;
- 6) Ordonne, en conséquence, l'annulation de l'attribution provisoire ;
- 7) Ordonne la reprise de l'évaluation sur la base des informations reçues ;
- 8) Ordonne la demande de justification du prix de l'offre par l'autorité contractante et la restitution de la consignation ;
- 9) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'entreprise Magatte Ndour Sall Entreprise (M.N.S.E.) au Ministère de l'Industrie et des Mines ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision, qui sera publiée dans le portail des marchés publics.

**Pour Le Président,
par intérim
Boubacar MAR**

Les membres du CRD
Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

La décision du CRD va dans le même sens que la jurisprudence française.
Cet article 59-4 du code sénégalais des marchés publics est le pendant de l'article 55 du code français des marchés publics.

La doctrine française estime que : « *l'appréciation de la situation se réalise au cas par cas. La collectivité ne peut pas écarter systématiquement cette offre, sous peine de se priver d'économies et de décourager les initiatives des entreprises. Elle vérifie donc sa validité en demandant, par écrit au candidat, des explications relatives à la teneur exacte de son offre (solutions techniques, approvisionnements, organisation du travail, ...) afin de déterminer s'il peut dégager des bénéfices normaux de la réalisation de cette prestation. Si tel n'est pas le cas, l'acheteur se trouve en présence d'une offre anormalement basse de nature à fausser la concurrence et elle doit être écartée* ».

La jurisprudence est abondante en Europe et en France :

1. COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE

CJCE, 15 mai 2008, SECAP SPA contre Commune di Torino, affaires jointes C-147/06 et C-148/06 (modalités d'exclusion des offres anormalement basses – obligations du pouvoir adjudicateur résultant des principes fondamentaux du droit communautaire).

2. CONSEIL D'ETAT

- CE, 28 juillet 1999, Institut Français de Recherche scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM) req. N° 186219 (notion de variante) ;
- CEAss. 5 mars 1999, Président de l'Assemblée Nationale, req. n° 163328 (Distinction entre les marchés publics et les actes parlementaires – offres anormalement basses – Notion d'urgence).

3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

CAA Bordeaux, 17 novembre 2009, SICTOM Nord, req. n° 08BX01571 (validité de la décision de la CAO considérant une offre anormalement basse en l'absence de réponse à sa demande de précisions).

11

**L'APPEL D'OFFRES OUVERT EST LE
PRINCIPE ET L'ENTENTE DIRECTE OBEIT
A DES CONDITIONS LIMITATIVEMENT
ENUMEREES PAR LA LOI**

Le Code des Obligations de l'Administration dispose en son article 26 nouveau, alinéa 1er : « l'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les conditions stipulées par le code des marchés publics.»

Par dérogation à ce principe, l'article 76 du Code des Marchés publics (comme l'article 38 de la directive 4/2005/UEMOA) prévoit la possibilité de conclure un marché par entente directe dans des conditions limitativement énumérées, à savoir en cas de :

- ▶ situation d'exclusivité ;
- ▶ marché complémentaire ;
- ▶ urgence impérieuse ;
- ▶ marchés classés « secret » ;
- ▶ marchés passés dans le cadre de mesure de mobilisation générale.

Ainsi, à chaque fois qu'une autorité contractante saisit la DCMP, soit pour obtenir, selon le cas, son autorisation ou son avis, pour conclure un marché par entente directe, cette Direction chargée du contrôle à priori des marchés publics, vérifie si l'une des conditions visées par l'article 76 susvisé est remplie.

Et si aucune desdites conditions n'existe la DCMP émet un avis négatif. De même que si l'autorité contractante concernée saisit le CRD pour obtenir l'autorisation de poursuivre la procédure, malgré ledit avis, ce dernier, d'une manière générale, en s'appuyant sur les dispositions pertinentes précitées, rejette le recours en ordonnant à l'autorité contractante de conclure le marché dans le respect de la réglementation.

**DECISION N° 042/15/ARMP/CRD DU 18 FEVRIER 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L'AGENCE SENEGALAISE D'ELECTRIFICATION
RURALE VISANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE CONCLURE UN MARCHE PAR
ENTENTE DIRECTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'URGENCE D'ELECTRIFICATION
RURALE (PUER)**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la requête de l'Agence sénégalaise d'Electrification rurale (ASER) en date du 23 janvier 2015 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d'enquêtes à la Cellule d'Enquête et d'Inspection; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 23 janvier 2015, l'Agence sénégalaise d'Electrification rurale (ASER) a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMP pour obtenir l'autorisation de conclure un marché par entente directe avec la société WELDY/LAMONT ASSOCIATES, INC pour la fourniture, le transport et la pose de matériels de réseaux électriques dans différentes régions du pays.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que la saisine du CRD par l'Agence Sénégalaise d'Electrification rurale (ASER), autorité contractante, fait suite à l'avis négatif rendu le 16 janvier 2015 par la DCMP, organe chargé du contrôle a priori des marchés publics;

Qu'elle est fondée sur l'article 142.3 du Code des Marchés publics qui dispose que si l'autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par la direction chargée du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou relatives à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends (CRD) près l'organe chargé de la régulation des marchés publics ;

Considérant que dans ce cas de figure, le Code des Marchés publics ne fixe pas un délai de saisine du CRD ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine de l'ASER recevable.

LES FAITS

Afin de relever de manière significative le taux d'électrification en milieu rural, le Ministère de l'Energie et du Développement des Energies renouvelables a élaboré un programme d'urgence d'électrification rurale dont la stratégie repose, entre autres, sur le Partenariat Public-Privé.

Dans ce cadre, la société Weldy/Lamont Associates, Inc a proposé de réaliser un programme d'électrification de villages identifiés par le Ministère de l'Energie et du Développement des Energies renouvelables et de servir d'intermédiaire entre l'Etat du Sénégal et EXIM BANK US pour le financement.

Ayant considéré que la proposition technique et financière de l'entreprise Weldy/Lamont Associates, Inc est dans l'intérêt du Sénégal, l'ASER a saisi la DCMP afin d'obtenir l'autorisation de conclure un marché par entente directe avec l'entreprise susnommée pour l'électrification par système solaire de plusieurs villages dans différentes régions du Sénégal.

Suite à l'avis négatif de la DCMP, l'ASER a saisi le CRD pour obtenir l'autorisation de poursuivre la procédure.

LES MOYENS A L'APPUI DE LA DEMANDE

Au soutien de sa requête, l'ASER expose que la société Weldy/Lamont Associates, Inc, pressentie pour la conclusion du contrat par entente directe, dispose d'une longue expérience dans le domaine de la réalisation de projets à vocation électrique. Selon l'ASER, Weldy / Lamont Associates, Inc a participé à la réalisation de grands projets de construction de postes à travers le monde, notamment, en Afrique et particulièrement au Ghana dont le dernier projet en cours est d'un montant de 350 millions de dollars US, comprenant à la fois l'électrification rurale, la fourniture de matériels électriques et la construction de postes.

L'ASER indique que la société Weldy/Lamont Associates, Inc a fait une proposition financière acceptée au regard des conditions de financement et de l'intérêt du Sénégal. En outre, l'ASER soutient que le projet, à réaliser par Weldy/Lamont Associates, Inc, s'inscrit dans le cadre global du programme Power Africa, initié par le Gouvernement américain au bénéfice des populations rurales africaines.

C'est ainsi que l'ASER a saisi la DCMP pour obtenir l'autorisation de conclure avec l'entreprise Weldy/Lamont Associates, Inc un marché par entente directe pour l'électrification rurale de villages au Sénégal.

Après l'avis négatif de la DCMP sur la demande, l'ASER a saisi Le CRD pour pouvoir poursuivre la procédure.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

De son côté, la DCMP a rappelé les conditions prévues pour recourir à la procédure d'entente directe, lesquelles sont énumérées à l'article 76 du Code des Marchés publics. L'organe chargé du contrôle a priori des marchés publics fait observer, à ce propos, qu'aucune des conditions susceptibles de motiver une procédure d'entente directe n'est visée par l'ASER pour fonder la décision de contracter par ce mode de passation.

En outre, au sujet de l'intermédiation de l'entreprise Weldy/Lamont Associates, Inc, pour la signature d'un accord de ligne de crédit entre l'Etat du Sénégal et Exim Bank US, la DCMP rappelle que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 3.1 du Code des Marchés publics exigent que l'accord soit signé au préalable.

En conclusion, la DCMP indique que seule la disponibilité de l'accord de prêt pourrait permettre d'émettre un avis sur la demande de l'ASER.

L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de ce qui précède que la demande a pour objet d'obtenir l'autorisation de conclure un marché par entente directe avec la société Weldy/Lamont Associates, Inc pour l'électrification rurale de villages au Sénégal.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du Code des Obligations de l'Administration (COA), l'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation de contrat auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe ;

Que par dérogation au principe sus rappelé, l'article 76 du Code des Marchés publics prévoit la possibilité de conclure un marché par entente directe dans des conditions limitativement énumérées :

- situation d'exclusivité ;
- marché complémentaire ;
- urgence impérieuse ;
- marchés classés « secret » et marchés passés dans le cadre de mesure de mobilisation générale ;

Qu'il ressort de l'examen de la demande de l'ASER qu'aucune des situations ci-dessus énumérées n'est citée comme fondement du recours à la procédure d'entente directe ;

Considérant, par ailleurs, que l'autorité contractante invoque l'intermédiation de la société Weldy/Lamont Associates, Inc entre l'Etat du Sénégal et Exim Bank US pour la signature d'un accord de ligne de crédits ;

Qu'à cet égard, au cas où l'accord de crédit est disponible, la DCMP semble être dans les dispositions d'émettre un avis sur la demande en référence aux dispositions de l'article 3.1 du Code des Marchés publics, relatives aux marchés passés en application d'accords de financement;

Que toutefois, en l'absence de l'accord de financement dans le dossier, d'une part, et étant donné que la demande de l'ASER ne vise aucune des conditions prévues à l'article 76 pour recourir à l'entente directe, d'autre part, le CRD ne peut accéder à la demande de l'ASER ;

Considérant, par ailleurs, qu'en cas de situation d'urgence simple, justifiée, les dispositions du Code des Marchés publics permettent de lancer un appel d'offres ouvert avec des délais réduits ;

Qu'ainsi, l'autorité contractante peut étudier la possibilité de recourir à ce mode de passation en utilisant le modèle de dossier pour les marchés clé en main assortis d'un montage financier ;

Que dans ce cas, en plus de préserver le principe d'égalité d'accès à la commande publique, l'autorité contractante pourra faire participer toute entreprise pouvant proposer un montage financier et boucler la procédure de passation dans des délais réduits ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Déclare la saisine de l'ASER recevable ;
- 2) Constate que l'ASER envisage de conclure le marché par entente directe sans viser l'une des situations prévues par le Code des Marchés publics pour recourir à un tel mode de passation ;
- 3) Constate que l'ASER invoque une intermédiation de l'entreprise Weldy/Lamont Associates, Inc entre l'Etat du Sénégal et Exim Bank US pour le financement du projet sans qu'un accord de crédit ne soit versé dans le dossier ;
- 4) Dit que la demande de l'ASER ne répond pas aux conditions fixées par le Code des Marchés publics pour conclure un marché par entente directe, et ne peut pas, non plus, être examinée sur la base des dispositions de l'article 3.1 dudit Code ;
- 5) Dit qu'il ne peut être autorisé la poursuite de la procédure par entente directe ;
- 6) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'Agence sénégalaise d'Electrification rurale (ASER), ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP **Les membres du CRD**
Boubacar MAR **Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

12

**POURSUITE DE LA CONCLUSION DU MARCHE
PAR ENTENTE DIRECTE SUR CERTIFICATION
DU PREMIER MINISTRE**

En vertu du dernier alinéa de l'article 76 du code de 2014 :

« Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite à l'organe chargé de la régulation des marchés publics et à celui chargé du contrôle des marchés publics que, pour des raisons tenant aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d'intérêt général, l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement. »

C'est ainsi que dans le cadre du marché initié par l'APIX, malgré l'avis négatif émis par la DCMF, le CRD a autorisé à l'APIX, à titre exceptionnel, de conclure par entente directe avec le cabinet SYSTRA le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; le CRD s'est fondé sur le fait que le Premier Ministre a certifié, par lettre du 16 décembre 2014 adressée à l'ARMP, la nécessité d'autoriser la conclusion du contrat au regard de l'intérêt général et des contraintes de délai imposées par le partenaire technique et financier et de l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet (décision CRD n°346 du 17 décembre 2014).

**DECISION N° 346/14/ARMP/CRD DU 17 DECEMBRE 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE APIX SA DE CONCLURE
UN CONTRAT PAR ENTENTE DIRECTE POUR L'ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE
EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DU TRAIN EXPRESS REGIONAL DAKAR-AIBD**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de l'Agence pour la Promotion des Investissements et grands Travaux (APIX) par lettre du 09 décembre 2014, reçue le lendemain au service courrier de l'ARMP ;

Vu la lettre de certification du Premier Ministre en date du 16 décembre 2014

Madame Khadijetou DIA LY, entendue en son rapport ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Mame Aïssatou DIENG TRAORE, chef de la Division Appuis Techniques ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires Juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d'enquête et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :

Par lettre du 09 décembre 2014, enregistrée sous le numéro 347/14, l'APIX a saisi le CRD pour solliciter l'autorisation de passer, par entente directe, le marché relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet du Train Express régional Dakar-AIBD, suite à l'avis négatif de la DCMP.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant que la saisine du CRD par l'APIX, vise l'avis rendu par la DCMP par lettre N°006591/MEFP/DCMP/64 du 04 décembre 2014 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l'article 142.3 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le présent litige oppose l'APIX, en sa qualité d'autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l'article 22 susvisé.

LES FAITS

Par lettre du 04 décembre 2014, l'APIX a transmis à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), une demande pour obtenir l'autorisation de conclure par entente directe, le marché relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet du Train Express régional Dakar-AIBD.

Suite à l'avis négatif émis par la DCMP par lettre du 04 décembre 2014, l'APIX a saisi le CRD par correspondance du 09 décembre 2014 pour pouvoir poursuivre la procédure.

Par la suite, le Premier Ministre par lettre N° 1831/PM/CAB/CS/S.DI du 16 décembre 2014 a adressé une correspondance au Comité de Règlement des Différends pour certifier que la signature du contrat avec le cabinet SYSTRA doit se faire immédiatement pour des motifs d'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article 76 du Code des Marchés publics.

LES MOTIFS DONNES PAR LA SOCIETE APIX S.A

L'autorité contractante justifie la procédure d'entente directe en invoquant les instructions données par Monsieur le Premier Ministre par lettre du 11 novembre 2014, de démarrer sans délais les études préparatoires en vue de la mise en œuvre du projet du Train Express régional DAKAR-AIBD.

Elle informe que ces instructions font suite à la décision de Monsieur le Président de la République du Sénégal de confier à l'APIX la maîtrise d'ouvrage dudit projet. Selon l'autorité contractante, cette situation qui requiert une action immédiate de la part de l'APIX, explique l'urgence impérieuse de contracter avec le cabinet SYSTRA qui possède des références avérées dans le domaine ferroviaire au Sénégal avec la réalisation notamment, de l'étude de faisabilité du développement du transport ferroviaire de la banlieue Dakar-Bargny pour le compte du CETUD.

Pour étayer davantage le caractère urgent du projet, l'APIX informe, en joignant une correspondance de l'Agence française de Développement adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, que les ressources prévues pour financer cette opération seront perdues pour le projet si les études préparatoires y relatives ne sont pas entamées avant le 31 décembre 2014.

Or, explique, l'autorité contractante, la mise en œuvre d'un projet d'une telle complexité requiert au préalable, un accompagnement stratégique et technique par un cabinet expert dans le domaine.

C'est pourquoi, l'APIX demande l'autorisation de contracter directement avec le cabinet SYSTRA pour un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration des supports de présentation du projet et d'un avant-projet sommaire devant permettre de sélectionner le futur opérateur, de valider les études techniques détaillées qui seront menées par ce dernier et l'appui à la procédure de sélection des opérateurs privés.

Elle soutient par ailleurs que la mise en œuvre de ce projet, dans les meilleurs délais est capitale pour la desserte de la Zone économique spéciale de Dakar, du Pôle urbain de Diamniadio, du Parc industriel et surtout de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) dont la mise en service est programmée pour décembre 2015 au plus tard.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a émis un avis négatif au motif que les informations fournies par l'APIX ne permettent pas d'asseoir le caractère impérieux de l'urgence invoquée au regard de l'article 76.2b du CMP qui énumère limitativement les conditions requises pour passer un marché par entente directe.

L'OBJET DE LA DEMANDE :

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande vise à obtenir l'autorisation de conclure par entente directe avec le cabinet SYSTRA, le marché relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le cadre du projet du Train Express régional Dakar-AIBD pour un coût total de 3 205 450 Euros.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu'en vertu de l'article 26 du Code des Obligations de l'Administration, l'appel d'offres ouvert constitue le mode de passation des marchés auquel les autorités contractantes doivent recourir par principe ;

Que par dérogation au principe sus rappelé, il peut être passé un marché selon la procédure d'entente directe dans les conditions prévues à l'article 76 du Code des Marchés publics ;

Considérant qu'aux termes des dispositions dudit article, les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu'après autorisation de la Direction centrale des Marchés publics dans les cas limitativement énumérés, notamment l'urgence impérieuse, la sécurité de l'Etat, le secret défense, à des raisons tenant à la détention d'un droit d'exclusivité... ;

Qu'en référence aux dispositions de l'article précité, la demande de la société APIX SA, comme d'ailleurs relevé par la DCMP, ne s'inscrit dans aucune des situations prévues pour la conclusion d'un marché par entente directe ;

Qu'à cet égard, le caractère d'imprévisibilité de l'urgence ne peut être invoqué pour recourir à une procédure d'entente directe ;

Considérant, toutefois, les risques réels de pertes d'une partie des fonds (5 millions d'euros) destinées à financer les travaux du projet du Train Express Dakar-AIBD qu'encourent l'Etat du Sénégal, si les contrats relatifs aux travaux préparatoires ne sont pas signés au 31 décembre 2014 ; Que ces conditions sont expressément mentionnées dans une correspondance de l'Agence Française de Développement (AFD) en date du 28 novembre 2014 adressée au Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;

Considération qu'en outre, l'article 76 du Code des Marchés publics donne la possibilité au Premier Ministre de certifier par notification écrite à l'ARMP et à la DCMP que, « pour des raisons tenant aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d'intérêt général, l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement »;

Qu'à cet égard, se fondant sur la disposition susvisée, le Premier Ministre a certifié, par lettre du 16 décembre 2014 adressée à l'ARMP, la nécessité d'autoriser la conclusion du contrat avec le cabinet SYSTRA au regard de l'intérêt général et des contraintes de délai imposées par le partenaire technique et financier et de l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet ;

Que, du reste, la mise en œuvre d'une telle infrastructure permettra d'améliorer la mobilité entre Dakar et Diamniadio dans un contexte marqué par l'option des autorités sénégalaises de faire de Diamniadio, une nouvelle ville ;

Qu'à cet égard, la réalisation de ce projet, relève de l'intérêt général avec le développement des transports, l'accroissement du flux des échanges et des retombées économiques qui en résultent pour les populations., outre la facilité d'accès qu'elle permettra aux passagers pour rallier les zones desservies à l'Aéroport International Blaise Diagne ;

Que s'il est vrai que les marchés par entente directe doivent être réduits au strict minimum pour préserver les principes de transparence et de liberté d'accès à la commande publique, il reste cependant entendu que les procédures de passation ne doivent pas empêcher l'exécution des activités confiées aux structures de l'Etat, pour le fonctionnement du service public et la satisfaction des besoins de la collectivité, surtout dans une économie caractérisée par la rareté des ressources ;

Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte de la lettre de Monsieur le Premier Ministre et d'autoriser l'APIX à conclure, à titre exceptionnel, par entente directe, le marché relatif à l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet du train Express Régional Dakar-AIBD afin de ne pas perdre le financement AFD y relatif.

PAR CES MOTIFS :

- 1) Déclare recevable la saisine de la Direction générale d'APIX SA ;
- 2) Constate que l'urgence impérieuse invoquée par l'autorité contractante n'est pas avérée en référence à l'article 76 du Code des Marchés publics ;
- 3) Dit, toutefois, que le caractère urgent est manifeste compte tenu des risques réels de perte d'une partie des fonds destinés à financer le projet Train Express régional Dakar-AIBD, si le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage dudit projet ne serait pas signé au 31 décembre 2014 ;
- 4) Constate que le Premier Ministre a certifié, par lettre adressée à l'ARMP, la poursuite de la procédure comme le lui permet la réglementation au regard de l'intérêt général ; en conséquence ;

- 5) Prend acte de la lettre de Monsieur le Premier Ministre certifiant l'urgence du projet ;
- 6) Autorise, par conséquent, l'APIX à titre exceptionnel, à conclure par entente directe avec le cabinet SYSTRA le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ;
- 7) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'APIX, ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP **Les membres du CRD**
Boubacar MAR **Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

13

**OBLIGATION DE PUBLIER SUR UN SUPPORT
INTERNATIONAL L'AVIS D'APPEL D'OFFRES
INTERNATIONAL**

En vertu de l'article 56-3 du Code des Marchés publics de 2014 « pour les appels d'offres de portée internationale, les avis d'appel public à la concurrence sont également insérés dans une publication à large diffusion internationale. »

De même que l'article 24 nouveau du Code des Obligations de l'Administration stipule que : « le non-respect des formalités de publicité prescrites et la violation du principe d'égalité de traitement des candidats aux commandes publiques par les acheteurs publics entraîne la nullité de la procédure de passation ou du marchés passé, à la requête de toute personne intéressée au déroulement normal de la procédure »

Se fondant sur ces dispositions, la DCMP donne un avis négatif à toutes les procédures ne remplissant pas ces conditions.

Tel a été le cas dans les procédures relatives aux décisions du CRD n°321 du 4 novembre 2015 et 345 du 2 décembre 2015.

Cependant dans toutes les deux affaires le CRD, saisi par l'autorité contractante, a autorisé, à titre exceptionnel, la poursuite de la procédure de passation du marché, après avoir constaté la violation des textes précités.

A l'appui de sa décision, dans la première affaire le CRD a estimé que même si l'avis d'appel d'offres n'a pas été inséré dans une publication « à large diffusion internationale », il n'en demeure pas moins que dix candidats ont retiré le dossier d'appel, dont deux groupements constitués avec des entreprises non communautaires, et que la procédure d'acquisition des ambulances est longue, sans compter que non seulement les procédures de passation des marchés ne doivent pas empêcher l'exécution des activités confiées aux structures de l'Etat, mais également la proposition d'attribution provisoire du marché fait ressortir une économie de presque un milliard et demi de frs CFA, par rapport au budget prévisionnel.

Pour motiver sa décision dans la seconde affaire, le CRD a soutenu que la publication dans le journal « Le Soleil », qui n'a pas été remise en cause par le bailleur de fonds qui souhaite faire démarrer rapidement les travaux d'aménagement, a permis d'obtenir des candidatures étrangères dans le respect des principes de la commande publique et que l'arrêt de la relance de la procédure d'attribution pourrait remettre en cause les objectifs de l'Etat en matière d'autosuffisance en riz.

**DECISION N° 321/15/ARMP/CRD DU 04 NOVEMBRE 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DU MINISTERE DE LA
SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION
DU MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE, ASSORTIE D'UN MONTAGE FINANCIER,
D'AMBULANCES MEDICALISEES D'UNITES MOBILES AU PROFIT DE LA DIRECTION DES
INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DE LA MAINTENANCE**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CR du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre du 29 octobre 2015 du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 29 octobre 2015, reçue et enregistrée le 03 novembre 2015 à l'ARMP, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) a saisi le CRD d'une demande d'autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché, assorti de montage financier, portant sur la fourniture d'ambulances médicalisées et d'unités mobiles suite au refus de la DCMP d'émettre un avis favorable sur le rapport d'analyse qui lui a été soumis.

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant que la saisine du CRD par le MSAS, vise l'avis rendu par la DCMP par lettre N° 004444 MEFP/DCMP/16 du 06 octobre 2015 ;

Que la saisine est basée sur les dispositions de l'article 142.3 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Considérant que le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le MSAS, en sa qualité d'autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l'article 22 susvisé.

LES FAITS

Dans le cadre du programme d'acquisition de véhicules d'évacuation sanitaire et d'unités mobiles, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a décidé de se doter d'un certain nombre d'ambulances médicalisées et d'unités mobiles. A cet effet, il a d'abord, par lettre en date du 30 janvier 2014 introduit auprès du CRD une demande d'autorisation de conclure le marché par entente directe avec la société MECOMAR pour un montant de 9 632 072 590 FCFA ;

Après étude du dossier, le CRD, par décision N° 086/15 du 08 avril 2015, avait estimé que les conditions limitativement listées au niveau de l'article 76 du Code des Marchés publics n'étaient pas réunies pour donner droit à cette demande et avait ordonné, en conséquence, la conclusion du

marché en respectant la réglementation en vigueur.

C'est ainsi que l'avis d'appel d'offres du marché précité, en un lot unique, avait été publié dans le journal « Le Soleil » du 08 juin 2015.

Le 12 juin 2015, la société nouvelle PC PLUS, après avoir acquis le dossier d'appel d'offres a saisi l'autorité contractante d'un recours gracieux sur certains critères du DAO, puis le CRD par lettre du 18 juin 2015 suite à la réponse négative de l'autorité contractante.

Le CRD, après examen du recours qui a été jugée recevable, avait par décision N° 187 du 08 juillet 2015, ordonné de continuer la procédure après avoir exigé la modification d'une des clauses du DAO portant sur la réalisation de marchés similaires.

Après modification de la clause précitée, le MSAS a procédé à la relance de la procédure en publiant l'avis d'appel d'offres dans le journal « Le Soleil » du vendredi 17 juillet 2015.

A l'ouverture des plis du 27 juillet 2015, les montants ci-après ont été lus publiquement pour les deux offres :

1. MECOMAR : 9 997 176 942 FCFA avec la mention « nature du prix non précisée » ;
2. Groupement Auto Ribeio Afrique conception Distribution (AR-ACD) : 7 540 881 584 FCFA.

Au terme de l'évaluation, l'autorité contractante a soumis le rapport d'analyse et la proposition d'attribution à la DCMP pour avis.

C'est ainsi que la DCMP, après examen du rapport d'analyse et de la proposition d'attribution provisoire du marché qui lui a été soumis pour avis, a, par lettre en date du 06 octobre 2015, réservé son avis de non objection et recommandé à l'autorité contractante, pour la poursuite de la procédure, de se référer à l'ARMP.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Dans sa lettre, la DCMP soutient ne pas pouvoir émettre d'avis sur le rapport d'analyse et la proposition d'attribution provisoire du marché au motif que l'avis d'appel d'offres international n'a pas été publié sur un support international comme exigé par l'article 56.3 du Code des Marchés publics.

LES ARGUMENTS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

A l'appui de sa demande, le MSAS soutient qu'en dépit de l'absence de publication de l'avis d'appel d'offres sur un support international, dix candidats ont retiré le DAO. Il précise qu'à la date d'ouverture des plis deux offres ont été reçues. Il soutient, par ailleurs sur le registre financier, que la proposition d'attribution du marché soumis à la DCMP permettrait à l'Etat de faire une économie de près de 1 459 118 416 FCFA au regard du budget du marché estimé à près de 9 milliards de F CFA. Il invoque, par ailleurs, la longueur du processus d'acquisition du matériel roulant, objet de la présente demande, initiée depuis janvier 2015 et qui n'a toujours pas abouti alors que le besoin des populations est plus que réel et pressant avec la mortalité maternelle et infantile, et plus généralement le besoin de la prise en charge des urgences sanitaires.

OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que la demande vise à obtenir, l'autorisation du CRD, pour poursuivre la procédure d'acquisition d'ambulances et d'unités mobiles, suite à l'avis négatif de la DCMP, pour défaut de publication de l'avis d'appel d'offres sur un support international.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant que l'autorité contractante a fait publier l'avis d'appel d'offres international relatif au marché d'acquisition de 162 ambulances et 04 unités mobiles dans le journal « Le Soleil » des 17, 18 et 19 juillet 2015 ;

Que ce faisant, l'autorité contractante n'a pas respecté les dispositions de l'article 56.3 du Code des Marchés publics qui dispose que pour les appels d'offres de portée internationale, les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans une publication à large diffusion internationale ;

Que sous ce rapport, la DCMP a rejeté, à raison, le rapport d'analyse et la proposition d'attribution du marché, pour défaut de publication de l'avis d'appel d'offres international y afférent sur un support international ;

Considérant toutefois, que même si l'avis d'appel d'offres n'a pas fait l'objet de publication dans un journal international, il n'en demeure pas moins, comme rappelé par l'autorité contractante, que dix (10) candidats ont retiré le Dossier d'appels d'offres (DAO) dont deux groupements constitués avec des entreprises non communautaires ;

Qu'ainsi, le manquement lié à l'exigence de portée internationale du support de publicité est atténué par la participation desdites entreprises ;

Considérant, par ailleurs, la longueur constatée du processus d'acquisition des ambulances, initié depuis janvier 2015 et toujours pas achevé malgré le besoin réel et pressant des populations vulnérables dans ce secteur particulièrement sensible où le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a la lourde responsabilité d'endiguer non seulement la mortalité infantile et maternelle mais également de prendre en charge, de manière générale, toutes les urgences sanitaires ;

Que s'il est vrai que le strict respect des procédures de passation des marchés publics a pour objectif de concourir, entre autres, à renforcer les principes de transparence, de liberté d'accès à la commande publique, il reste cependant entendu, que les procédures de passation des marchés ne doivent pas empêcher l'exécution des activités confiées aux structures de l'Etat pour le fonctionnement du service public et la satisfaction des besoins de la collectivité, spécifiquement, pour ce qui est de l'exécution d'une politique prioritaire ;

Qu'il s'y ajoute que la proposition d'attribution provisoire du marché fait ressortir une économie d'un milliard quatre cent cinquante neuf millions cent dix huit mille quatre cent seize (1 459 118 416) F CFA par rapport au budget prévisionnel du marché qui se chiffre à neuf milliards (9 000 000 000) de F CFA ;

Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser, à titre exceptionnel, la poursuite de la procédure de la procédure de passation du marché d'acquisition de cent soixante deux (162) ambulances et quatre (04) unités mobiles au profit des structures sanitaires du Sénégal.

PAR CES MOTIFS :

- 1) Déclare recevable la saisine du Ministère de la Santé et de l'Action sociale ;
- 2) Constate que l'avis d'appel d'offres international a été publié dans un quotidien national en lieu et place d'un support international comme requis par l'article 56.3 du Code des Marchés publics ;
- 3) Constate que, malgré le support de publicité dénoncé, deux entreprises non communautaires ont pris part à l'appel à la concurrence ;
- 4) Dit, ainsi que le manquement lié à l'exigence de portée internationale du support de publicité est atténué par la participation des deux entreprises susmentionnées ;
- 5) Dit, en outre, que l'objectif d'efficacité de la commande publique ne milite pas en faveur de l'annulation de la procédure au regard, d'une part, de la longueur de la procédure, et, d'autre part, de la nécessité de soulager les populations vulnérables ;
- 6) Autorise, à titre exceptionnel, la poursuite de la procédure de passation du marché d'acquisition de cent soixante deux (162) ambulances et quatre (04) unités mobiles au profit des structures sanitaires du Sénégal ;
- 7) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au Ministère de la Santé et de l'Action sociale ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.

Le Président
Mademba GUEYE

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général,
Rapporteur
Saër NIANG

**DECISION N° 345/15/ARMP/CRD 2 DECEMBRE 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET
D'EXPLOITATION DES TERRES DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL ET DES VALLEES DE
LA FALEME (SAED) CONTESTANT L'AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP PORTANT SUR LE
MODE DE PUBLICITE DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE
GENIE CIVIL DES PERIMETRES IRRIGUES DES OUVRAGES DE CONTRÔLE DES CUVETTES
DE DECRUE DANS LE CADRE DU PROJET D'APPUI A L'AGRICULTURE IRRIGUÉE ET AU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERROIRS RURAUX DE PODOR (AIDEP)**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CR du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre du 20 novembre 2015 du Directeur général de la Société nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) ;

Monsieur Moustapha NGAIDO, Commissaire à la Cellule d'Instruction des Recours, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Madame Khadidjatou Dia LY assurant l'intérim du Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assistée par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre datée du 20 novembre 2015, reçue le 23 novembre 2015 au service du courrier, puis enregistrée le lendemain sous le numéro 329/15 au Secrétariat du CRD, la Société nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), a saisi le CRD d'une demande d'autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché de travaux par Appel d'Offres International (AOI) no 2015/27 pour le marché visé en objet, suite à l'avis défavorable de la DCMP sur la décision d'attribution provisoire dudit marché.

117

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE

Considérant que la saisine du Comité de Règlement des Différends (CRD), par le Directeur général de la SAED, fait suite à l'avis négatif rendu par la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), suivant la proposition d'attribution provisoire du marché visé en objet, par lettre no 003643 CPM/DG/SAED du 20 novembre 2015 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l'article 142.3 du décret no 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Considérant que le décret no 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les litiges entre les organes de l'Administration intervenant notamment dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics ;

Considérant que le différend oppose la Société nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Société nationale, en sa qualité d'autorité contractante, à la DCMP, organe chargé du contrôle a priori de la passation des marchés publics ;

Considérant que le Code des Marchés publics ne fixe pas, dans ce cas de figure, un délai de saisine du CRD ;

Qu'il y a lieu de déclarer la saisine du Directeur Général de la SAED recevable, en application de l'article 22 du décret no 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP.

LES FAITS

La SAED a lancé dans le journal « Le Soleil » du 24 août 2015, un avis d'appel d'offres international portant sur la réalisation des travaux de terrassement et de génie civil des périmètres irrigués et des ouvrages de contrôle des cuvettes de décrue répartis en deux (2) lots :

- lot 1 relatif aux travaux de terrassement et de génie civil pour la réhabilitation et l'extension de 48 périmètres irrigués villageois et la construction de quatre (4) ouvrages de contrôle de cuvettes de décrue ;
- lot 2 relatif aux travaux de terrassement et de génie civil pour la réhabilitation et l'extension de périmètres irrigués villageois.

La SAED a obtenu les avis de non-objection de la DCMP et du bailleur de fonds (Agence française de Développement), respectivement le 8 juillet 2015 et le 3 août 2015.

Le 8 octobre 2015, l'ouverture des plis a été effectuée par la commission des marchés de la SAED.

Pour douze (12) dossiers retirés, cinq (5) candidats ont soumissionné. Les montants des offres sont présentés dans le tableau suivant :

Liste des candidats	Lots	Montants en FCFA HT/HD	Montants en FCFA HTVA	Montants en FCFA TTC
	Lot 1			
Groupelement CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING CO & SOTRACOM		5 176 579 178		6 108 363 430
MARCO OBRA PUBLICA		5 976 492 822		7 052 261 530
CGC INT		5 501 843 677		6 492 175 539
EIFPAGE Sénégal		7 130 425 701	7 221 943 308	8 521 893 103
	Lot 2			
Groupelement CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING CO & SOTRACOM		4 579 952 395		5 404 343 826
MARCO OBRA PUBLICA		5 172 774 099		6 103 873 437
CGC INT		4 064 032 993		4 795 558 932
EIFPAGE Sénégal		6 370 508 113	6 429 604 681	7 586 933 524
RC CONSTRUCOES		5 225 000 000		6 165 500 000

Le procès-verbal d'ouverture des plis a été remis aux soumissionnaires et un comité technique mis en place pour procéder à l'évaluation des offres.

Le 22 octobre 2015, la commission des marchés, après analyse du rapport du comité technique, a procédé à l'attribution provisoire du lot 1 à l'entreprise MARCO OBRA PUBLICA pour un montant de 7 052 261 530 FCFA TTC et le lot 2 à l'entreprise CGC INT'L pour un montant de 4 795 558 932 F CFA en TTC.

Les documents relatifs au marché ont été transmis à la DCMP/Pôle de Saint-Louis pour avis, le 26 octobre 2015, avant la transmission à l'Agence française de Développement, bailleur de fonds.

Par courrier no 01389/MEFP/DCMP/SRMPPS/101 du 30 octobre 2015, la DCMP a demandé de fournir des documents complémentaires.

La SAED, par courrier no 3503/SAED/DG/CPM, du 5 novembre 2015 a transmis les offres des candidats, ainsi que les précisions sur le procès-verbal d'ouverture des plis et sur la publication de l'AOI dans un support à large diffusion internationale.

En réponse, la DCMP, par courrier no 001416/MEFP/DCMP/SRMPPS/114 du 9 novembre 2015 a exprimé des réserves sur le support utilisé en se fondant sur la décision no 78/ARMP/CRD du 16 juillet 2012 et a refusé d'émettre un avis favorable pour la poursuite de la procédure.

Sur la base de ces faits, l'autorité contractante saisit l'ARMP le 20 novembre 2015 pour solliciter la poursuite de la procédure de passation du marché susvisé.

LES MOYENS A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de sa demande, la SAED a retracé l'historique de la procédure, marquée à chaque étape par l'avis de non-objection du bailleur de fonds.

Elle ajoute que l'Appel d'offres international relatif au marché de travaux a été publié, le 24 août 2015 dans le quotidien « Le Soleil », en même temps que le marché no 2015/24 relatif à la fourniture et à l'installation d'équipements électriques et électromécaniques dans le cadre du Projet AIDEP. Les deux AOI ayant suivi la même procédure et ont été transmis à la DCMP à la même date. Mais, cette dernière n'a émis un avis défavorable que pour le marché de travaux et ne s'est pas prononcée sur la forme de publicité concernant le marché de fournitures.

Elle allègue que sur les cinq (5) entreprises qui ont déposé leurs offres, quatre (4) sont des entreprises étrangères dont deux (2) ont été déclarées attributaires provisoires.

La SAED estime que la publicité dans un journal à grande diffusion internationale, constitue, certes, une formalité substantielle, mais qu'elle a pris toutes les précautions pour que les soumissionnaires puissent présenter leurs offres dans les délais. Les entreprises étrangères intéressées par les marchés de la SAED ont des représentants au niveau local et ces derniers retirent les DAC après publication des AOI. Les AOI de la SAED ont toujours été publiés à travers le quotidien « Le Soleil » dont les copies sont transmises aux bailleurs de fonds qui n'ont jamais émis d'observations sur le mode de publicité utilisé qui est accessible, disponible, fiable et crédible.

Par ailleurs, la SAED soutient que l'utilisation de l'outil informatique permet de s'abonner gratuitement pour accéder aux appels d'offres publiés. Le principe de l'économie dans les marchés publics justifiant une telle publication nationale.

L'Autorité contractante marque son étonnement quant au fait que la DCMP n'évoque le mode de publicité que pour la première fois en se référant notamment à une décision du CRD du 16 juillet 2012, alors qu'il s'agissait dans ce cas d'espèce d'un appel d'offres en deux étapes et que la relance de la procédure était liée aux critères de qualification et de conformité.

L'Autorité contractante soutient que le démarrage du marché est urgent, car les superficies à aménager sont prises en compte dans le Programme d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture sénégalaise (PRACAS) du Plan Sénégal Emergent et que 60 % des objectifs pour l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017 sont assignés à la Vallée du Fleuve Sénégal et de la Falémé.

Ainsi, la SAED affirme que le bailleur de fonds l'a invitée à accélérer la passation des marchés financés dans le cadre du Projet AIDEP, transmettre les documents y afférents et démarrer les travaux afin que les aménagements soient disponibles pour permettre l'atteinte des objectifs de l'Etat en matière d'autosuffisance en riz pour l'année 2017.

Compte tenu de ce qui précède, la SAED sollicite l'accord du CRD pour la poursuite de la procédure de passation du marché cité en objet.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Dans sa correspondance du 9 novembre 2015, la DCMP relève que les observations antérieurement formulées n'ont pas été prises entièrement en compte et qu'en ce qui concerne le quotidien « Le Soleil », même s'il peut être consulté gratuitement partout dans le monde, il n'a pas vocation à servir de support international.

Elle souligne que la décision n° 78/12/ARMP/CRD du 16 juillet 2012 a rappelé que des supports sont dédiés aux appels d'offres internationaux.

Par ailleurs, la DCMP rappelle l'article 24 du Code des Obligations de l'Administration qui prévoit la nullité de la procédure en cas de non-respect des formalités de publicité prescrites.

En définitive, l'organe chargé du contrôle a priori déclare ne pas être en mesure de formuler un avis favorable sur le dossier.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que l'objet de la requête porte sur la validité du support utilisé par l'autorité contractante pour la publication de l'appel d'offres international.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 56.3 du Code des Marchés publics, que les avis d'appel public à la concurrence sont publiés sur le portail des marchés publics et au moins dans un journal quotidien de grande diffusion et que pour les appels d'offres de portée internationale, les avis publics à la concurrence sont également insérés dans une publication à large diffusion internationale ;

Considérant que le 24 août 2015, la SAED a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil », puis sur son portail web, l'avis d'appel d'offres international AOI n° 2015/27 portant sur le marché litigieux ;

Considérant que l'insertion de l'avis d'appel d'offres international dans le journal « Le Soleil » constitue une publication dans un journal de grande diffusion et non une publication à large diffusion internationale ;

Considérant que lorsque les entreprises étrangères sont visées dans le cadre d'une compétition, la manière la plus adéquate pour les atteindre est de porter l'information sur des supports d'envergure internationale, dédiés à cet effet conformément à l'article 56.3 du Code des Marchés publics ;

Considérant que selon l'article 56.4 un avis d'appel d'offres par voie électronique ne peut être que complémentaire à l'insertion dans une publication à large diffusion internationale ;

Considérant que la DCMP en exigeant l'insertion de l'appel d'offres international no2015/27 de la SAED, dans une publication à large diffusion internationale, n'a fait que rappeler à l'Autorité contractante la nécessité de respecter les dispositions de l'article 56.3 du Code des Marchés publics en s'appuyant sur la décision no 78/12/ARMP/CRD du 16 juillet 2012 de l'ARMP ;

Considérant, par ailleurs, que le non-respect des formalités de publicité prescrites entraîne la nullité de la procédure conformément à l'article 24 du Code des Obligations de l'Administration ;

Ainsi, la décision de la DCMP, de ne pas émettre un avis favorable sur le procès-verbal d'attribution provisoire du marché susvisé, est fondée ;

Considérant, toutefois, que la publication dans le quotidien « Le Soleil » a permis la préservation d'une concurrence saine et loyale dans le marché litigieux ;

Considérant le rôle des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé pour garantir l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en riz en 2017 passe par l'aménagement et l'augmentation du taux de mise en valeur afin d'augmenter la production agricole ;

Considérant que le bailleur de fonds n'a pas remis en cause le mode de publicité de l'autorité contractante qui a permis d'obtenir des candidatures essentiellement étrangères, dans le cadre d'un appel d'offres international, tout en respectant les principes de transparence dans la procédure, et d'égalité de traitement entre les candidats, d'efficacité et d'économie ;

Considérant que le bailleur de fonds, associé à toutes les procédures de passation du marché, souhaite faire démarrer les travaux d'aménagement le plus rapidement pour permettre au Sénégal l'atteinte des objectifs de l'Etat en matière d'autosuffisance en riz, particulièrement, dans les Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé ;

Considérant que l'arrêt de la relance de la procédure d'attribution du marché pourrait remettre en cause les efforts des pouvoirs publics dans la planification de la mise en valeur agricole dans le cadre du PRACAS ;

Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser, à titre exceptionnel, la poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

- 1) Déclare la saisine de la SAED recevable ;
- 2) Constate que la SAED a fait publier dans le quotidien « Le Soleil », sur le site des marchés publics et sur son portail Web, l'avis d'appel d'offres international no 2015/27 portant sur le marché litigieux ;

- 3) Dit que lesdits supports utilisés sont incomplets pour un appel d'offres international, au regard de l'article 56.3 et 56.4 du Code des Marchés publics ;
- 4) Dit, en conséquence, que la DCMP est fondée à réserver son avis ;
- 5) Dit, toutefois, que la reprise de la procédure allongerait les délais et risquerait de compromettre la planification de la mise en valeur agricole pour l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en riz en 2017 ;
- 6) Constate que la procédure a fait l'objet de revue de la part du partenaire technique et financier qui a émis un avis de non-objection sur chaque phase de la procédure ;
- 7) Autorise, à titre exceptionnel, pour l'intérêt national, la poursuite de la procédure ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la SAED et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des Marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA**

**Pour le Directeur général, par intérim,
Rapporteur
Khadijetou Dia LY**

14

**OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ
CONTRACTANTE D'AVOIR UN MINIMUM DE
TROIS SOUMISSIONNAIRES**

En vertu de l'article 74 du code de 2014 « l'autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite un nombre de candidats permettant d'assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à trois. »

De même qu'en application de l'article 67.5 du Code des Marchés publics, lorsqu'un minimum de trois plis n'a pas été remis à la date et heure limites de réception des offres, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze(15) jours ouvrables et qu'elle porte à la connaissance du public.

S'appuyant sur ces dispositions, la DCMP a refusé d'émettre un avis sur la proposition d'attribution provisoire du marché lancé par l'hôpital Youssou Mbargane, relatif à l'acquisition d'un appareil de radiographie par appel d'offres restreint ; en l'espèce, les plis ont été ouverts alors qu'il n'y avait que deux offres, sans l'ouverture d'un nouveau délai au moins égal à quinze jours.

Par décision n°117 du 30 avril 2014, le CRD, après avoir rappelé les dispositions applicables en la matière, a autorisé l'autorité contractante à poursuivre la procédure aux motifs que les deux offres reçues ayant été ouvertes, la reprise de la procédure ne garantit pas forcément les conditions d'une concurrence saine et qu'au regard du temps d'arrêt relativement long de l'appareil de radiographie, la disponibilité d'une nouvelle machine revêt un caractère urgent.

**DECISION N° 117/14/ARMP/CRD DU 30 AVRIL 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DU CENTRE HOSPITALIER YOUSSEU MBAR-
GANE DIOP, SUITE A L'AVIS DEFAVORABLE DE LA DCMP SUR L'ATTRIBUTION PROVI-
SOIRE DU MARCHE RELATIF A L'ACQUISITION D'UN APPAREIL DE RADIOGRAPHIE**

124

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre du 23 avril 2014 du Centre hospitalier (CH) Youssou Mbargane DIOP;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Conseiller technique ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes; Moussa DIAGNE, chef de la Division de la Formation ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Affaires juridiques et Madame Khadijetou DIA LY, chargée d'enquête à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 23 avril 2014, enregistrée le 25 avril 2014 au service du courrier sous le numéro 1157/14, la Directrice du CH Youssou Mbargane DIOP a saisi le Comité de Règlement des Différends, suite à l'avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics sur l'attribution provisoire du marché relatif à l'acquisition d'un appareil de radiographie, lancé par appel d'offre restreint.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par la Directrice du CH Youssou Mbargane DIOP, autorité contractante, vise l'avis rendu par la DCMP le 05 mars 2014 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l'article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégation de service public ;

Considérant que la présente requête oppose, le CH Youssou Mbargane DIOP, en sa qualité d'autorité contractante, et la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l'article 22 susvisé.

LES FAITS

L'hôpital Youssou Mbargane est un établissement public de Santé de niveau 1 érigé depuis 2010, qui a commencé à fonctionner réellement comme EPS en 2012 parce que les différents organes n'étaient pas encore mis en place.

Suite à la détérioration de son appareil de radiographie depuis 2011. Le Conseil d'administration a autorisé l'acquisition d'un nouvel appareil en octobre 2013. Il entame la procédure d'acquisition après avis de la DCMP qui a autorisé l'appel d'offres restreint en invitant les entreprises suivantes :

- Carrefour médical ;
- Delta médical fermond ;
- Science and Technology Engineering (STE);
- La maison du médecin ;
- Clément Santé SARL ;

En cours d'exécution notamment au moment de l'ouverture des plis, il a été par méconnaissance en séance publique procédé à l'ouverture avec seulement deux candidats soumissionnaires, ce qui est contraire à la réglementation. Après une saisine par la DCMP, l'on a voulu corriger mais il y avait déjà vice de forme.

Ainsi, après plusieurs correspondances avec cette dernière, la DCMP a suggéré de se rapprocher de l'ARMP pour la possibilité ou non de continuer la procédure.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient que l'hôpital YoussouMbargane est le seul du département et il couvre la zone de Sangalkam, Jaxay, Bambilor, Yenne, Sébikotane, Diamniadio et Mbao. Il reçoit même des patients de la périphérie de Thiès, comme Pout... En plus, il est dans une zone carrefour où il reçoit souvent des traumatisés suite à des accidents sur la voie publique.

Ainsi, le Centre hospitalier souligne que la prise en charge correcte ne peut se faire sans la radiologie. Ce qui fait que les médecins et leurs patients éprouvent beaucoup de difficultés dans la prise en charge des malades. Ce, dans toutes les pathologies.

Dans ce même contexte, l'autorité contractante signale que les services des urgences, du bloc opératoire, de la médecine et de la pédiatrie évacuent les malades à Pikine, Le Dantec, Fann ou HOGGY, induisant des coûts additionnels pour les patients avec une sur-utilisation de l'ambulance.

Enfin, l'hôpital est exposé de plus en plus aux mouvements d'humeur des populations et de l'intersyndicale de l'hôpital puisque la radiographie a cessé de fonctionner depuis deux ans et demi.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

Selon elle, un avis d'attribution provisoire a été publié le 20 décembre 2013 dans le quotidien « Le Soleil » pour le présent projet de marché sans avis de non objection.

En outre, des lettres de relance (sans accusés de réception) adressées aux différents candidats sont datées du 12 janvier 2014 pour une ouverture des plis prévue le 25 février 2014.

Ainsi, les informations sus indiquées montrent que les plis ont été ouverts alors que le minimum de trois plis requis n'a pas été reçu et qu'un nouveau délai n'a pas été ouvert, conformément à l'article 67.5 du Code des Marchés publics.

Au regard de ce qui précède, elle ne peut émettre un avis sur la proposition d'attribution provisoire. Toutefois, elle lui a suggéré de saisir l'ARMP afin d'obtenir un avis sur la conduite à tenir.

SUR L'OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la possibilité pour le Centre hospitalier Youssou Mbargane DIOP de poursuivre la passation du marché relatif à l'acquisition d'un appareil de radiographie par appel d'offres restreint, malgré le non respect des dispositions de l'article 67.5 du Code des Marchés publics.

AU FOND

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 74 du Code des Marchés publics, dans le cas d'un appel d'offres restreint, l'autorité contractante est tenue de mettre en concurrence par une consultation écrite, un nombre de candidats permettant d'assurer une concurrence réelle et qui ne peut être inférieur à trois ;

Que dans un tel cas, l'article 67.5 du Code des Marchés publics dispose que lorsqu'un minimum de trois plis n'a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu'elle porte à la connaissance du public ;

Considérant que dans la procédure litigieuse, en présélectionnant six entreprises, l'autorité contractante a respecté le minimum de trois candidats exigé à l'article 74 du Code des Marchés publics pour une mise en concurrence réelle ;

Que toutefois, la poursuite de la procédure avec deux offres, sans ouvrir un nouveau délai au moins égal à quinze (15) jours, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 67.5 du Code des Marchés publics ;

Considérant que l'exigence, dans le cadre d'un appel d'offres restreint, d'un minimum de trois plis pour poursuivre la procédure vise à assurer une concurrence saine, à préserver la transparence et à réduire le risque de pratiques répréhensibles, notamment les ententes illicites ;

Que toutefois, dans la procédure litigieuse, les plis ayant été déjà ouverts et les montants de deux soumissions connus, une reprise de la procédure ne garantit pas la préservation de la transparence et une concurrence saine ;

Considérant qu'il s'y ajoute que le manquement procède moins d'une manœuvre de l'autorité contractante que de sa méconnaissance des règles ; que la disponibilité d'un appareil de radiographie participe à l'amélioration du service public de la santé au bénéfice des populations de Rufisque et environnants qui souffrent de ce manque qui n'a que trop duré ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la capitalisation de la procédure actuelle permet, non seulement de faire l'économie d'une reprise de la procédure alors que les montants des offres sont connus, mais également d'éviter un allongement des délais dans un contexte d'urgence ;

Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la procédure de passation du marché ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que le Centre hospitalier Youssou Mbargane DIOP a pris les dispositions pour respecter les exigences de l'article 74 du Code des marchés publics en invitant cinq candidats ;
- 2) Dit que la poursuite de la procédure avec seulement deux offres, sans ouvrir un nouveau délai au moins égal à quinze (15) jours, resté sans effet, n'est pas conforme à l'esprit de l'article 67.5 du Code des Marchés publics ;
- 3) Dit toutefois que les deux offres reçues ayant été ouvertes, la reprise de la procédure ne garantit pas forcément les conditions d'une concurrence saine ;
- 4) Dit qu'au regard du temps d'arrêt relativement long de l'appareil de radiographie, la disponibilité d'une nouvelle machine revêt un caractère urgent ;

- 5) Dit en conséquence que pour préserver les intérêts des populations, le Centre hospitalier Youssou Mbargane DIOP est autorisé à poursuivre la procédure de passation du marché en question ;
- 6) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Centre hospitalier Youssou Mbargane DIOP et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président
Mademba GUEYE

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR

Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG

15

**DENONCIATION D'IRREGULARITES :
EXCLUSION DU FAUSSAIRE DES MARCHES
PUBLICS ET DES DELEGUATIONS DE
SERVICE PUBLIC**

Aux termes de l'article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) : « *Le Comité de Règlement des Différends est chargé de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission des litiges, soit le Comité en formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à l'exécution des marchés publics, il saisit le Comité en formation disciplinaire ; s'ils constituent une infraction pénale, il saisit les juridictions compétentes,* ».

De 2008 à 2013, quatorze (14) décisions de sanction ont été prononcées par le CRD sur la base de dénonciation d'irrégularités commises par les acteurs de la commande publique, soit une moyenne de 2,3 sanctions par an pendant les six (6) ans.

Certaines de ces irrégularités étaient reprochées aux autorités contractantes alors que d'autres étaient reprochées aux candidats et aux attributaires.

Par contre, pendant les deux années 2014 à 2015, une seule sanction a été prononcée et concerne la seule année 2015, soit une moyenne de 0.5 par an.

Cette baisse du nombre de sanctions enregistrées entre les deux périodes semble traduire, à priori, une prise de conscience des acteurs de la commande publique quant à l'existence d'une sentinelle contrôlant le système.

La seule sanction prononcée en 2015 concerne l'entreprise MATEBAT et son gérant Oumar PAYE. En effet, dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction de six (6) salles de classe et de trois (3) blocs d'hygiène dans trois (3) écoles élémentaires de la Communauté rurale de SanthiabaManjaque, l'entreprise MATEBAT a fait parvenir à l'AGETIP une demande de restitution de sa retenue de garantie après le dépôt d'une caution bancaire supposée être délivrée par la SGBS. Ladite banque ayant déclaré que le document en question est faux et n'a jamais été délivré par ses services, l'AGETIP saisit le CRD.

Entendu sur les faits, le gérant Oumar Faye reconnu que la caution est fausse.

Par décision n° 189 du 8 juillet 2015, le CRD, après avoir déclaré que MATEBAT a violé les règles de passation des marchés publics, fait prévu et puni par l'article 148 du Code des Marchés publics de 2014, a prononcé, en application de l'article 149 du code, l'exclusion de MATEBAT et de son gérant Oumar PAYE des marchés publics et délégations de service public pour une durée de six (6) mois.

**DECISION N° 189/15/ARMP/CRD DU 08 JUILLET 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
FORMATION DISCIPLINAIRE SUR DES FAITS DE PRODUCTION PAR LA
SOCIETE MATEBAT D'UNE FAUSSE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE DANS LE
CADRE DU MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION DE 6 SALLES DE CLASSE ET DE 3
BLOCS D'HYGIENE DANS 3 ECOLES ELEMENTAIRES DE LA COMMUNAUTE RURALE DE
SANTHIABA MANJAQUE**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la lettre n°TEC/460/15 du 16 mars 2015 de l'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt public contre le Sous-Emploi (AGETIP);

Vu le procès-verbal d'audition du 07 juillet 2015 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD);

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou Dia LY, chargée d'enquêtes ; Takia Nafissatou Carvalho FALL, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques et Baye Samba DIOP, chef de la Division Régulation et Affaires Juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, le CRD peut recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Que si ces faits caractérisent des violations de la réglementation relative à la passation des marchés publics, le Président du Comité saisit, soit la Commission Litiges, soit le Comité en Formation Disciplinaire selon le cas ;

Qu'en application de cette disposition, le Président du CRD a saisi la Formation disciplinaire des faits de production d'une fausse caution de retenue de garantie, produite par la société MATEBAT dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction de six (6) salles de classe et de 3 blocs d'hygiène dans trois (3) écoles élémentaires de la Communauté rurale de Santhiaba Manjaque, département d'Oussouye.

LES FAITS

Dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction de 6 salles de classe et de trois (3) blocs d'hygiène dans 3 écoles élémentaires de la Communauté rurale de Santhiaba Manjaque, l'entreprise MATEBAT a fait parvenir à l'AGETIP une demande de restitution de sa retenue de garantie après le dépôt d'une caution bancaire, supposée être délivrée par la SGBS.

Conformément aux procédures de l'AGETIP, une demande a été adressée à la SGBS pour authentification de la caution avant de procéder au paiement. En réponse, la banque susnommée a affirmé que le document supposé représenter la caution est faux et n'a jamais été délivré par ses services.

Ainsi, considérant l'acte de MATEBAT comme du faux et usage de faux en écriture privée, l'AGETIP a saisi le CRD pour que les dispositions nécessaires soient prises conformément à la réglementation.

Afin d'instruire le dossier dans le respect du principe du contradictoire, une procédure a été entamée pour recueillir la version du responsable principal de l'entreprise mise en cause.

AU FOND.

Considérant qu'il est constant que pour recevoir le montant correspondant à la retenue de garantie, l'entreprise MATEBAT a transmis à l'AGETIP, une caution de retenue de garantie qu'aurait délivrée la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) le 03 mars 2015 pour un montant de 5 632 794 francs CFA;

Considérant que la vérification effectuée par l'AGETIP, conformément à ses procédures, a révélé que le document est un faux et n'a jamais été délivré par la SGBS ;

Considérant que pour les besoins de l'instruction du dossier dans le respect du principe du contradictoire, plusieurs tentatives de recueillir la version du mis en cause sont restées vaines ;

Que finalement, après avoir reçu une mise en demeure servie par voie d'huissier, Monsieur Oumar PAYE, gérant de l'entreprise MATEBAT, s'est finalement présenté à l'ARMP le 07 juillet 2015 pour donner sa version;

Qu'ainsi, entendu sur les faits, Monsieur Oumar Paye a reconnu que la caution est fausse et a justifié son acte par l'empressement de fournir le document exigé par l'AGETIP dans le délai imparti, afin d'éviter la confiscation des sommes constituées en guise de retenue de garantie ;

Que même si Monsieur Oumar PAYE affirme que l'entreprise MATEBAT a réalisé entièrement les travaux jusqu'à leur réception, dans un contexte marqué par une insécurité dans la zone concernée, il reste constant que son aveu suffit pour attester de la violation par l'entreprise MATEBAT et son dirigeant des règles de passation des marchés publics par le biais du dépôt d'une fausse pièce, fait prévu et puni par l'article 148 du Code des Marchés publics ;

Considérant que l'article 149 du Code des Marchés publics prévoit, au titre des sanctions pouvant être prononcées contre les titulaires de marchés coupables de violation des règles de passation des marchés publics, outre la confiscation des garanties constituées par le contrevenant, l'exclusion du droit de concourir pour l'obtention de marchés publics ;

Qu'à cet égard, compte tenu de la fraude manifeste, il y a lieu de prononcer l'exclusion de l'entreprise MATEBAT et de son gérant Oumar PAYE, des marchés publics et délégations de service public pour une durée de six (06) mois, afin de bannir de telles pratiques frauduleuses du système de passation des marchés publics ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Reçoit le Président du CRD en sa saisine ;
- 2) Constate que dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction de six (6) salles de classe et de trois (3) blocs d'hygiène dans trois (3) écoles élémentaires de la Communauté rurale de Santhiaba Manjaque, lancé par l'AGETIP, la société MATEBAT a produit une fausse caution de retenue de garantie ;
- 3) Dit que par cet acte, MATEBAT a violé les règles de passation des marchés publics;
- 4) Prononce, en application de l'article 149 du Code des Marchés publics, l'exclusion de MATEBAT et de son gérant Oumar PAYE des marchés publics et délégations de service public pour une durée de six (06) mois ;
- 5) Dit que la présente décision prend effet à compter de sa notification à MATEBAT, ou à défaut, à compter de la date de sa publication sur le portail des marchés publics ;
- 6) Dit que le Directeur Général de l'ARMP est chargé de notifier à la société MATEBAT, à l'AGETIP et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

**Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

Conscient des graves conséquences du faux, le législateur sénégalais lui a consacré toute une section dans le chapitre du code pénal intitulé « crimes et délits contre la paix publique », pour réprimer le faux sous toutes ses formes, de même que l'usage de faux ; et ces délits font partie des infractions les plus sévèrement réprimées par le juge pénal.

En France, l'article 47 du Code des Marchés publics stipule que : « après la signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements il est fait application, aux torts du titulaire, des conditions de résiliation prévues par le marché ».

L'inexactitude des renseignements et documents devant être produits dans le cadre d'une procédure de commande publique est sévèrement sanctionnée par la résiliation de plein droit aux torts exclusifs du cocontractant, à condition que le contrat contienne des dispositions relatives à la résiliation (Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 septembre 2001, M. Bernard Djaoui, n° 0100956 : conséquences de fausses déclarations sur la situation fiscale et pénale du candidat).

Pénalement, le législateur français a consacré le chapitre premier du titre IV (des atteintes à la confiance publique), du livre quatrième du code pénal, aux faux. L'article 441.1 dispose : « *constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.*

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois (3) ans d'emprisonnement et de 45 000 (quarante-cinq mille) euros d'amende ».

Ainsi, en France aussi, le faux et l'usage de faux sont sévèrement punis.

Pour la jurisprudence, constitue un faux pénalement punissable au sens de l'article 441.1 du code pénal, l'altération frauduleuse de la vérité préjudiciable à autrui, accomplie dans un document faisant titre (crim. 8 juin 1994 ; Bull. crim. N° 228) ; constituent des faux et usage de faux, entrant dans les prévisions des art. 147, 150 et 151 anciens et 441.1 nouveau du code pénal, la falsification de documents ayant un effet probatoire et l'usage de tels documents falsifiés, lorsque l'auteur, quelque soit son mobile, a conscience d'une altération de la vérité susceptible d'occasionner un préjudice (crim. 19 déc. 1996 ; Gaz Palais 1997 – 1, chron. Crim. 82).

Relativement au préjudice, la jurisprudence française précise que « le préjudice, élément constitutif de faux, et dont la simple éventualité suffit pour faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi, est le préjudice matériel, moral ou social, qui a été causé (ou qui aurait pu être causé) par l'existence ou l'usage de la pièce fausse ; il ne se confond pas nécessairement avec le préjudice personnel, né et actuel qui, en sus de tout dommage résultant de l'usage d'une pièce fausse, découle directement pour la victime d'une infraction de la perpétration même de cette infraction (crim. 15 janvier 1969 ; Bull. crim. N° 30) ».

16

**LES MEMBRES DE LA COMMISSION DES
MARCHES DOIVENT ETRE DISTINCTS
DE CEUX DE LA CELLULE DE PASSATION
ET SON PRESIDENT DOIT ETRE UN
FONCTIONNAIRE DE LA HIERARCHIE B OU
UN CADRE OU ASSIMILE**

En vertu de l'article 35 du Code des Marchés de 2014, au niveau de chaque autorité contractante, sont mises en place une commission des marchés chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés ainsi qu'une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Economie des Finances et du Plan (MEFP) après avis de l'organe chargé de la régulation des marchés publics.

C'est l'arrêté n°0864 du 22 janvier 2015 du MEFP qui fixe le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes.

Ledit arrêté fixe le nombre de représentants de l'autorité contractante dans la commission des marchés à quatre dont le président, le directeur financier ou son représentant, le responsable des services techniques ou son représentant, le responsable chargé des approvisionnements des marchés ou son représentant.

L'arrêté précise en son article 3 que tous les membres titulaires et suppléants de la commission des marchés sont nommés par arrêté ou décision de l'autorité contractante et que le rapporteur de ladite commission est désigné parmi les membres de la cellule de passation des marchés.

Ainsi, le rapporteur de la commission des marchés et son suppléant doivent être désignés par l'autorité contractante en dehors de la liste des membres de la commission des marchés.

De même qu'il résulte de l'article 5 dudit arrêté que les membres des commissions marchés et leurs suppléants doivent appartenir au moins à la hiérarchie B, s'ils sont fonctionnaires, et à une catégorie assimilée s'ils sont non-fonctionnaires, s'agissant de l'Etat ou des organismes ou agences non dotés de la personnalité morale et que pour les sociétés étatiques, les établissements publics et agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale, lesdits membres doivent être de niveau cadre assimilé.

S'appuyant sur ces règles, la DCMP a émis un avis négatif sur la constitution de la commission des marchés du Centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNUF) dont le président n'est pas un cadre ou assimilé et dont les membres comprennent également des membres de la cellule de passation des marchés.

Saisi par le Centre hospitalier national universitaire de Fann, suite au refus de la DCMP, le CRD, abondant dans le même sens que la DCMP, a rejeté la demande d'autorisation, en demandant au CHNUF de se conformer à la réglementation, en nommant un président de niveau cadre ou assimilé et en corrigeant la liste des membres de la Commission des marchés.

**DECISION N° 054/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT
EN COMMISSION LITIGES SUR LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES MARCHES DU
CENTRE HOSPITALIER NATIONAL UNIVERSITAIRE DE FANN.**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014 -1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann du 20 février 2015 ;

Monsieur Moussa DIAGNE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs. Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d'enquêtes à la Cellule d'Enquête et d'Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, conseillère chargée de la coordination et du suivi, Messieurs Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes et Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ;

Par lettre reçue le 20 février 2015 à l'ARMP, le Centre Hospitalier National Universitaire de Fann a saisi le CRD d'une demande pour autoriser la composition de la commission des marchés de l'Hôpital avec la présence de membres de la cellule et le maintien de la nomination du président qui est un commis de l'administration. La saisine du CRD fait suite à la lettre de la DCMP du 19 janvier 2015 par laquelle l'organe de contrôle a priori a marqué son objection sur la composition de la commission des marchés du Centre Hospitalier National Universitaire de Fann (CHNUF).

LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUERANT

Au soutien de sa requête, le Centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNUF) expose dans un premier point que les deux membres de la cellule figurant dans la liste des membres de la commission des marchés occupent les postes de rapporteurs comme titulaire et suppléant. Le CHNUF rappelle que les membres de la commission et de la cellule sont ceux de l'année passée et ont été validés par la DCMP. Dans le deuxième point, il explique que le choix porté sur la personne du président de la commission se justifie essentiellement par son expérience en matière de passation des marchés. Il occupe ce poste de président de la commission depuis 2013 et il a bénéficié de différentes formations en marchés publics. Le CHNUF reconnaît cependant que le profil du président proposé ne répond pas tout à fait aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes. Le CHNUF ajoute que le président a obtenu les diplômes équivalents au niveau demandé depuis deux ans et a déposé une demande de reclassement à la fonction publique qui tarde à être traitée. Enfin le CHNUF admet que la suppléance du président adjoint pourrait être une voie de solution, si ce dernier avait les connaissances basiques en matière de passation des marchés.

OBJET DE LA DEMANDE

Il ressort des éléments exposés par le requérant que la demande porte sur l'autorisation de constituer une commission des marchés avec la présence de membres de la cellule en qualité de rapporteurs et le maintien du président en tant que commis de l'administration.

EXAMEN DE LA DEMANDE

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35 du Code des Marchés publics, au niveau de chaque autorité contractante, sont mises en place une commission des marchés chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution provisoire des marchés ainsi qu'une cellule de passation des marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la commission des marchés, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Economie des Finances et du Plan après avis de l'Organe chargé de la régulation des marchés publics ;

Considérant que le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes sont fixés par l'arrêté n° 0864 du 22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie des Finances et du Plan ;

Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté susvisé, fixe le nombre de représentants de l'autorité contractante dans la commission des marchés à quatre (4) dont le président, le directeur financier ou son représentant, le responsable des services techniques ou son représentant, le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté susvisé, prévoit que le président, les autres représentants de l'autorité contractante dans la commission des marchés ainsi que leurs suppléants et, tous les autres membres de la commission sont nommés par arrêté ou décision de ladite autorité. Le rapporteur de la commission des marchés est désigné par l'autorité contractante parmi les membres de la cellule de passation des marchés visée à l'article 35 du Code des Marchés publics et, est tenu à la même obligation de secret que les membres de la commission ;

A cet égard le rapporteur de la commission des marchés et son suppléant doivent être désignés par l'autorité contractante en dehors de la liste des membres de la commission des marchés. Et que pour éviter toute équivoque, l'autorité contractante doit reprendre la désignation du rapporteur et de son suppléant dans une autre liste ;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté susvisé prévoit que pour l'Etat et les organismes ou agences non dotés de la personnalité morale, les représentants des autorités contractantes membres des marchés et leurs suppléants doivent appartenir au moins à la hiérarchie B ou, s'ils sont non fonctionnaires à une catégorie assimilée.

En ce qui concerne les sociétés nationales, les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, les établissements publics et les agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale, ils doivent être de niveau cadre ou assimilé ;

Qu'à ce titre, la nomination d'un président de la commission des marchés, qui n'est pas agent cadre ou assimilé, est contraire à la réglementation en vigueur et que la Direction centrale des Marchés publics est fondée à réserver son avis de non objection ;

Et qu'il y a lieu pour l'autorité contractante de se conformer à la réglementation, d'autant plus qu'elle dispose de personnel ayant le profil recommandé par le Code des Marchés publics ;

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de corriger la liste de la commission des marchés du CNHUF avant de solliciter l’avis de non objection auprès de la Direction centrale des Marchés publics ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que la liste de la commission des marchés comprend deux membres de la cellule de passation des marchés nommés titulaire et suppléant ;
- 2) Constate que le rapporteur de la commission des marchés est désigné par l’autorité contractante parmi les membres de la cellule de passation des marchés ;
- 3) Dit, que le rapporteur de la commission des marchés et son suppléant doivent être désignés par l’autorité contractante en dehors de la liste des membres de la commission des marchés ;
- 4) Dit, que pour éviter toute équivoque, l’autorité contractante doit reprendre la désignation du rapporteur et de son suppléant dans une autre liste ;
- 5) Constate que la nomination du président de la commission des marchés qui n’est pas de la hiérarchie B est contraire à la réglementation en vigueur ;
- 6) Dit, que l’autorité contractante doit se conformer à la réglementation pour la nomination du président qui doit être de niveau cadre ou assimilé ;
- 7) Dit, qu’en conséquence, l’autorité contractante doit corriger la liste de la commission des marchés du CNHUF avant de solliciter l’avis de non objection auprès de la Direction centrale des Marchés publics ;
- 8) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au Centre National Hospitalier Universitaire de Fann ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

En France il existe une Commission des Marchés publics de l’Etat (CMPE) créée par le décret n°2004-1299 du 26 novembre 2004, en remplacement de la Commission technique des Marchés. Elle est chargée de fournir aux ministres et aux personnes responsables des marchés une assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés de l’Etat.

Elle formule des observations et des recommandations concernant ces marchés et peut être saisie par le ministre concerné ou par toute personne responsable du marché d'une demande d'avis sur une difficulté particulière concernant la passation du marché. En accord avec le pouvoir adjudicateur ou à sa demande, cette commission peut décider la mise en place d'une mesure d'assistance à la passation du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre la décision motivée de ne pas saisir la commission lorsque la passation présente un caractère d'urgence impérieuse, dans le respect de conditions strictes édictées par l'article 5 du décret.

Il n'existe pas de jurisprudence relative à la Commission des Marchés publics de l'Etat.

17

**L'AUGMENTATION DES FOURNITURES
RESULTANT D'UN AVENANT NE PEUT
DEPASSER 30% DU MONTANT INITIAL**

En vertu de l'article 24 du code de 2014, « *l'augmentation ou la réduction des fournitures, services ou travaux résultant d'un ou plusieurs avenants ne doit dans aucun cas, dépasser 30% du montant du marché initial, après application des éventuelles clauses d'actualisation et de révision.* »

Se fondant sur cette disposition, le CRD, par décision n°309 du 28 octobre 2015, a rejeté la demande du CEREEQ visant à obtenir l'autorisation de conclure un avenant au marché de base et dont l'effet aurait abouti d'augmenter de 140% le marché initial.

**DECISION N° 309/15/ARMP/CRD DU 28 OCTOBRE 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DU CENTRE EXPERIMENTAL
DE RECHERCHES ET D'ETUDES POUR L'EQUIPEMENT VISANT A OBTENIR
L'AUTORISATION DE SIGNER UN AVENANT AU MARCHE D'ACQUISITION DE VEHICULES
POUR L'ANNEE 2016**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration, modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande du Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes pour l'Equipement (CEREEQ-S.A), par correspondance du 14 octobre 2015 ;

Monsieur Ousseynou CISSE, entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance du 14 octobre 2015, reçue le lendemain au service courrier de l'ARMP, le Directeur général du CEREEQ a saisi le Comité de Règlement des Différends pour solliciter l'autorisation de conclure un avenant au marché d'acquisition de trois (03) véhicules, conclu avec la Sénégalaise de l'Automobile.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 2.5 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007, l'ARMP est chargée de veiller, par ses avis et recommandations, à l'application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public et de contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence ;

Considérant qu'à ce titre, l'ARMP peut être saisie par toute autorité contractante, tout candidat ou titulaire de marchés sur l'application, le sens ou la portée de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics, délégations de service public, des documents standards, ou des décisions relatives aux procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;

Considérant que dans sa saisine, le Centre expérimental de Recherches et d'Etudes pour l'Équipement (CEREEQ-SA) demande au CRD la possibilité et l'autorisation de conclure un avenant pour disposer de véhicules supplémentaires lorsque les ressources seront disponibles en 2016 ;

Qu'une saisine du CRD dans un tel cas n'est soumise à aucune condition de délai et de forme ;

Qu'ainsi, il y a lieu de déclarer la saisine du CEREEQ recevable.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

A l'appui de sa demande, la Direction générale du CEREEQ expose que dans le cadre de la mise en œuvre des activités issues de son Plan de passation des marchés (PPM) 2015, un appel d'offres ouvert avait été lancé sous le libellé AAO N°F/CEREEQ/004 pour l'acquisition de six (6) véhicules.

Le CEREEQ indique qu'en raison des ponctions opérées sur ses ressources durant la gestion 2015, les quantités ont été réduites de commun accord avec l'attributaire du marché, après en avoir informé la DCMF. C'est ainsi que le montant disponible dans le budget a servi à conclure un marché portant sur un nombre de trois (3) véhicules de type « Pick up ».

Ainsi, pour les trois (03) autres véhicules qui restent (deux véhicules de type station wagon et un pick-up), le CEREEQ souhaite conclure un avenant au marché de base afin de pouvoir les acquérir lorsque le budget de 2016 sera mis en place.

C'est pourquoi, il saisit le CRD pour solliciter l'autorisation de conclure l'avenant avec « La Sénégalaise de l'Automobile », titulaire du marché de base relatif à la fourniture de trois (03) véhicules de type pick-up.

OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le CEREEQ vise à obtenir l'autorisation du CRD pour conclure un avenant au marché de base afin de pouvoir disposer des trois véhicules restants suite à la diminution des quantités du marché initial, lorsque les crédits seront disponibles durant la gestion 2016 .

AU FOND

Considérant que le CEREEQ a initialement lancé un appel d'offres ouvert pour l'acquisition de six (6) véhicules, répartis en deux (2) lots ;

Que cet appel d'offres attribué à la société « La Sénégalaise de l'Automobile » pour un montant de 128 325 000 francs CFA TTC, a fait l'objet d'une réduction des quantités, en raison des crédits disponibles sur le budget 2015 du CEREEQ ;

Qu'ainsi en lieu et place du montant de 128 352 000 francs CFA TTC, initialement attribué, le CEREEQ a conclu avec « La Sénégalaise de l'Automobile » un marché d'un montant de 53 454 000 francs CFA TTC portant sur l'acquisition de trois (3) véhicules de type « Pick up ».

Que dans ces conditions, il est permis d'admettre que le CEREEQ, qui avait lancé un appel d'offres ouvert sur la base de ses besoins initiaux évalués à six (06) véhicules, veuille disposer des trois (3) véhicules restants dès que des ressources additionnelles seront disponibles, soit deux (02) véhicules de type station wagon et un (01) pick-up ;

Considérant, toutefois, que le CEREEQ opte pour la conclusion d'un avenant afin de disposer de ces véhicules en 2016 ; ce qui représente un coût de soixante quatorze millions huit cent quatre vingt dix huit mille (74 898 000) francs CFA TTC ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 du Code des Marchés publics, les modifications des conditions initiales du marché après son approbation doivent faire l'objet d'un avenant écrit, signé par les représentants habilités de l'autorité contractante et du titulaire du marché ;

144

Que certes, selon les dispositions de l'alinéa 2.b de l'article susvisé, l'objet d'un avenant peut porter sur l'augmentation de la masse des fournitures excédant les variations maximales prévues par le Dossier d'Appel d'Offres ;

Que néanmoins, l'article 24 du Code des Marchés publics dispose que l'augmentation des fournitures résultant d'un avenant ne doit, en aucun cas, dépasser 30% du montant initial, après application des éventuelles clauses d'actualisation et de révision ;

Considérant que dans le cas d'espèce, l'avenant aurait pour effet de porter le montant du marché de 53 454 000 francs à 128 325 000 francs CFA, soit une augmentation de 140% du marché initial ;

Qu'il s'ensuit que l'avenant, tel qu'envisagé par le CEREEQ, n'est pas conforme à la réglementation ;

Qu'il s'y ajoute que dans sa saisine, l'autorité contractante n'apporte pas d'éléments nouveaux sur la question budgétaire qui avait motivé la signature d'un marché initial portant sur des quantités de fournitures réduites ;

Que l'avenant sollicité vise l'année budgétaire 2016 alors que l'autorité contractante n'a pas, à ce jour, la certitude de l'existence des crédits prévus sur ledit budget pour pouvoir engager la signature d'un contrat ;

Qu'ainsi, accéder à la demande du CEREEQ reviendrait à autoriser l'acquisition de l'ensemble des six (06) véhicules initialement attribués alors qu'aucun fait nouveau concernant le budget n'est survenu depuis l'immatriculation du marché de base le 15 septembre 2015 ;

Qu'en considération de ce qui précède, la demande d'autorisation du CEREEQ ne peut être autorisée ;

PAR CES MOTIFS

- 1) Constate que l'avenant envisagé concerne un marché de base, conclu après réduction des quantités en raison de problème budgétaire ;
- 2) Constate que la conclusion de cet avenant aurait pour effet d'augmenter le montant du marché de base de 140% ;
- 3) Dit que la conclusion d'un tel avenant n'est pas conforme à la réglementation ;
- 4) Dit que le CEREEQ n'a pas à ce jour, la certitude de l'existence des crédits prévus dans le budget de 2016 pour pouvoir, d'ores et déjà, envisager la conclusion de l'avenant ;
- 5) Recommande au CEREEQ d'entamer, à temps, une procédure de passation de marché par appel d'offres ouvert afin d'acquérir les véhicules restants dans le respect des règles de concurrence ;
- 6) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la Direction générale du CEREEQ ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP **Les membres du CRD**
Boubacar MAR **Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

En effet le montant de l'avenant est un indice de l'absence de bouleversement du contrat initial et le fait de limiter le montant de l'avenant permet de lutter contre la tentation que pourrait avoir l'autorité contractante d'éviter de passer un nouvel appel à la concurrence.

Pour la doctrine française, l'avenant doit être totalement imprévisible. Il est généralement estimé raisonnable d'admettre qu'une augmentation du montant d'un marché par un ou plusieurs avenants successifs, inférieurs à 15% du montant initial de ce marché, ne présente pas, généralement, de caractère abusif.

Le juge saisi statue in concreto ; il a ainsi refusé un avenant augmentant de 18% le montant total d'un marché fractionné (T.A Lille, 8 juillet 1997, Préfet du Pas-de-Calais contre Commune de Lens et autres ; RFDA, 1998, p. 546), tandis qu'il a admis la validité d'une augmentation de près de 38% d'un autre marché (CE 13 juin 1997, Commune d'Aulnay-sous-Bois, réq. N° 150681).

18

**AUTORISATION D'OUVRIR A
L'INTERNATIONAL UN APPEL D'OFFRES**

En vertu de l'article 52 du Code des Marchés publics de 2011, la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l'article 2 du même code est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que, toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent lorsque l'appel d'offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l'accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires, constitués conformément aux dispositions de l'article 47 du même texte ;

Voulant produire des vaccins vétérinaires compétitifs, l'Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) saisit le CRD d'une demande d'autorisation de lancer un appel d'offres international pour l'acquisition des intrants rentrant dans la composition desdits vaccins.

Par décision n°165 du 25 janvier 2014, le CRD autorisa ladite ouverture aux motifs que d'une part l'étroitesse d'un marché du fait de la présence d'un nombre limité d'offres peut avoir pour conséquence des pratiques de prix prohibitifs imposées par ces opérations impactant négativement sur la compétitivité et que d'autre part la mise en concurrence vise à obtenir le meilleur rapport qualité/prix, le prix étant largement déterminé par le niveau de la compétition.

**DECISION N° 165/14/ARMP/CRD DU 25 JUIN 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L'INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES
AGRICOLES (ISRA) POUR UNE AUTORISATION DE LANCER UN APPEL D'OFFRES
INTERNATIONAL POUR L'ACQUISITION D'INTRANTS.**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de l'Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA);

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, rapporteur ;

En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Baye Samba DIOP, chef de la Division Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d'enquête à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division Appuis techniques et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; observateurs.

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des Marchés publics et des principes généraux de la régulation;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 03 juin 2014, enregistrée le 11 juin 2014 au service courrier puis le 12 juin 2014 au secrétariat du CRD sous le numéro 169/14, l'Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) a saisi le Comité de Règlement des Différends d'une demande d'autorisation de lancer un appel d'offres international pour l'acquisition des intrants.

A l'appui de sa demande, il soutient que dans le cadre de ses résultats de recherches, l'institut dispose d'un laboratoire de production de vaccins vétérinaires pour lutter contre les principales épizooties.

Ainsi, pour elle, les vaccins produits par l'ISRA sont réputés de qualité et sont préférés par les clients. Plusieurs pays d'Afrique comptent sur les vaccins de l'ISRA pour mener à bien leur campagne nationale de prophylaxie ; et particulièrement le Sénégal, avec le Ministère de l'Elevage.

Cependant, selon le requérant, le ratio qualité/prix pour rester compétitif exige que l'ISRA s'approvisionne sur le marché international des intrants, rentrant dans la composition des vaccins. Cela lui permettrait de maintenir ses coûts de production à un niveau similaire à ceux des laboratoires concurrents.

Il souligne, également, que cette proposition est d'autant plus nécessaire que les intrants qui rentrent dans la composition des vaccins ne sont pas produits en Afrique, encore moins au Sénégal.

L'ISRA informe, dans le même ordre d'idées, que le marché sous régional des vaccins, du fait de son ouverture à tous les laboratoires africains titulaires d'une AMM (Autorisation de mise sur le sous-regional marché), est plus que concurrentiel.

En outre, il rappelle que les appels d'offres nationaux ne font participer que des soumissionnaires locaux qui, d'ordinaire, proposent des prix prohibitifs. Ces prix vont renchérir le prix de revient des vaccins et placer l'ISRA dans une position de faible compétitivité. Cette situation va prévaloir aussi longtemps que l'ISRA continuera de s'approvisionner à travers des fournisseurs locaux qui proposent des prix abusifs.

Enfin, l'autorité contractante prévoit que l'ambition du Sénégal d'arriver à la couverture zoo sanitaire universelle se heurterait à la faiblesse du pouvoir d'achat des éleveurs face à la cherté des vaccins du fait des intrants.

En considération de ces raisons, l'ISRA sollicite du CRD une autorisation de lancer un appel d'offres international pour toute acquisition d'intrants.

SUR L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la demande porte sur une autorisation exceptionnelle d'ouvrir à l'international des acquisitions d'intrants destinés à la production de vaccins vétérinaires pour lutter contre les principales épizooties, par dérogation aux dispositions de l'article 52 du Code des Marchés publics.

AU FOND

Considérant que l'article 52 du Code des Marchés publics dispose que la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l'article 2 du Code des Marchés publics est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité ;

Que, toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent lorsque l'appel d'offres concerné ne peut être satisfait par les entreprises ci-dessus visées ; l'accès aux marchés concernés est alors autorisé aux groupements réunissant des entreprises communautaires à des entreprises non communautaires et constitués conformément aux dispositions de l'article 47 du même texte ;

Considérant que les moyens invoqués par l'autorité contractante pour solliciter l'ouverture de la procédure sur l'international se réfèrent à une volonté d'être compétitive d'autant plus que les intrants qui entrent dans la composition des vaccins ne sont pas produits en Afrique, encore moins au Sénégal ;

Qu'ainsi, le ratio qualité/prix pour rester compétitif exige que l'ISRA s'approvisionne sur le marché international des intrants, rentrant dans la composition des vaccins ;

Considérant, par ailleurs, que la mise en concurrence vise à obtenir le meilleur rapport qualité/prix et que le prix est largement déterminé par le niveau de la compétition en termes de participation : plus il y a de concurrents, plus le prix est bas ;

Que cela signifie que pour qu'une autorité contractante puisse espérer le maximum de gains relativement aux prix offerts lors d'une procédure de passation de marchés publics, elle doit œuvrer à ouvrir le processus au plus grand nombre possible ; ce qui a pour mérite de rendre contestable la position des entreprises présentes dans un secteur ;

Considérant que l'étroitesse d'un marché du fait de la présence d'un nombre limité d'offres peut avoir pour conséquence des pratiques de prix prohibitifs imposées par ces dernières ;

Que lorsque la plateforme d'échange constitue un marché d'intermédiaires, comme en l'espèce, de telles distorsions vont impacter négativement la compétitivité des consommateurs finaux que sont les entités comme l'ISRA ;

Que l'efficacité de la commande publique doit amener l'autorité contractante à anticiper sur les risques de soumissions concertées ou d'abus de position dominante de la part de potentiels candidats en créant les conditions d'une contestabilité du marché ;

Qu'ainsi, le moyen le plus approprié pour assurer d'un tel dessein est l'ouverture du marché à la concurrence internationale ;

Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser exceptionnellement l'ouverture à l'international pour toute acquisition, par l'ISRA, d'intrants destinés à la production de vaccins vétérinaires pour lutter contre les principales épizooties, par dérogation aux dispositions de l'article 52 du Code des Marchés publics ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Déclare recevable la demande ;
- 2) Dit que l'étroitesse d'un marché du fait de la présence d'un nombre limité d'offres peut avoir pour conséquence des pratiques de prix prohibitifs imposées par ces opérations ;
- 3) Dit que de telles distorsions vont impacter négativement la compétitivité des consommateurs finaux que sont les entités comme l'ISRA lorsque l'on est sur une plateforme d'intermédiaire ;
- 4) Dit que la mise en concurrence vise à obtenir le meilleur rapport qualité/prix et que le prix est largement déterminé par le niveau de la compétition en termes de participation ;
- 5) Dit qu'ouvrir le processus de passation au plus grand nombre possible rend contestable la position des entreprises présentes dans le secteur visé ;
- 6) Dit que le moyen le plus approprié pour assurer cette ambition est l'ouverture du marché à la concurrence internationale ; en conséquence,
- 7) Autorise, exceptionnellement, l'ouverture à l'international pour toute acquisition, par l'ISRA, d'intrants destinés à la production de vaccins vétérinaires pour lutter contre les principales épizooties ;
- 8) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à l'Institut sénégalais de Recherches agricoles et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site des marchés publics.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

En vertu des dispositions du code, susvisées, l'ouverture à l'international ne peut être envisagée que s'il est prouvé l'inexistence, au niveau communautaire, d'entreprises capables de réaliser les prestations sollicitées.

Cela d'ailleurs a été rappelé maintes fois par le CRD (décisions n°264 du 24 septembre 2014, n°315 du 12 novembre 2014...).

En France, l'article 53-IV du Code des Marchés publics accorde un droit de préférence qui ne s'exerce que dans des cas où il existerait égalité de prix ou équivalence des offres entre un organisme protégé (société coopérative ouvrière de production, groupement de producteurs agricoles, artisans, société de coopérative d'artisans ou société de coopérative d'artistes, etc....) et une société commerciale. Souvent les organismes d'insertion des personnes handicapées, comme les ateliers protégés, ne peuvent pas soutenir la concurrence des entreprises purement commerciales.

La CJCE a rappelé maintes fois l'attachement du droit communautaire au principe de transparence, qui est rattaché, entre autres, au principe de non-discrimination en raison de la nationalité (Laure Marcus, « la Jurisprudence de la CJCE sur les marchés publics »).

19

**OBLIGATION POUR L'AUTORITE
CONTRACTANTE DE NE PAS PROCEDER A
UN CLASSEMENT SANS SUITE ABUSIF**

Le Code des Marchés publics de 2011 dispose en ses articles 64 et 65 :

Article 64 :

1. L'autorité contractante, après consultation de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics, peut déclarer un appel d'offres infructueux lorsque selon l'avis de la commission des marchés compétente, aucune offre n'a été remise à l'expiration de la date limite de dépôt des offres ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrecevables ou non conformes, bien que toutes les conditions devant assurer le succès de l'appel à la concurrence aient été remplies.
2. Dans ce cas, l'autorité contractante en avise immédiatement tous les candidats. Elle peut alors procéder soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un appel d'offres restreint conformément aux articles 73 et 74 du présent décret.

Article 65 :

L'autorité contractante peut, après consultation de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics, ne pas donner suite à un appel d'offres pour des motifs d'intérêt général, tels que la disparition du besoin qui était à l'origine de la procédure ou des montants d'offres trop élevés par rapport à la valeur estimée du marché.

Suite à l'appel d'offre lancé par l'APIX et relatif aux travaux de reconversion du site de la décharge de Mbeubeuss, le Groupement Le Floch Dépollution/ CSE a été déclaré attributaire provisoire du marché et la DCMP émit son avis de non objection par la lettre du 13 septembre 2013.

Mais le bailleur n'ayant pas émis d'avis de non objection et ayant proposé la relance de l'appel d'offres, l'APIX adressa au groupement en question une notification de la « décision de déclarer l'appel d'offres sans suite » reçue le 21 juillet 2014.

Le groupement saisit alors le CRD, conformément aux articles 88 et 89 du code de 2011, pour arbitrage en contestant le classement sans suite.

Se fondant sur les dispositions de l'article 64 du code, par décision n°223 du 20 août 2014, le CRD déclara le classement sans suite abusif et ordonna la poursuite de la procédure, en faisant valoir que d'une part les motifs invoqués par le bailleur pour relancer la procédure ne sont ni conformes aux règles du code des marchés ni à ses propres directives et que, d'autre part le risque financier lié au classement sans suite abusif est de loin plus important que celui s'attachant à la provenance des matériaux de couverture et les coûts de transports associés.

DECISION N° 223/14/ARMP/CRD DU 20 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS, STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT D'ENTREPRISES LE FLOCH DE POLLUTION/CSE PORTANT SUR LE CLASSEMENT SANS SUITE DE L'APPEL D'OFFRES DU MARCHE N°APIX/AOI/PADD/01/12, RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONVERSION DE LA DECHARGE DE MBEUBEUSS, LANCE PAR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ET GRANDS TRAVAUX (APIX S.A).

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Groupement d'Entreprises le Floch dépollution/CSE ;

Vu la quittance de consignation du 04 août 2014 ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d'enquête à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Mame Aïssatou DIENG TRAORE, chef de la Division Appuis techniques et, Messieurs Ousseynou CISSE, chargé d'enquête à la Cellule d'Enquêtes et d'Inspection et Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Réglementation et des Affaires juridiques ; observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 1er août 2014, enregistrée le 04 août 2014 au service du courrier sous le numéro 2220, le Groupement d'Entreprises le Floch dépollution/CSE a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester le classement sans suite de l'appel d'offres relatif aux travaux de reconversion du site de la décharge de Mbeubeuss, lancé par APIX S.A.

LES FAITS

Dans les journaux « Le Soleil » et « L'Observateur » du 17 février 2012, et dans le journal « Jeune Afrique » du 19 février 2012, l'APIX S.A a publié un avis d'appel d'offres relatif aux travaux de reconversion du site de la décharge de Mbeubeuss.

Suite à la non objection de la DCMP et de l'IDA sur une nouvelle version du DAO, le dossier a été relancé le 14 juin 2012 sur UNDB et le 16 juin 2012 dans le journal « L'Observateur ».

Ainsi, à la parution dudit avis, dix-huit (18) firmes ont retiré le dossier d'appel d'offres et deux (02) ont déposé leurs offres.

Il s'agit de :

- Groupement Le Floch dépollution/CSE
- New Energy Pty Ltd en association avec Galaxy Industries Corporation s.a

Au terme de l'évaluation des offres faite par la commission, une seule offre, celle du Groupement Le Floch dépollution/CSE, avait été déclarée conforme pour l'essentiel du DAO pour un montant de 10 650 356 567 FCFA TTC.

Puis, par lettre du 13 septembre 2013, la proposition d'attribution provisoire du marché a reçu l'avis de non objection de la DCMP.

Toutefois, la Banque n'a pas émis d'avis de non objection et propose la relance de l'appel d'offres. Dans cette logique, après avoir publié « un avis de classement sans suite » du marché susvisé dans le quotidien « Le Soleil » du 1er août 2014, le Groupement Le Floch/CSE a saisi, pour arbitrage, le CRD qui par la suite, a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour les besoins de l'instruction.

Par lettre du 06 août 2014, l'APIX S.A a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS :

Le requérant soutient que par procès-verbal d'ouverture des offres du 27 juillet 2012, leur groupement a été le seul, parmi les deux soumissionnaires, à produire une offre financière ainsi qu'une garantie de soumission.

Selon lui, depuis cette date, toute la procédure a été régulièrement suivie par l'APIX S.A, pour l'autorité contractante et toutes les diligences ainsi que tous les documents demandés avaient été fournis par les responsables du groupement aussi bien en France qu'au Sénégal et plusieurs voyages avaient été nécessaires.

Le processus d'attribution du marché était en phase de finalisation et le cabinet chargé du contrôle des travaux déjà sélectionné. D'ailleurs, le groupement rappelle que le Gouvernement du Sénégal s'était d'ailleurs engagé auprès de la Banque mondiale pour financer le complément du marché dans le projet de loi de finance de 2014.

C'est pourquoi, il affirme que grande a été sa surprise de recevoir de l'APIX S.A, le 21 juillet 2014 à 12 heures, une notification N°3344/APIX/DG/DPM de la « décision de déclarer l'appel d'offres sans suite ».

Le requérant rapporte les motifs invoqués dans la notification qui sont :

- invalidation de la solution technique envisagée ;
- perturbations institutionnelles dans le secteur des déchets au Sénégal au moment de l'appel d'offres. Ces éléments auraient eu, selon l'APIX S.A, pour effet d'influer négativement sur la concurrence.

Selon le Groupement Le Floch dépollution/CSE, ces motifs ne résistent à aucune analyse sérieuse. En effet :

1. c'est apparemment l'APIX S.A qui a pris la décision de déclarer l'appel d'offres sans suite alors qu'elle avait, par mail en date du 31 mars 2014, demandé au requérant de proroger la validité de son offre jusqu'au 31 juillet 2014; ce qui a été fait par lettre en date 1er avril 2014 ;
2. l'invalidation de la solution technique envisagée n'a jamais fait l'objet d'une décision officielle portée à la connaissance des soumissionnaires ;
3. si des perturbations institutionnelles dans le secteur des déchets avaient pu constituer un motif déterminant au moment de l'appel d'offres comme l'a soutenu l'APIX S.A, celui-ci ne devait pas être lancé ;

4. ces motifs n'ont pas pu avoir pour effet « d'influer négativement sur la concurrence » ; la vérité est que dans ce secteur, il y a peu de spécialistes et donc seules deux sociétés dont le requérant, avaient répondu à l'appel d'offres et la société concurrente n'avait ni fait une offre financière, ni fourni une garantie de soumission comme cela a été constaté dans le procès-verbal d'ouverture des offres ;

Il souligne qu'en décidant, de déclarer l'appel d'offres sans suite pour les motifs précités de la relancer à nouveau, l'autorité contractante a violé les dispositions de l'article 65 du Code des marchés publics puisqu'il n'y a aucun motifs précis d'intérêt général tels que la disparition du besoin qui était à l'origine de la procédure ou des montants d'offres trop élevés par rapport à la valeur estimée du marché.

En outre, pour lui, l'absence de concurrent n'est pas fonction du nombre de candidats car, même si une seule offre est soumise, le processus doit être validé si la publicité a été faite correctement, si les critères ne sont pas restrictifs et si les prix sont raisonnables par rapport au marché ;

Il ajoute, également, que si l'appel d'offres devrait être reprise alors qu'il n'y a aucun motif valable, le requérant subirait un grave préjudice puisque les éléments de son offre financière seraient déjà connus par tous les acteurs et tous les concurrents.

De plus, le Groupement Le Floch dépollution/CSE informe qu'il avait en prévision pour l'exécution du marché, parce qu'ayant déposé la seule offre compétitive, engagé d'importantes dépenses et pré-positionné déjà à Dakar, en provenance de Nicosie, une bonne partie du matériel lourd nécessaire.

Compte tenu de ce qui précède, le Groupement saisit le CRD conformément aux dispositions des articles 88, 89, suivants le Code des Marchés publics pour arbitrage.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Selon l'autorité contractante, son partenaire technique et financier a relevé des questions essentielles sur la provenance des matériaux de couverture et les coûts de transport associés, qui auront nécessairement un impact très important sur le cout final de ces travaux. En effet, pour ce dernier, le requérant n'a pas précisé où se trouvait le site d'extraction de ces matériaux, ce qui crée une certaine incertitude sur le réalisme de son offre financière.

De plus, le partenaire ajoute qu'une seule offre avait été reçue, sans doute, à cause de l'incertitude qui régnait dans le secteur des déchets (existence de la SOPROSEN) et en raison de certains points à préciser dans le DAO qui avaient suscité des demandes d'éclaircissements de la part des soumissionnaires potentiels, qui s'étaient finalement abstenus de soumettre une offre .

Ainsi, la Banque a réservé son avis de non objection pour des raisons tenant essentiellement de la réception d'une seule offre recevable induisant une supposée absence de compétitivité.

L'autorité contractante renseigne, toutefois, que l'offre du Groupement Le Floch dépollution/CSE est tout à fait conforme. Ce qui, du reste, a été confirmé par les résultats de la contre-expertise initiée par l'IDA.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le classement sans suite de l'appel d'offres litigieux et sur la proposition de sa relance.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu'en vertu de l'article 64 du Code des Marchés publics, l'autorité contractante, après consultation de la Direction chargée du Contrôle des Marchés, peut déclarer un appel d'offres infructueux lorsque selon l'avis de la commission des marchés compétente, aucune offre n'a été remise à l'expiration de la date limite de dépôt des offres ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrecevables ou non conforme, bien que toutes les conditions devant assurer le succès de l'appel à la concurrence aient été remplies ;

Considérant que l'article 65 du Code des Marchés publics dispose que l'autorité contractante peut, après consultation de la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics, ne pas donner suite à un appel d'offres pour des motifs d'intérêts général, tels que la disparition du besoin qui était à l'origine de la procédure ou des montants d'offres trop élevés par rapport à la valeur estimée du marché ;

Considérant qu'en l'espèce, APIX S.A a classé l'appel d'offres sans suite la procédure visée, après avis favorable de la DCMP qui est fondé sur le refus de la Banque mondiale d'émettre un avis de non objection sur l'attribution provisoire du marché pour les raisons suivantes :

- la provenance des matériaux de couverture non précisée dans l'offre de la requérante et les coûts de transport associés ;
- des perturbations institutionnelles qui caractérisées le secteur de la gestion des déchets et ayant influés sur la concurrence ;

Considérant qu'après examen des pièces du dossier à la lumière de la réglementation et des pratiques en matière de marchés publics, ces motifs se révèlent insuffisants pour fonder le classement sans suite de la procédure de passation du marché en question ;

Qu'en effet, comme le souligne le maître d'ouvrage, les précisions sur la provenance des matériaux de couverture et les coûts de transport associés peuvent être abordées au moment de la stabilisation du dossier d'exécution que le Groupement a l'obligation de produire pour préciser les conditions d'exécution des travaux avant leur démarrage effectif ;

Que lequel dossier d'exécution sera soumis à la validation du maître d'ouvrage appuyé par son consultant assurant la mission de maître d'œuvre qui ont l'obligation de veiller à la prise en compte de toutes les mesures permettant de mitiger les risques liés à l'exécution du marché sur la base de l'offre de l'attributaire provisoire ;

Que « le contexte institutionnel » que relève le partenaire technique et financier a été connu d'elle et qu'il ne l'a, ni empêché d'émettre un avis de non objection sur le dossier d'appel à la concurrence, ni poussé à attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le risque ;

Que de plus, dire que la réception d'une seule offre conforme est due au contexte institutionnel procède d'une spéculation si l'on sait qu'aucun des candidats ayant retiré le dossier d'appel à la concurrence n'en a fait état et que d'autres raisons peuvent être à l'origine des désistements, notamment le plan de charge incompatible avec les délais de réalisation requis, une incapacité de satisfaire les exigences techniques ou financières etc. ;

Qu'il s'y ajoute que la procédure a fait l'objet d'une large publicité (UNDB, Jeune Afrique, Le Soleil, l'Observateur et le site des marchés publics) dont la portée est attestée par le nombre significatif de candidats ayant retiré le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant, par ailleurs, qu'au regard des Directives de la Banque mondiale, le classement sans suite sur la base de la réception d'une seule offre pose problème si l'on s'en réfère à la clause 2.61 du même texte qui dispose que « même si seulement une offre est soumise, le processus d'appel d'offres peut être considéré comme valide si l'appel d'offres a été correctement publié, si les critères de qualification n'ont pas été excessivement restrictifs et si les prix sont raisonnables par rapport aux valeurs du marché » ;

Que le rapport fourni par le Consultant ARTELIA, en guise d'évaluation de la « crédibilité technique et financière de l'offre du groupement » suite à la recommandation de la Banque mondiale, a conclu que « l'offre est globalement conforme, techniquement et financièrement » ;

Qu'en considération de ce qui précède, tout classement sans suite de la procédure, pour les motifs susvisés, en vue de sa relance n'est pas conforme aux règles du Code des marchés publics ainsi qu'à celles des Directives de la Banque mondiale et par conséquent, doit être considéré comme étant abusif ;

Considérant que l'abus de droit peut déboucher sur une procédure en réparation du préjudice subi par la victime devant les tribunaux compétents et qu'en l'espèce, la responsabilité sera imputée à l'emprunteur et non au bailleur du fait que ce dernier est tiers à la relation contractuelle établie par le dossier d'appel à la concurrence ;

Qu'au vu du montant de l'attribution provisoire du marché qui est de 10 650 356 567 (dix milliards six cent cinquante millions trois cent cinquante six mille cinq cent soixante sept francs CFA TTC), le risque financier lié au classement sans suite, jugé abusif, est de loin plus important que celui s'attachant à la provenance des matériaux de couverture et les coûts de transport associés ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la procédure en question ;

Que dans le cas contraire, le maître d'ouvrage devra provisionner les sommes nécessaires au paiement d'éventuels dommages et intérêts ;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu d'ordonner la restitution de la consignation ;

PAR CES MOTIFS :

- 1) Constate que APIX S.A a classé sans suite la procédure visée à cause du refus du partenaire technique et financier d'émettre un avis de non objection sur l'attribution provisoire du marché ;
- 2) Dit que le classement sans suite de la procédure, pour les motifs invoqués par le bailleur en vue de sa relance n'est ni conforme aux règles du Code des Marchés Publics ni à ses propres directives ;
- 3) Déclare, en conséquence, le classement sans suite abusif ;
- 4) Dit que le risque financier lié au classement sans suite, jugé abusif, est de loin plus important que celui s'attachant à la provenance des matériaux de couverture et les coûts de transport associés ;
- 5) Ordonne la poursuite de la procédure en question ;

6) Ordonne la restitution de la consignation ;

7) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier, au Groupement d'Entreprises le Floch dépollution/CSE, à APIX S.A et à la Direction centrale des Marchés publics, la présente décision qui sera publiée sur le site officiel des marchés publics.

Le Président
Mademba GUEYE

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG

20

**L'AVIS DU CRD NE PEUT FAIRE GRIEF AU
REQUERANT**

Aux termes de l'article 2.5 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, cette dernière est chargée de veiller, par ses avis et recommandations, à l'application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de services, des documents standards et contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises et de compétences nationales stables et performantes.

La Société de Services d'Inspection et de Conseil (SSIC) a participé à une consultation lancée par la SICAP S.A pour des prestations de contrôle technique des travaux de construction du projet Sicap Sacré Cœur III VDN Extension.

Le projet de « convention bureau de contrôle technique » dont la signature était envisagée avec la SICAP S.A prévoit en son article 3 intitulé : « durée et déroulement des missions du contrôleur », une clause libellée comme suit : « en cas de dépassement des délais d'exécution des travaux, pour quelques raisons que ce soit, le prestataire est tenu d'accomplir sa mission jusqu'à la fin du chantier sans honoraires supplémentaires »

Estimant que cette clause est abusive, la SSIC s'en est ouverte à l'autorité contractante et lui proposa l'introduction d'un coût mensuel en cas de dépassement de délais.

Les responsables de la SICAP lui ayant fait savoir qu'ils se plieront à l'avis de l'ARMP, la SSIC saisit alors le CRD d'une demande d'avis sur la clause jugée abusive du contrat et la possibilité, pour le bureau de contrôle technique, de percevoir un coût mensuel en cas de dépassement des délais.

Par avis n°8 du 10 septembre 2014, le CRD déclara que la demande de SSIC, relative à l'insertion d'une clause dans le contrat, pour un coût mensuel en cas de prolongation de la durée des travaux, n'est pas fondée, parce que, non seulement les prestations attendues du bureau de contrôle sont, pour l'essentiel, des tâches ponctuelles dont le volume n'augmente pas, de façon systématique, s'il ya prolongation du délai des travaux, mais également, la rémunération du bureau de contrôle technique est déterminée à partir d'un pourcentage du marché des travaux ; que cependant, pour l'équilibre du contrat, la clause litigieuse doit être reformulée pour une juste répartition des obligations entre les parties, parce que telle qu'elle est libellée elle constitue une clause pénale qui exonère l'autorité contractante de toute responsabilité alors que toutes les charges pèsent sur le cocontractant.

**AVIS N° 008/14/ARMP/CRD DU 10 SEPTEMBRE 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE DE SERVICES D'INSPECTION
ET DE CONSEIL (SSIC) CONCERNANT L'INCLUSION D'UNE CLAUSE JUGEE ABUSIVE
DANS LE CONTRAT RELATIF AU CONTRÔLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU PROJET SICAP SACRE COEUR III VDN EXTENSION**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la Société de Services d'Inspection et de Conseil (SSIC) du 20 août 2014, enregistrée le 27 août 2014 au secrétariat du CRD sous le n° 237/14,

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saer NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d'enquêtes et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ;

Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d'Enquête et d'Inspection; Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques et Moussa DIAGNE, chef de la Division Formation, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente décision :

Par correspondance du 20 août 2014, enregistrée le 27 août 2014 au secrétariat du CRD sous le n° 237/14, la Société de Services d'Inspection et de Conseil (SSIC) a saisi le CRD pour d'une demande d'avis sur l'inclusion d'une clause dans le dossier de consultation pour le contrôle technique des travaux de construction du projet Sicap Sacré Coeur III VDN Extension.

163

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD

Considérant qu'aux termes de l'article 2.5 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007, l'ARMP est chargée de veiller, par ses avis et recommandations, à l'application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat et contribuer à la promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence ;

Considérant qu'à ce titre, l'ARMP peut être saisie par toute autorité contractante, tout candidat ou titulaire de marchés pour avis sur l'application, le sens ou la portée de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat, des documents standards, ou des décisions relatives aux procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics ;

Considérant qu'une saisine du CRD dans de tels cas n'est soumise à aucune condition de délai et de forme ;

Qu'à cet égard, il convient de déclarer la saisine de SSIC recevable.

LES FAITS

La Société de Services d'Inspection et de Conseil (SSIC) a participé à une consultation lancée par la SICAP SA pour des prestations de contrôle technique des travaux de construction du projet Sicap Sacré Coeur III VDN Extension. Ayant constaté dans le projet de contrat une clause qu'elle juge abusive, la Société de Services d'Inspection et de Conseil (SSIC) s'en est ouverte à l'autorité contractante. Elle affirme que cette dernière lui a demandé de faire une contre proposition.

C'est ainsi qu'elle a proposé l'introduction d'un coût mensuel en cas de dépassement de délais.

Le requérant affirme néanmoins que sur quatre (04) cabinets qui avaient répondu à la consultation, deux (02) ont accepté la clause jugée abusive du projet de contrat.

Le requérant soutient que les responsables de la SICAP lui ont fait savoir qu'ils se plieront à l'avis de l'ARMP si cet organe est saisi.

C'est pour cette raison que la SSIC a soumis la demande d'avis au Comité de Règlement des Différends (CRD).

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DE LA DEMANDE

A l'appui de la demande, SSIC a joint le projet de « convention bureau de contrôle technique » dont la signature était envisagée avec la SICAP SA. Ledit projet prévoit à l'article 3 intitulée « durée et déroulement des missions du contrôleur technique », une clause qui fait obligation au prestataire d'accomplir sa mission jusqu'à la fin du chantier sans avoir droit à des honoraires supplémentaires en cas de dépassement des délais d'exécution des travaux, pour quelques raisons que ce soit.

Estimant que la clause susvisée est abusive, le requérant propose en lieu et place, l'introduction d'un coût mensuel en cas de dépassement de délais.

L'OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent que la demande vise à recueillir l'avis du CRD sur la clause jugée abusive du contrat et la possibilité, pour le bureau de contrôle technique, de percevoir un coût mensuel en cas de dépassement des délais.

AU FOND

Considérant que la clause contestée est libellée en ces termes « *en cas de dépassement des délais d'exécution des travaux, pour quelques raisons que ce soit, le prestataire est tenu d'accomplir sa mission jusqu'à la fin du chantier sans honoraires supplémentaires* » ;

Qu'à l'analyse, la clause peut être qualifiée de clause pénale qui exonère l'autorité contractante de toute responsabilité pécuniaire alors que le co-contractant est mis dans une situation de supporter toute charge financière induite par un prolongement du délai des travaux quelles qu'en soient l'ampleur et l'origine ;

Qu'à l'évidence, la clause incriminée étant de nature à conférer au contrat un caractère déséquilibré, le requérant est fondé à la dénoncer ;

Considérant que SSIC propose une substitution de la clause contestée par une autre qui prévoit un coût mensuel en cas de dépassement du délai des travaux ;

Considérant qu'en l'espèce, la mission du bureau de contrôle technique vise à prévenir les aléas techniques résultant d'un défaut d'application des normes et des règlements susceptibles de nuire à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (mission L), à la sécurité des personnes du fait des installations électriques (mission S) et au fonctionnement des installations (mission F) ;

Que dans ce cadre, il ressort de l'examen du projet de contrat que les prestations du bureau de contrôle technique s'étendent de la signature du contrat à la réception définitive et se déroulent en quatre phases :

Phase 1 : examen des documents de conception ;

Phase 2 : examen des documents d'exécution ;

Phase 3 : examen sur le chantier de la réalisation des ouvrages, participation au rendez-vous de chantier, rédaction des rapports de fin de chantier et ceux destinés aux assureurs, assistance à la réception définitive ;

Phase 4 : examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement ;

Qu'au vu des prestations ci-dessus décrites, le bureau de contrôle technique assure, pour l'essentiel, des tâches ponctuelles dont le volume n'évolue pas, de manière systématique, lorsqu'il y a prolongation du délai d'exécution des travaux ;

Qu'il s'y ajoute que dans le contrat envisagé, le bureau de contrôle technique est rémunéré selon un pourcentage fixé par rapport au montant des travaux ;

Qu'à cet égard, le bureau de contrôle technique ne peut réclamer, à bon droit, un réajustement du montant de son contrat, s'il ne justifie pas qu'à l'exécution le volume de ses prestations a augmenté pour une cause indépendante de sa volonté, ou bien que le montant des travaux a subi une modification induisant un changement de l'assiette de calcul de sa rémunération, déterminée selon un pourcentage du montant des travaux ;

Que du reste, conformément aux dispositions des articles 121 et suivants du Code des Obligations de l'Administration, lorsqu'à l'exécution des prestations le titulaire subit un préjudice établi, notamment en cas de retard des travaux, le principe de l'indemnisation est envisageable si le préjudice découle d'une situation extérieure à la volonté du titulaire et imputable au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants ;

Qu'en considération de ce qui précède, la demande de SSIC relative à l'inclusion d'une clause dans le contrat pour un coût mensuel en cas de prolongation de la durée des travaux, n'est pas fondée ; Que toutefois, compte tenu de son caractère abusif, la clause contestée doit être reformulée dans le sens d'équilibrer les obligations des deux parties ;

PAR CES MOTIFS :

1) Déclare recevable la saisine de SSIC ;

2) Constate que les prestations attendues du bureau de contrôle sont, pour l'essentiel, des tâches ponctuelles dont le volume n'augmente pas, de façon systématique, s'il y a prolongation du délai des travaux ;

- 3) Constate que la rémunération du bureau de contrôle technique est déterminée à partir d'un pourcentage du marché des travaux ;
- 4) Dit que la demande de SSIC relative à l'insertion d'une clause dans le contrat, pour un coût mensuel en cas de prolongation de la durée des travaux, n'est pas fondée ;
- 5) Dit que la clause contestée peut être qualifiée de clause pénale qui exonère l'autorité contractante de toute responsabilité alors que toutes les charges pèsent sur le cocontractant ;
- 6) Dit que pour l'équilibre du contrat, la clause doit être reformulée par une juste répartition des obligations entre les deux parties ;
- 7) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) est chargé de notifier à la Société d'Inspection de Conseil et de Services (SSIC) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), le présent avis qui sera publié.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Les membres du CRD
Samba DIOP Boubacar MAR Cheikhou Issa SYLLA

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

Par lettre du 18 décembre 2014, le directeur général de la SSIC adressa au Directeur général de l'ARMP des observations relatives à cet avis du CRD, tout en reprenant ses arguments déjà développés devant le CRD.

Par lettre n°60 du 12 janvier 2015, le directeur général de l'ARMP lui rappela les termes de l'avis tout en lui précisant d'une part que le CRD ne peut statuer à nouveau sur le dossier puisqu'un avis est déjà rendu et que d'autre part le CRD n'est pas habilité à définir la clause contestée, ladite prérogative revenant à l'autorité contractante.

Suivant requête reçue le 16 mars 2015 à la Cour suprême, la SSIC sollicite l'annulation de la lettre susvisée du directeur général de l'ARMP.

Mais, par arrêt n°22 du 24 mars 2016, le juge du droit déclara irrecevable le recours en faisant valoir, avec pertinence, qu'il est dirigé contre la lettre du directeur général de l'ARMP qui se borne à rappeler le sens d'un avis du CRD, lequel n'est pas une décision au sens de la loi puisqu'elle ne fait pas grief au requérant et ne modifie en rien l'ordonnancement juridique.

21

**REVERSEMENT DE LA CONSIGNATION
AU REQUERANT DONT LE RECOURS EST
FONDE**

En vertu de l'article 90, alinéas 2 et 3 du code de 2014, le recours auprès du CRD du candidat à une procédure d'attribution d'un marché « n'est recevable que s'il invoque une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagné de la pièce attestant du paiement d'une consignation dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

La consignation est reversée au requérant lorsque son recours est fondé.

Suite au recours initié par la Société Triple A contre les critères de qualification mentionnés dans l'avis d'appel d'offres lancé par le COUD, le CRD, par décision n°322 du 26 novembre 2014 a déclaré le recours fondé, sans ordonner la restitution de la consignation au requérant.

C'est pourquoi, par décision n°347 du 17 décembre 2014, le CRD a ordonné ladite restitution.

**DECISION N° 347/14/ARMP/CRD DU 17 DECEMBRE 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT SUR LA RESTITUTION DE
LA CONSIGNATION DE LA SOCIETE TRIPLE A SUITE A LA DECISION D'ANNULATION
D'UNE DISPOSITION POUR VIOLATION A LA REGLEMENTATION SUR LA PROCEDURE
DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L'APPEL D'OFFRES DU CENTRE DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES DE DAKAR (COUD) AYANT POUR OBJET DE LANCER UN MARCHE DE
CLIENTELE POUR L'EXPLOITATION ET LA GESTION DES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
DE « CENTRAL, ASD, ESP DAKAR, ENSETP, BLOC ISFAR-ENSA-CMRT, UFR SANTE-HOTEL
du RAIL, RESTAURANT ZIGUINCHOR ET EPT THIES**

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

168

Vu le Code des Obligations de l'Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la Société TRIPLE A SARL ;

Vu la quittance de consignation du 07 novembre 2014 ;

Vu la décision n° 322/14/ARMP/CRD du 26 novembre 2014 du Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges sur le recours de la société TRIPLE A portant sur l'annulation d'une disposition pour violation à la réglementation sur la procédure de passation du marché relatif à l'appel d'offres du Centre des œuvres Universitaires de Dakar ayant pour objet de lancer un marché de clientèle pour l'exploitation et la gestion des restaurants universitaires de «de Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, BLOC ISFAR-ENSA, CMRT, UFR SANTE – Hôtel du Rail, Restaurant de Ziguinchor et EPT Thiès répartis en 7 lots. » ;

Après avoir entendu le rapport de Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des affaires juridiques ; Ousseynou CISSE, chargé d'enquêtes ; et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi ; Khadijetou Dia LY, chargée d'enquêtes et Mame Aïssatou DIENG, chef de la Division Appuis techniques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 06 novembre 2014, enregistrée le lendemain au bureau du courrier puis au Secrétariat du CRD le 07 novembre 2014 sous le numéro 3259, la Société Triple A a introduit un recours dirigé contre les critères de qualification mentionnés dans l'avis d'appel d'offres n° S02/14 marché de clientèle, du COUD publié dans le journal « Le Soleil » du mercredi 24 octobre 2014.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 24 Octobre 2014, le Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD) a lancé un avis d'appel d'offres ayant pour objet l'exploitation et la gestion des restaurants universitaires de Central, ASD, ESP Dakar, ENSETP, BLOC ISFAR-ENSA, CMRT, UFR SANTE – Hôtel du Rail, Restaurant de Ziguinchor et EPT Thiès répartis en 7 lots.

Par courrier en date du 30 Octobre 2014, la Société TRIPLE A SARL a introduit un recours gracieux auprès de l'Autorité Contractante en vue de l'annulation de la disposition IC 5.4 (b), puis le CRD par courrier du 6 novembre 2014.

Après avoir déclaré le recours recevable, par décision n°311/14/ARMP/CRD du 12 novembre 2014, le Comité de Règlements des Différends a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché et a demandé la transmission des pièces du dossier de marché pour les besoins de l'instruction.

Par lettre du 18 novembre 2014, Le Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD) a transmis l'avis d'appel d'offres et le dossier d'appel d'offres.

Par décision n° 322/14/ARMP/CRD du 26 novembre 2014, le CRD a déclaré que le recours de Triple A est fondé.

SUR LA CONSIGNATION

Considérant qu'aux termes de l'article 90 du code des marchés publics, la saisine du Comité de Règlement des Différends se fait par notification écrite et que le recours n'est recevable que s'il invoque une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et est accompagné de la pièce attestant du paiement d'une consignation dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances ;

Considérant que la consignation est reversée au requérant lorsque son recours est fondé ;

Considérant que par décision n° 322/14/ARMP/CRD du 26 novembre 2014, le CRD a déclaré que le recours de Triple A est fondé ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la restitution la consignation ;

PAR CES MOTIFS:

- 1) Ordonne la restitution de la consignation ;
- 2) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la Société TRIPLE A, à la Direction du COUD ainsi qu'à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

**Le Président
Mademba GUEYE**

Samba DIOP **Les membres du CRD**
Boubacar MAR **Cheikhou Issa SYLLA**

**Le Directeur Général
Rapporteur
Saër NIANG**

Le paiement d'une consignation par le candidat qui initie un recours contentieux auprès du CRD est une nouveauté du code de 2014, qui n'existait ni dans le code de 2007, ni dans celui de 2011.

Mais cette nouvelle disposition qui permet, entre autres, de lutter contre les recours qui pourraient être qualifiés de fantaisistes, n'a pas, pour autant, entraîné une baisse des recours, qui est passé de 359 à 2014 à 369 à 2015.

«Brochure réalisée avec l'appui de la Coopération Sénégal-Luxembourg dans le cadre du Programme d'Appui à l'Exécution nationale – SEN/030-T1»

